

특허제도를 보완하기 위한 기술공유화에 대한 연구

A Study on Technology Sharing to Complement Patent System



Korean Intellectual Property Office

특허제도를 보완하기 위한 기술공유화에 대한 연구

A Study on Technology Sharing to Complement Patent System

2010. 12.



Korean Intellectual Property Office

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “특허제도를 보완하기 위한 기술공유화에
대한 연구”과제의 결과보고서로 제출합니다.

2010. 12.

수탁기관 : 한국지식재산연구원(KIIP)

연구책임자 : 신지연(KIIP 부연구위원)

연구원 : 전성태(KIIP 부연구위원)

조지은(KIIP 연구원)

장태미(KIIP 연구원)

<目 次>

제1장 서론	1
제1절 연구목적	1
제2절 연구의 방법 및 범위	2
제2장 특허제도의 역사적 고찰	3
제1절 서설	3
제2절 특허제도의 역사적 변천	4
I. 특허제도의 비판론과 국제특허제도의 탄생	4
1. 유럽에서의 특허제도의 비판론	4
2. 국제특허제도의 탄생	12
II. 우리나라에서의 특허제도의 성립과 변천	21
1. 서언	21
2. 특허법 제정 전의 우리나라의 특허제도	21
3. 독자적인 대한민국 특허법의 제정 및 발전	23
제3절 소결	25
제3장 제도론적 관점에서의 특허제도의 한계	28
제1절 서설	28
제2절 공익 및 기술혁신과 관계된 특허제도의 한계	28
I. 기후변화 대응과 특허제도	28
1. 기후변화협약의 의의	28
2. 기후변화협약과 환경문제	29

3. 기후변화협약에 있어서 특허권 문제	30
II. 의약품(공중보건)과 특허제도	32
1. TRIPS 협정과 공중의 건강에 관한 선언	32
2. 의약품과 특허권	34
III. 리서치 툴과 특허제도	35
1. 리서치 툴 특허의 의의 및 유형	35
2. 리서치 툴 특허의 문제점	37
IV. 정리	39
제3절 특허권의 남용과 관계된 특허제도의 한계	40
I. Patent Troll과 특허남용	40
1. Patent Troll의 의의 및 유형	40
2. Patent Troll이 특허제도에 미치는 영향	43
II. 특허풀과 특허남용	44
1. 특허풀의 의의 및 종류	44
2. 독점규제 방지를 위한 특허풀 제한	47
III. 정리	48
제4절 소결	49
제4장 기술공유제도에 대한 설문조사	51
제1절 설문조사 실시 목적 및 개요	51
I. 설문조사 실시 목적	51
II. 설문조사의 개요	51
제2절 설문 항목별 조사 결과 및 분석	53
I. 특허제도의 문제점과 기술공유에 대한 인식	53
1. 특허제도의 문제점 조사	53
2. 기술 공유의 필요성 및 기술공유가 도움이 되는 부문	54
3. 기술공유에 대한 사례 인지도와 활용 경험 및 효과	56
4. 기술공유의 지지 및 활용 분야	58

5. 공공의 이익 관련 정부 주도의 기술공유 정책	61
II. 기술 공유 관련 법제도 및 정책	62
1. 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 인지도	62
2. 공익관련 특허 실시제도의 효율성	63
3. 특허법상 공익관련 특허 실시제도의 확대 의견	65
4. 정책적 측면에서의 제도보완의 방향성 및 적절한 수단	66
III. 기타 의견	68
제3절 소결	70
I. 현행 특허제도의 문제점과 기술공유에 대한 인식	70
II. 기술공유 관련 법제도 및 정책수립 방향	71
 제5장 기술공유제도의 모델 분석 및 제도설계방향	73
 제1절 서설	73
제2절 종래 기술 공유관련 제도적 모델	74
I. 특허기부(기술기부채납) 제도	74
1. 도입 배경	74
2. 특허기부제도의 개념	75
3. 특허기부의 법적 성격	76
4. 특허기부제도를 통한 미활용 기술의 활용	77
II. 특허풀 제도	78
1. 축적형 기술에 대한 대응	78
2. 크로스라이센스의 보급	79
3. 우리나라에서의 특허풀 동향	80
4. 특허풀의 전망	81
IV. 정리	81
제3절 최근 민간 주도의 기술공유 모델	82
I. 특허 공용제(Patent Commons)	82
1. Eco-Patent Commons	82

2. Science Commons	85
II. 특허협력제(Green Xchange)	87
1. 성립배경 및 이유	87
2. 참여기업	89
III. 기타 모델(Open Source 운동)	89
1. 오픈소스 SW의 발생 배경 및 의의	89
2. 오픈소스 SW 운동의 시사	92
IV. 정리	93
제4절 일본의 GTPP 제안과 WIPO의 대응	95
I. 서설	95
II. 일본의 GTPP 제안	96
1. 개도국으로의 기술이전의 과제	96
2. 그린기술 패키지 프로그램(GTPP)	96
3. 라이선스 규칙의 완화·철폐에 대한 국제 규범 검토	100
4. 기타 추가 서비스의 검토	100
III. WIPO의 대응	101
제5절 소결	101
제6장 결론	103
<참고문헌>	105

<표 차례>

<표 III-1> COP14에서의 개도국이 주장한 내용	30
<표 IV-1> 조사 설계의 내용	52
<표 V-1> Eco-Patent Commons의 운영방침에 대한 내용	83
<표 V-3> Science Commons의 주요 활동	87
<표 V-2> 오픈소스 SW 운동의 연혁	90
<표 V-3> 일반 상용 SW와 오픈소스 SW의 비교	92

<그림 차례>

<그림 IV-1> 특허제도의 문제점	53
<그림 IV-2> 기술공유의 필요성 및 기술공유가 도움이 되는 부문	55
<그림 IV-3> 기술공유가 도움이 되지 않는 이유	56
<그림 IV-4> 기술공유사례 인지도 · 활용경험 및 활용가치	57
<그림 IV-5> 기술공유제도의 활용효과	58
<그림 IV-6> 기술공유제도의 지지도 및 활용분야	59
<그림 IV-7> 기술공유제도를 지지하지 않는 이유	60
<그림 IV-8> 공익관련 기술공유정책의 동참의향	62
<그림 IV-9> 특허법상 공익관련 특허실시제도의 인지도	63
<그림 IV-10> 공익관련 특허실시제도의 효율성	64
<그림 IV-11> 공공분야의 특허법상 공익관련 특허실시제도의 범위 확대	65
<그림 IV-12> 정책적 측면에서의 제도보완의 방향성	66
<그림 IV-13> 제도보완 시 적절한 수단	67
<그림 V-1> 녹색기술 패키지 프로그램 하에서의 기술이전의 예	102

제1장 서론

제1절 연구목적

19세기 후반, 유럽에서 일어난 특허제도의 비판론은 특허제도는 독점을 제도적으로 보장하는 것이므로 문제가 된다는 주장, 유럽 국가 중에서도 산업발전이 늦은 국가에는 경제발전에 유리하지 않다는 주장, 특허제도는 자유무역에 반하는 제도라는 주장 등 다양한 비판이 있었다. 그러나 유럽 국가들은 대공황에 따른 보호무역주의로의 전환정책, 미국의 국제특허정책, 유럽 각국의 산업혁명의 진전, 강제실시제도의 창설 등 경제적·사회적인 패러다임의 요청 속에서 오늘날의 특허제도로 자리 잡게 되었다.

이와 같이, 19세기 특허의 독점에 대한 폐해 문제는 오늘날 다시금 특허제도의 새로운 패러다임을 요구하고 있다. 이를 테면, 공익과 관계된 기후변화, 공중보건에 있어서의 특허의 독점문제, 리서치 툴과 같은 기술혁신에 필수적인 분야에 마저 독점을 부여하여 후속개발이 이루어지지 않는 문제, 게다가 특허제도를 지나치게 비즈니스모델로 활용하는 패트론틀(patent troll)이나 특허풀 형성과 같은 특허권의 남용 문제 등을 들 수 있다. 이러한 문제들이 21세기의 특허제도의 패러다임(특허 2.0이나 Soft IP 개념 등)을 요구하고 있는 것이다.

이러한 패러다임 가운데, 하나의 현상으로 볼 수 있는 것이 바로 기술(특허) 공유 운동이다. 대표적인 예로서 특허 기부제나 민간 주도의 기술공유 운동인 Eco-Patent Commons 및 GreenXchange, 소프트웨어 분야의 Open Source Movement, 의약품 분야의 ‘Open Source Drug Discovery Project’ 등이 나타나고 있다. 이러한 공유와 관련된 운동들은 특허제도를 보완하기 위한 하나의 대안으로 인식되고 있다. 특허제도의 지나친 독점의 폐해를 기술공유를 통하여 제거하면서 특허제도가 산업발전에 기여하는 제도로서 거듭날 필요가 있다.

그러므로 특허제도의 새로운 패러다임에 대응하여 현재 특허제도를 보완할 수 있는 기술 공유운동에 대한 면밀한 검토와 분석이 요구된다. 따라서 본 연구에서는 특허제도의 역사적 고찰, 설문조사, 기술 공유모델 등을 분석하여 특허제도를 보완하는 기술공유제도에 대한 방향성을 제시하고자 한다.

제2절 연구의 방법 및 범위

본 연구는 국내·외 관련 논문, 연구보고서에 대한 문헌연구와 기술 공유관련 기업, 연구소, 학자 등 전문가에 대한 설문조사 및 분석을 통한 실증연구를 중심으로 특허제도를 보완하기 위한 기술 공유모델에 대한 방향성을 제시한다.

특히 특허제도가 산업발전에 기여한다는 본연의 목적을 달성할 수 있도록 특허제도의 보완적 측면에서 연구하고자 한다. 이를 위해, 19세기 특허제도의 비판론에 관하여 역사적으로 고찰하여 시사점을 도출하고, 현재 특허제도의 문제점인 공익과 기술혁신, 그리고 특허권 남용 등 특허제도의 제문제에 대한 실태를 파악한다. 이러한 문제현상을 직시하고, 각계 전문가를 대상으로 하여 설문조사를 실시하여 기술공유에 대한 방향성에 대한 의견을 수집한 후, 현재 진행되고 있는 기술 공유모델을 분석하여 결론을 도출한다.

제2장에서는 19세기에 활발히 일어났던 특허제도의 비판론과 국제특허제도가 형성되기까지의 국제적 동향 및 우리나라의 특허제도의 변천사를 검토하고, 이것이 현시점에서 특허제도에 어떠한 시사점을 주고 있는지를 살펴본다.

제3장에서는 제도론적 관점에서 특허제도가 가진 한계이자 문제점에 대한 현황과 실태를 파악하고자 한다. 특히 공공의 이익(기후변화, 환경, 공중보건)과 기술혁신(리서치 툴), 그리고 Patent Troll 및 특허풀에 있어서의 특허남용을 중심으로 현재 특허제도가 처해있는 현실에 대하여 검토한다.

제4장에서는 학계·산업계·연구계 등 각 분야 전문가들을 대상으로 인터뷰 형 설문조사를 실시하여 특허제도의 문제점과 이를 보완하기 위한 관련제도 및 정책에 대한 의견을 수렴한다.

제5장에서는 특허제도의 문제점 및 폐해를 극복하고 현행 특허제도를 보완하기 위한 방안으로써 기술공유화 운동에 관한 모델들을 검토한다. 특허풀, 특허기부제도와 Eco-Patent Commons, GreenXchange, Science commons, Open Source 운동 및 일본의 제안과 WIPO의 대응 등 기술 공유모델에 대해 분석하고, 정리한다.

제6장에서는 이상의 연구결과를 요약하고, 특허제도를 보완하기 위한 기술공유화 제도 도입에 제도적 설계의 방향성을 제시한다.

제2장 특허제도의 역사적 고찰

제1절 서설

19세기 후반, 유럽에서는 특허비판 내지 특허제도 폐지론이 등장하였다. 특허제도는 독점을 제도적으로 형성하는 것이므로 문제된다는 주장, 유럽 내에서도 산업발전이 뒤쳐진 국가에서는 경제발전에 유리하지 않다는 주장 및 특허제도는 자유무역에 반하는 제도라는 비판 등 그 의견이 다양하였다. 이러한 특허제도의 인식 전환이 있던 시기는 1870년대라고 마하루프는 언급하고 있다.¹⁾ 이 시기인 1873년에 오스트리아 빈에서 만국박람회가 개최되었고, 이와 동시에 공업소유권에 관한 국제회의가 개최되었다.

이 시기에는 미국의 국제특허정책과 유럽의 대공황이라는 상황 속에서 각국의 무역정책이 보호무역주의로 전환되는 시기였다. 이러한 상황 하에 특허제도는 보호무역주의 하에서 재평가되었다.²⁾ 이와 같이, 유럽의 특허제도 비판론에서 국제특허제도가 탄생하기까지의 역사적 과정과 우리나라의 특허제도의 변천사 등을 살펴보고자 한다.

특히, 19세기는 특허제도에 대한 새로운 패러다임이 정립된 시기이고, 이 시기를 거치면서 특허제도는 점차 산업발전에 있어 극히 중요한 제도로써 자리 잡게 되었다. 특히 기업에 있어서는 경쟁력의 수단 혹은 기업전략의 핵심적 요소로 작용하게 되었다. 이러한 19세기에 대한 특허제도의 패러다임에 관한 문제는 현시점인 지금도 재점화되고 있다. 공익과 기술혁신, 특허제도의 남용적 독점현상이 발생하는 등 특허제도의 변화에 대한 요구가 대두되고 있다.

따라서 본 장에서는 19세기 유럽의 특허제도의 비판론과 국제특허제도가 탄생하기까지의 일련의 역사적 과정을 살펴보고, 이것이 현재 특허제도에 제기되고 있는 새로운 패러다임의 요구에 어떠한 시사를 내포하고 있는지 검토해 보고자 한다. 아울러 우리 특허제도의 역사적 변천내용에 대해서도 살펴보고자 한다.

1) 마하루프는 "특허보호에 대한 인식은 반특허 운동이 급격히 붕괴한 1873년에 그 흐름이 바뀌었다. 이러한 급격한 변화에 대해서는 대공황과 이에 따른 보호 무역론의 대두, 내셔널리즘의 대두 및 특허옹호론자의 타협을 받아 들일 수 있는 준비 등을 이유로 들 수 있다" (Machlup, F, "An Economic Review of the Patent System", 1958, p.25 및 土井輝生訳, 「特許制度の経済学」, 日本経済新聞社, 1975 참조)고 하였다.

2) 石井 正, "特許廃止論から国際特許制度への転換の時代", 「パテント」, 日本弁理士会, Vol. 61, 2008, 29頁.

제2절 특허제도의 역사적 변천

I. 특허제도의 비판론과 국제특허제도의 탄생

1. 유럽에서의 특허제도의 비판론

가. 영국에서의 특허제도의 비판

영국에서는 그간 비판이 계속되어 온 특허법을 1852년에 개정하였다. 특허관리위원회를 설치하여 15개 내지 16개의 관청에 분산되어 있었던 관리 사무를 3部局으로 통합하고, 특허 명세서를 전문 인쇄발행하기 시작하였다. 또한 영국은 잉글랜드, 스코틀랜드 및 아일랜드에 분산되어 있었던 특허를 연합왕국특허로 통합하고, 가명세서의 제출을 인정하였으며, 출원일을 특허성립일로 명확히 하였다.

1852년 특허법 개정으로 인하여 상당한 절차적 합리성이 도모되었으며, 이전까지 특허제도의 문제점으로 지적되었던 부분들이 많이 개선되었다.³⁾ 그러나 자유무역시대에는 특허제도 자체에 대하여 많은 논의가 있었다. 특허제도 자체에 대한 폐지론은 비단 영국에서 제기된 문제만이 아닌 유럽 전체에서 논의되고 있었다.

제레미 벤담(Bentham, Jeremy)은 ‘발명의 보상’과 관련하여 일정기간의 독점 배타권 부여가 직접적인 보상금 지급에 비하여 합리적이라고 평가하였다. 이에 대하여 존스튜어트 밀(Mill, John Stuart)과 아담 스미스(Smith, Adam)도 같은 입장을 취하였으며, 특히 아담 스미스는 ‘독점은 원칙적으로 사회에 유해하지만, 발명자에게 일정기간 부여된 독점권은 발명자의 위험과 비용을 보상하는 방법’이라고 주장하였다.⁴⁾

특허권의 이론적 근거로서 자연권설, 보상 장려설, 산업 정책설, 공개대상설이 연구되어 왔다.⁶⁾ 그러나 경제학자 중에는 특허제도의 반대론자도 있었는데, 영국 특허제도 반대론의 선봉장으로서 리카르도(Ricardo)를 들 수 있다.⁷⁾ 영국 의회에서는 로버트 맥

3) Macleod, C., "Concepts of Invention and the Patent Controversy in Victorian Britain" Technological Change Methods and themes in the History of Technology(Edited by Fox, R.) Harwood Academic Publishers, 1996, p.141-142.

4) Machlup, F., *supra note 1*, p.25.

5) 石井 正, 앞의 논문, 29頁.

6) Machlup, F. & Penrose, E., "The Patent Controversy in the Nineteenth Century", *The Journal of Economic History*, Vol. 10 No.1, 1950, p.10-28.

피(McPhee, Robert)가 특허제도 폐지론의 최고 논객으로 손꼽히는데, 당시 그는 리버풀의 제당업자로 특허폐지론으로 논란이 뜨겁던 영국의회 하원의 구성원이었다. 한편, 또 다른 논객으로는 특허변호사였던 힌도 마크와 웹스터를 들 수 있는데, 이들은 특허제도의 개혁추진에는 적극적이었으나, 특허폐지 자체에는 반대하는 입장을 취하고 있었다.⁸⁾

1857년, 사회과학추진국민협의회는 특허개혁과 특허폐지론자를 위해 연차총회를 개최하였지만, 이러한 노력에도 불구하고 의회에서의 특허폐지 논란은 1883년까지 계속되었다. 그러나 특허제도의 폐지가 아닌 특허제도의 개혁 쪽으로 대세가 기울고 있었다. 당시의 문제가 된 것은 특허침해사건에 있어서 배심제의 역할과 연방항소법원의 특허 유효성 판단, 즉 전문가의 필요성에 대한 것이었다.⁹⁾ 이러한 비판은 특허제도 본질에도 영향을 미치게 되었는데, 이는 ‘발명에 대하여 특허권을 부여하는 근거가 무엇인가’라는 근본적인 물음과 관련된 것이었다. 특허권 부여의 근거에 대한 기본적인 생각은 자연권에 기초한다는 것과 공리주의에 기초한다는 것이었다.¹⁰⁾

자연권론자인 맥피는¹¹⁾ ‘특허는 사회 발전을 위하여 발명을 공개하는 것에 대한 인센티브’로 보아야 한다고 주장하였다. 또한 웹스터는 특허 공개를 지지하면서, 발명을 위한 인센티브로써 일정기간 독점권을 부여해야한다는 인센티브론도 지지하였다.¹²⁾ 맥피는 “과거 영국이 특허제도를 도입할 때 정부는 신기술을 도입할 필요성을 느끼고 있었다. 그 당시에는 발명의 수가 적었고 개발된 신기술을 누구든지 도용할 수 있었기 때문에, 발명자들은 기술 개발에 많은 위험부담을 갖고 있었다. 따라서 독점권으로서 특허가 부여되었고 이는 당시에는 합리적인 것으로 받아들여졌지만, 시대가 변함에 따라 이러한 특허제도를 더 이상 받아들일 수 없다”고 주장하였다.¹³⁾

7) 大河内曉男, 「發明行爲と 技術構想 - 技術と 特許の 經營史的 位相 -」, 東京大学出版会, 1992, 159-160頁.

8) Janis, M.D., “Patent Abolitionism”, *Berkley Technology Law Journal*, Vol.17, 2002, p.924-925.

9) 회의에서는 특별한 특허침해사건에 대하여 기술적인 전문성이 필요한 점에서 특별한 재판이 행해져야 한다는 의견과 현존하는 시스템의 개혁으로도 충분하다는 의견으로 나뉘었다. 힌드마크는 “판사가 특허사건에서 완벽한 판단을 하는 것이 아닌 점, 게다가 배심원은 기술적으로도 또한 특허제도에 관해서도 문외한인 점 등이 특허 문제로 되고 있다”고 주장하고 있었다.

10) 石井 正, 앞의 논문, 30頁.

11) 맥피는 발명자에 대하여 자연권에 기초한 권리가 있는 이상 보상장려가 필요하다고 하였다. 그러나 그 사회적 보상장려의 시스템은 일정기간 독점권을 부여하는 특허제도에 대응되었다(*Ibid.*, p.931-934).

12) *Ibid.*, p.933-935.

13) 맥피는 산업계에 다수 존재하는 특허권의 문제를 비판하였다. 이것은 현대의 특허문제에도

그렇다면 자연권에 기해 어떠한 권리를 부여할 경우, 특허권을 대체할 수 있는 것은 무엇인지에 대한 문제가 제기되었다. 이에 대해 맥피는 ‘보상장려제도’를 주장하면서, 특허청은 발명을 심사하고 그 보상액을 결정할 수 있는 정도의 관청이어야 하며, 평가를 통하여 발명자에게는 최고 1만 파운드의 보상금을 지급하거나 증명서를 부여한다는 것이 보상장려제도의 주된 내용이었다. 그러나 이러한 보상금으로 인해 연간 20만 파운드 정도의 예산이 소요될 것이 예상되었기 때문에, 벤담, 로자즈 등은 이러한 보상장려제도에 대하여 반대하였다.¹⁴⁾

1872년에 특허법 개정안이 심의되었다. 그 내용으로는 독점권으로서 비판이 강했던 특허기간을 7년으로 단축, 특허 허여를 위한 엄격한 심사의 진행, 특허 취득 후 2년 간 불실시한 특허권의 몰수, 강제실시허락 등이 있었다. 특허법 개정안은 상원을 통과하였으나, 하원은 통과하지 못하고 취하되었다. 영국에서는 이러한 특허제도에 대한 비판론이 다양하게 존재하였으나, 특허폐지론에서 점차 개혁론 쪽으로 기울면서 오히려 국제적으로 통일성 있는 특허제도가 필요하다는 주장이 제기되었다.¹⁵⁾¹⁶⁾

나. 독일의 특허제도 폐지에 대한 논의

프로이센에서는 1815년 특허법에 기초하여 특허권을 부여해 왔으나, 엄격한 심사를 통하여 출원된 발명 중 일부만을 특허로 부여하였고, 이 경우에도 특허기간은 3~5년 정도로 비교적 짧은 편이었다. 이렇게 특허권을 제한적으로 부여하는 것이 장기간 행해졌는데, 기술이 뒤쳐진 독일로서는 이것이 최선이라는 사고를 가지고 있었다. 이러한 점 때문에 유럽에서의 반특허 움직임을 독일에서 자연스럽게 받아들일 수 있었다.

독일국민경제회의는 가장 조직적으로 반특허 운동을 전개하였다. 1863년 드레스덴에서 개최된 제6회 대회에서 프린스는 “특허는 발명촉진을 도모하는 것이 아니라 오히려 그 실현을 곤란하게 하기 때문에 대중의 발명의 조속한 이용을 저해하고, 대개 발

공통되는 심각한 과제이었다. 그는 “내가 관계한 제조업은 설탕산업이지만, 거기에는 300~400개의 특허가 있다. 이 400개의 특허권을 어떻게 모두 안다고 생각하십니까? 이것을 어떻게 관리하는지, 이것들의 특허가 무엇과 충돌하고 있는지에 대하여 내가 아는 한, 어떠한 특허도 침해하지 않는다고 믿습시다만...” 라고 말하였다(Janis, M.D., *supra note 8*, p.936).

14) Batzel, V. M., “Legal Monopoly in Liberal England : The Patent Controversy in the Mid-Nineteenth Century”, *Business History*, Vol. 22 No.2, 1980, p.192.

15) 石井 正, 앞의 논문, 29-30頁.

16) 石井 正, 위의 논문, 30-31頁.

명가 자신에게 이익보다는 오히려 불이익을 가져 온다”고 하면서, ‘특허부여는 법적 강제에 의한 독점권의 창설’이라고 하였다.¹⁷⁾ 당시 독일은 영국에서 기술의 대부분을 배우고 있었고, 영국에서 섬유기계를 수입하고 영국의 장인, 기술자를 초빙하여 산업혁명을 추진해왔다. 그만큼 독일 산업계에서는 특허제도로 인해 외국으로부터의 기술 도입이 오히려 저해된다고 생각하였으며, 발명특허는 공공의 복리를 저해한다는 불신이 팽배하였다.

1868년, 국민경제회의기술위원회 위원장인 모자는 “시대에 맞지 않고, 효용보다도 폐해를 가져오는 현재의 특허제도는 즉시 폐지하는 것이 당연하다”고 비스마르크에게 보고하여, 이것을 받아들인 비스마르크와 델브뤼크는 연방 내 특허제도를 재검토하여 구체적으로 그 폐지를 주장해 나가기 시작하였다.¹⁸⁾ 반면, 베르나 지멘스는 독일기술자협회와 함께 특허제도 옹호운동을 전개하였다. 특허법을 폐지하지 않고 개혁함으로써, 유용한 발명은 계속해서 특허로서 보호하고 그 내용을 공개하며, 보호기간 후에는 특허를 공유재산으로 하자는 것이 이들의 주장이었다.¹⁹⁾

독일제국은 프로이센-프랑스 전쟁에서 승리한 후, 1871년 1월 성립하였다. 국민경제의회와 비스마르크는 특허제도에 부정적이었지만, 4월에 선포된 제국헌법의 제2장 제4조에는 발명특허와 저작권의 보호에 대한 내용이 입법으로 규정되었다. 이는 독일제국의 자부심과 영국을 착실하게 따르고 있다는 인식을 배경으로 하였으며, 독일기술자협회와 지멘스의 특허제도 옹호운동의 성과가 그 규정에 반영되어 있었다. 협회와 지멘스는 총9조의 독일제국 특허법안을 작성하여 1872년 6월 의회에 제출하였다.²⁰⁾ 법안 제출의 이듬해에 오스트리아의 빈에서 공업소유권에 관한 국제회의가 개최되었고, 지

17) 大本富夫, 「近代ドイツの特許と企業家活動 - 鐵鋼・電機・ビール経営史研究」, 泉文堂, 2002, 88頁.

18) 大本富夫, 위의 책, 88-92頁.

19) 독일기술자협회(Verein Deutscher Ingenieure)는 1856년 창립한 독일에서의 기술자의 교육제도 충실, 기술자의 사회적 지위향상, 독일의 기술향상 등을 목적으로 설립되었다. 독일 최대의 전기제조기업의 창립자 베르나 지멘스(Ernest Werner von Siemens, 1816-92)도 독일기술자협회에 가입해서 활동했다. 지멘스는 스스로의 경험을 입각해 베를린의 기술자협회에 특허제도 논의에 참가하고, 게다가 1862년에는 하원선거에 의원으로 되어, 당시 특허제도의 문제를 지적하였다. 프로이센의 특허는 명세서가 공개되지 않기 때문에 누가 어떠한 발명을 특허로서 보유하고 있는지도 알지 못하고, 이것에서는 신기술을 기업화한 경우, 너무 위험한 것, 게다가 특허가 된다고 해도 너무 짧은 기간의 특허인 것 등. 지멘스는 프랑스적인 자연법적인 재산권설은 취하지 않고, 확실히 산업정책설에 기초한 특허라고 하는 것을 강조했다. 발명자로서 또 경영자로서 특허제도의 필요성을 주장했다.

20) 大本富夫, 위의 책, 93頁.

멘스도 이 회의에 참석하였다.²¹⁾

다. 네덜란드의 특허제도 폐지

1854년 네덜란드에서는 산업진흥위원회의 보고서가 발표되었다. 동 보고서에서는 네덜란드의 특허제도가 발명의 가치를 고려하지 않고, 신규성만을 고려하는데 지나지 않는다는 점, 특허 기준이 너무나 사소한 것에 좌우된다는 점 등이 지적되었다. 소토펬르는 한 사람에 의해 특허가 결정되는 점이 문제라고 하였고, 이 점을 받아들여 1843년 판텔은 위원회에 의한 특허 가부판단을 제안하였다.²²⁾ 게다가 베이크는 특허내용을 공개하여야 한다는 것과, 외국 특허에 대해서는 그 내용을 도서관에서 공개할 것을 제안하였다.²³⁾

당시 네덜란드의 특허제도에는 예를 들면, 특허기간 중에는 발명이 비밀로 유지되고, 또한 특허명세서가 공보로서 인쇄·발행되지 않는다는 등 많은 문제점이 있는 것이 사실이었다. 또한 네덜란드에는 외국에서 출원되고 네덜란드에서 특허 등록된 발명은 네덜란드에서는 무효가 된다는 제도가 있었으며,²⁴⁾ 그밖에도 명세서와 도면에 대한 규정이 없어서 이를 특허권자 자신에게 유리하게 작성하는 경우도 많았다. 따라서 네덜란드의 특허제도 본질에 대한 문제에 대하여 너무 느슨하다는 점과 반면에 지나치게 엄격하다는 비판과 불만들이 공존하고 있었다.²⁵⁾ 네덜란드 의회에서는 1854년의 산업진흥위원회의 보고서가 발표된 이래, 꾸준히 특허제도의 시비가 논의되어 폐지론이 주장되는 경우가 많았다.

1867년 제11회 위원회에서는 대부분의 의원이 특허제도의 폐지를 주장하고 몇몇의 의원만이 특허제도의 개정을 요구하는데 그쳤다. 이러한 네덜란드 의회에서의 특허폐지론에 대한 논의는 멀리 스위스의 특허제도에 대한 논의에 까지 영향을 미치고 있었다. 스위스의 특허반대론자들은 네덜란드의회에 특허비판 동향을 주시하라고 하였다.

최종적으로 폭크 장관은 특허부여를 정지하는 법안을 제출하였으며, 이는 네덜란드

21) 石井 正, 앞의 논문, 31頁.

22) Doorman, G., "Patent Law in the Netherlands-Suspended in 1869 and Reestablished in 1910-", *Journal of the Patent Office Society*, Vol.30 No.3, 1948, p.236.

23) *Ibid.*, p.236.

24) Lerner, J., "Patent Policy Innovations : A Clinical Examination", *Vanderbild Law Review*, Vol. 53 No.6, 2000, p.1847.

25) Schiff, E., "Industrialization without National Patents : the Netherlands 1869-1912 : Switzerland 1850-1907", *Princeton University Press*, 1971, p.19-20.

특허상황에 따른 결정이었다. 1851년부터 1865년까지 네덜란드의 연평균 특허수는 140건이었고, 그 중 90%가 수입특허였다. 게다가 그 중 97건은 2년 이내에 연차료 납부를 중지하고 있었다.²⁶⁾ 이러한 상황을 요약해보면, 네덜란드에서는 네덜란드인이 직접 발명하는 경우가 적고, 특허권은 이미 외국에 알려져 있어 네덜란드에서 아직 실시되지 않은 발명에 대한 특허의 부여에 지나지 않다는 점, 게다가 그 대부분이 2년 이내 연차료 납부를 중지하고 있는 상황이었다. 이러한 상황에 특허권을 부여하는 것이 의미가 있을지가 의문이었으며, 특허정지법안의 심의에서는 49명이 법안에 찬성하고, 8명만이 법안에 반대하였다.²⁷⁾²⁸⁾

라. 강제실시제도와 대공항

19세기 말 이래, 특허제도에 대한 엄격한 비판은 특허 독점권의 폐해를 지적하는 것이 주를 이루었다. 이러한 폐해를 제도적으로 해결할 수 있을지가 큰 과제였으며, 그 해결책으로서 강제실시허락제도가 제안되었다. 이 제도는 실시되지 않은 특허발명에 대하여 실시하고자 하는 자가 특허권자의 동의를 얻지 않고 강제로 특허를 실시할 수 있도록 하는 제도이다. 베네치아에서는 특허 받은 발명자가 그 발명을 실시하지 않을 경우, 정부의 권한에 의해 그 발명을 이용하는 것이 가능하다.²⁹⁾ 이용이 가능하다는 것은 특허권을 갖는 발명자 이외의 자가 실시하는 것을 허용한다는 것을 의미한다.

중상주의시대 프랑스에서 특허라고 하는 것은 발명보장제도에 근거하였으며, 이는 발명을 실시할 것을 강하게 요구하는 제도였다. 1791년 프랑스 혁명으로 새로운 특허법(자연권으로서의 특허)이 성립하였는데, 이에 대하여 샤프탈(Chaptal, C.)은 이 자연권 사상에 기초하여 특허권을 부여할 경우 개량발명이 배제되는 점을 들어 프랑스 특허법을 비판하였다.³⁰⁾ 기술이 연쇄적으로 발명될 때, 특허를 상호 이용할 수 있는 관계

26) Doorman, G, supra note 22, p.240.

27) Ibid., p.241.

28) 石井 正, 앞의 논문, 31-32頁.

29) 베네치아 특허법의 최종 절에서는 “정부의 판단 결과, 발명자가 그 발명을 실시하지 않은 경우, 발명에 관한 기계·장치의 운영 및 이용하는 것이 가능하다.”고 하였다(Mandich, G. "Venetian Patents", *Journal of the Patent Office Society*, Vol. 30, No. 3, p. 1450-1550, p.171-172). 또 다른 버전의 최종 절에서는 “정부의 권한에 기초해 발명자가 그 발명을 실시하지 않을 경우에 있어서 발명 및 장치가 필요한 자는 그것을 사용하는 것이 가능하다” (Ladas, S.P., "Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection", 1975)고 하였다.

가 되어야 하며, 이것이 발명의 개량과 관계된 강제실시허락제도이다.

미국에서는 연방헌법제정 후, 1790년 특허법의 심의가 행해진 의회상원에서 강제실시허락제도가 검토되었고, 상원은 이를 인정하여 그 내용의 법안을 가결하였다. 하원에서는 그 내용은 거부되었지만, 강제실시허락제도가 현실의 제도로서 다뤄져야 한다는 생각은 가지고 있었다.

또한 유럽 각국에서는 제도적으로 발명의 실시를 강제할 것을 요구하고 있었다. 상품이 국경을 초월하는 시대가 된 19세기 유럽에서는 특허권을 취득하면 반드시 그 특허를 취득한 나라에서 발명이 실시되는 것은 아니고, 단지 특허제품이 수입되는 정도에 그치고 있었다. 각국 정부는 특허권은 그 나라의 시장 확보를 위하여 이용되는 것에 지나지 않는 점을 인식함과 동시에, 그 대책으로서 특허실시 그것 자체 혹은 타인에 대한 강제실시허락제도를 요구하였던 것이다.

러시아에서는 1833년 특허법에 의해 외국인에게 6년간의 특허권을 부여하였지만, 그 중 4분의 1의 기간 동안 그 발명이 실시되지 않으면 그 특허권은 취소된다는 규정이 있었다.³¹⁾ 오스트리아에서는 특허권 취득 후, 1년 간 발명을 실시하지 않을 경우 특허권이 취소된다는 규정이 있었다.

독일은 1815년의 프로이센 특허법의 경험으로부터 이러한 강제실시허락제도와 운용에 익숙하였다. 원래 프로이센에서의 특허권은 영주의 특권부여를 제도적으로 합리화한 것으로서, 玉井克哉는 “프로이센에서도 오스트리아에서도 특권부여는 군주가 공공선을 실현하는 중상주의정책의 수단이었다”고 하였다.³²⁾ 따라서 실시되지 않은 특허는 국가의 필요에 의해 특허권자를 초월하여 사회전체의 이용을 도모해야 한다는 생각이 뿌리 깊게 박혀있었다. 그것은 발명의 실시에 관하여 공공의 이익에 한해 강제실시허락을 확대한 것이다. 특허제도 옹호, 제도개혁운동의 입장에 있는 지멘스도 강제실시허락제도 그것을 특허제도비판에 대한 해결책으로서 생각하고 있었다.³³⁾

30) Penrose, E. T., *The Economics of the International Patent System*, The Johns Hopkins Press, 1951, p.165.

31) Lerner, J., *supra note 24*, p.1849-1850.

32) 玉井克哉, 「特權付与から行政行為への史的発展 - ドイツ特許制度成立過程の一断面」, 行政法の發展と変革 塩野宏先生古稀記念, 有斐閣, 2001頁.

33) 지멘스는 다음과 같이 말한다. “발명자의 권리와 충돌할 때에, 라이선스를 하는 것은 권리자에 의무화하는 것을 생각할지도 모른다. 확실히 그러한 규칙은 절대적으로 필요하다. 독일산업의 관심은 라이선스가 권리의 하나로서 행해질 수 있는 것을 요구하고 있다. 오늘날 산업은 급속하게 발전해가고, 그 결과 발명의 독점과 특허권의 남용은 많은 산업분야에 심각한 타격을 주고 있다. 정부는 그것들의 위험에서 산업을 보호하지 않으면 안된다. 외국에서는 다른 위험이 초래하고 있다. 영국, 미국, 프랑스에서 발명활동은 독일의 그것과 비교

유럽 각국에서 강제실시허락제도의 정착으로 인해 특허 독점권의 폐해에 대한 비판이 점차 약해져 가는 것과 동시에, 특허제도 옹호의 움직임이 일어나기 시작하였다. 무엇보다도 이 강제실시허락제도는 빈의 공업소유권 국제회의의 개최 계기가 되었다.

결정적으로 영향을 준 것이 1873년에 유럽을 습격한 대공황이었다. 물가는 하락하고 이자율은 낮아지는 등 경제는 붕괴되고 있었고, 빈을 중심으로 한 금융공황은 기업의 큰 도산을 초래하였다. 프로이센-프랑스 전쟁에서 얻은 보상금으로 공황 전의 붐을 누린 독일경제는 대략 20년간의 불황에 돌입해 붐 시기에 설립된 기업 858사 중 160사가 도산하였다. 유럽 각국은 그 당시 자유무역방침에서 보호무역정책으로 급속하게 전환하였다. 프랑스에서도 보호무역정책으로의 복귀 논란이 강해졌으며, 독일에서는 공업가와 대지주의 동맹에 의해 1878년 무쇠수입관세철폐정책이 파기되었다. 이탈리아에서는 1887년에 고율보호관세를 채용하고, 오스트리아와 러시아도 1874년과 1877년에 보호정책으로 전환하였다.³⁴⁾

이 대공황은 특허라는 관점에서만 보면 큰 역할을 하였으며, 대공황에서 나온 기업보호의 필요성, 무역에 있어서 권리 및 발명의 보호 등의 여론이 중요하게 인식되었다.³⁵⁾

해서 훨씬 우위에 있다. 오늘날 까지 독일에서 외국인에 의해 취득된 특허권의 수는 적지 않지만, 그것이라고 하는 것도 발명자에 부여된 보호의 범위가 좁은 것이었기 때문이다. 신 제도는 외국인 특허권을 증가시키고 있다. 외국인 특히 미국인의 특허출원의 물결을 경험하고 있다. 이것의 특허는 독일에서 공장건설을 보호하기 위한 것은 아니고 외국에서 제품의 독점을 보호하는 것이다. 이것들은 이 나라에도 도입되게 된다. 이것들의 위험은 피할 수 없다. 외국인 특허권자에 대해서는 독일에서 공장을 건설한다고 하는 증거를 제출시키는 것만으로는 충분하지 않다. 그러한 것은 결국 그 특허권을 유지하기 위한 국내생산을 한다고 하는 것, 단순한 모습과 같은 것에 지나지 않는다. 프랑스는 유효한 무기를 갖고 있다 - 발명자가 특허의 제품을 수입하고, 타자에 수입을 허가하고 있는 경우에는 그 특허권은 무효한 것이라고 한다. 그러나 프랑스 방식은 무역이라는 점에서는 유효하지 않다. 그것에 심각한 반대에도 직면할 것이다. 중요한 특허인 경우 특허권자가 국내에 있어서 필요로 하는 정도에는 생산할 것, 그것이 실제의 생산을 요청하는 것이다. 마찬가지로 특허가 중요할 경우에는 라이선스가 행해질 것이 최선이다. 이 계획에의 관청의 관여는 용이하지 않다. 그러나 관청과 재판소는 곤란에 직면해 잠정협정을 맺을 수 있다. 로열티는 발명의 중요성에 기초해서 결정된다. 미국에서는 침해소송에서 피고가 합리적인 로열티를 제시했음에도 불구하고 라이선스가 거부된 경우, 특허권자는 통상 소송이 각하된 곳으로부터 이러한 강제라이선스의 액이 존재하고 있다.” (Kronstein, H. & Till, I., “Revaluation of the International Patent Convention”, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 12, 1974, p.773-774.)

34) Landes, D. S., “The Unbound Prometheus—Technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present”, 1969. [石坂昭雄・富岡庄一(訳), 「西ヨーロッパ工業史 1」, みすず書房], 1980, 263-264頁.

35) 石井 正, 앞의 논문, 32-33頁.

2. 국제특허제도의 탄생

가. 오스트리아 빈회의

1873년, 오스트리아 빈에서 만국박람회가 개최되었는데, 이 시기에 특허에 관하여 문제가 발생하였다. 당시 오스트리아의 특허법은 강제실시제도를 엄격히 규정하여 특허권을 취득한 후, 1년 간 실시하지 않는 경우에는 그 특허권을 강제적으로 수용하는 규정을 두고 있었다.

각국은 빈 만국박람회에 최신기술의 상품을 출품할 것을 요청받았는데, 그러한 최신기술의 상품을 출품하게 되면 당연히 그 기술이 전시되어 상세히 관찰 및 분석되어 불가피하게 모방의 기회로까지 이어지게 되었다. 특허권을 오스트리아에서 취득하면 발명의 모방은 피할 수 있었지만, 만국박람회에 출품하는 것만으로는 오스트리아에서 특허권을 실시할 의향이 있다는 의미는 아니었다. 따라서 특허를 실시하지 않게 되면 강제 실시제도에 의해 그 특허가 강제 수용되는 문제가 발생하게 되었다. 따라서 오스트리아 정부는 각국의 최신기술상품의 출품을 우선시하여 이 만국박람회에서는 강제실시조항을 적용하지 않도록 예외 조항을 두었다.³⁶⁾ 그러나 그 당시 관계자 모두가 강제실시와 관련된 문제를 보다 기본적으로 해결해야 한다고 인식하고 있었기 때문에 오스트리아 정부는 이를 위해 국제적인 특허의 취급을 검토하는 국제회의의 개최를 결정하였으며, 그 회의에서는 미국의 강력한 권고가 있었다.³⁷⁾

미국은 특허의 국제적 취급을 검토하는 국제회의의 필요성을 지적하며 선도해 갔다. 미국 특허청의 레짓 장관(M. D. Legget)은 5월 29일 국무장관 앞으로 편지를 보내 이 국제회의에서 미국이 리더십을 발휘하는 것에 대한 중요성을 지적하였다.³⁸⁾ 당초 이

36) 빈 만국박람회에 관련해서 미국의 과학잡지 「Scientific American」는 미국인 발명가가 오스트리아 특허제도 하에서는 실질적으로 보호받지 못한다는 것을 기사화 하였다. 이 기사의 내용에 관하여 빈 주재의 미국대사가 오스트리아 외무성 대신에게 질문을 한 것이 문제의 발단이 되었다(Penrose, E. T., *supra note 30*, p.45-46).

37) 실제 만국박람회 사무국의 국제회의 초청장의 내용은 다음과 같았다. “미국정부의 권유도 있어 만국박람회 사무국은 국제회의를 개최하게 된다. 회의에서는 특허에 대한 논의를 하지 않고, 특허권의 찬부에 대해서도 체결되게 되는 것이었다. 그러나 이 회의의 책무는 다양한 각국 나라의 경험을 기초로 하여 여러 재료를 모아 특허등록에 관하여 국제적 개혁을 위한 기본원칙을 선언하는 것으로 되었다.” (Kronstein, H. & Till, I., *supra note 33*, p.766.)

38) 이 편지 중에서 레짓장관은 다음과 같이 말하였다. 빈에서 개최된 특허회의는 매우 중요하며 미국정부의 생각과 논의를 주시하는 것이다. 만약 회의에서 미국 시스템의 사실 및 상황

국제회의의 과제인 특허보호를 점차적으로 확대해갔으며, 또한 이를 국제적으로 공통화하는 것을 염두에 두고 상세하게 검토해 나갔다. 의회 초대장의 내용은 다음과 같다.

1860년 이래 반특허 움직임은 확대되어 가고 있다. 이것은 현 시대의 경제적 진보로 인해 나온 다양한 의견 중 하나이며, 지금까지 문제 일부의 해결에만 머물러 왔던 것이 그 원인이기도 하였다. 이 운동은 발명에 관한 모든 특허를 완전히 폐지하고, 또 현재의 특허법을 유지하면서 간단한 개혁에 의하여 특허가 보호되어야 하며, 이는 국제적인 협정에 기초하여야 한다는 것을 표어로 내걸고 추진되었다. 현재의 특허보호는 스위스와 최근에 특허제도를 폐지한 네덜란드를 제외한 계몽적이고 진보적인 공업국가에서는 특허보호가 필요불가결한 것이라고 인식하고 있다.³⁹⁾

나. 공업소유권에 관한 국제회의

1873년 8월 공업소유권에 관한 국제회의가 개최되었다. 이 회의에는 독일, 오스트리아·헝가리 제국, 영국, 미국 등을 포함한 20개국 150명이 참석하였다. 미국에서는 36명, 영국에서는 15명이 참석하였고, 프로이센-프랑스 전쟁에서 패한 프랑스는 공식적으로는 불참석하였으나, 산업계에서의 출석이 있었던 것으로 보인다.⁴⁰⁾

미국대표는 부장관인 대처(J. M. Thacher)로 그는 장관 레짓에게 다음과 같은 지시를 받았다. 미국의 특허제도를 설명하고 다음 사항에 주목하게 하라.

- ① 신규하고 유익한 발명에 대하여 그 최초 발명자에게 정당하고 효율적으로 특허를 부여할 것
 - ② 신규성을 판단하기 위한 예비적인 공적심사의 중요성
 - ③ 각국 산업에 이익을 준 미국 특허제도의 영향
 - ④ 국민에게 자유로운 정신을 발동시킨 자국의 특허제도
- 이에 추가하여 국가 간의 과제로서 다음 사항을 강조할 것.

- ① 단순한 수입자는 특허를 받을 수 없다.
- ② 어느 나라에 있거나 다른 나라의 국민에게 특허를 부여할 경우, 시간적 혹은 장소적인 제한이 있다. 이것은 특허권을 무가치한 것으로 만들기 때문에 그러한 제한은 피하여야만 한다.⁴¹⁾

이 적절하게 설명된다면 나는 최선의 결과가 얻어질 것이라고 확신한다.” (Kronstein, H. & Till, I., Ibid 33., p.767.)

39) Ibid ., p.767.

40) 石井 正, 앞의 논문, 33-34頁.

의회는 1873년 8월 4일에서 8월말까지 9회 개최되었다. 이 의회는 미국과 영국이 주도하였으며, 경제학자와 법학자에게도 자유로운 발언권이 인정되어 실제 자유롭고 다양한 의견을 가진 자에게 열려 있는 회의였다. 예를 들면 학자 중에는 독점배타권인 특허권의 부여 없이 오히려 국가의 보상금 지급만으로, 국민이 발명을 자유롭게 이용할 수 있게 하여야 한다는 주장도 있었다.⁴²⁾ 그러나 의회의 진행과 함께 회의 참가자들에게 공통된 특허 존재 형식이 형성되었으며 실제로 뒤에서 보는 결의의 대부분이 만장일치로 결정되었다. 그러나 단지 특허의 강제 실시권에 관한 규정만은 격렬한 의견대립이 있었고, 이는 투표에 의해 결정되었다. 150명 중 많은 투표자가 기권하여 찬성 42명, 반대 17명이었고, 이 결과는 제2결의 중에 포함되었다.⁴³⁾ 이 회의의 결과로서 제3결의가 채택되었다. 이 결의의 내용에서는 회의참석자들의 특허에 관한 공통된 인식을 볼 수 있다.⁴⁴⁾

제1의 결의에는 모든 문명국에서 지적인 노동법적인 보호를 구할 것, 발명을 명세서로서 공개하는 것이 기술과 산업의 발전에 있어 유익하다는 것, 노하우 등을 비밀로 해 둘 필요가 없어지는 것, 특허의 법적보호는 발명자 자신이 완성한 발명을 가치 있는 것으로 만듦으로 인해 발명자에게 자금이 유입되는 것 등의 이유로 하여 각 문명국은 입법으로서 발명의 보호를 보장할 것을 권고한다.

제2의 결의에는 발명자 및 승계인만이 특허를 취득할 수 있도록 할 것, 외국 발명자의 특허 취득을 거부하지 않을 것, 특허의 기간을 15년으로 할 것, 특허 연금을 누진적으로 증가시켜 실시하지 않는 발명에 대해서는 사회에서 조속히 이용할 수 있게 하는 제도가 추진될 것, 실시하지 않는 발명에 대해 특허의 소멸을 초래하지 않을 것 등을 권고한다.⁴⁵⁾

41) Kronstein, H. & Till. I., *supra* note 33, p.769.

42) 마ーキュ아·E. R., 「1873年ウィーン國際特許會議」, 知的財産法の系譜 小野昌延古稀記念論文集, 青林書院, 2002, 247-248頁.

43) 마ーキュ아·E. R., 위의 책, 248頁.

44) 石井 正, 앞의 논문, 32-33頁.

45) <제2 결의> 국제적 특허의 보호의 기본원칙으로서 효과적이고 유용한 특허입법은 다음과 같이 기초를 다져야 하는 것이다.

- (a) 발명자 자신 또는 전자의 승계인만 특허를 취득할 수 있을 것.
- (b) 외국의 발명자에 특허의 취득을 거부해서는 안된다.
- (c) 이상을 고려해서 예비심사를 행할 것을 필요로 한다.
- (d) 발명에 대한 특허의 유효기간을 15년간 혹은 전체로서 15년간까지 연장할 수 있다.
- (e) 특허의 부여는 완전한 발명이 기술상의 적용이 가능한 때에 공시한다.
- (f) 특허의 부여는 적절한 비용과 누진부과제도의 채용에 의한다

제3의 결의는 특허보호의 국제적 협정의 형성을 각국 정부에 권고한다는 것이다. 회의는 시작부터 끝까지 미국의 주도 하에 진행되었으며, 당시 미국대표였던 대저 미국특허청 부장관은 다음과 같이 본국에 보고하였다. “일반적이고 보편적으로 말할 수 있다고 생각하는 빈 회의에서의 주장, 즉 각국에 있어서 기계기술의 진보를 확보하고 그들의 숙련된 기술자의 이주를 방지하자는 의견들은 유럽 특허제도 개혁의 필요성을 보여주고 있다”고 하였다.

오스트리아의 안도랏시 수상은 상설위원회의 인터뷰에서 다음과 같이 발언하였다.

“나는 영국과 미국에 주목한다. 이들 나라는 제조업에 있어서 가장 진보한 나라이며, 또 그들의 법제도를 자세히 살펴보면 세계 최고의 특허제도를 갖고 있다. 이 사실들을 종합해 볼 때, 그들의 법제도와 다른 오스트리아의 특허법을 개혁하여 개정할 것을 주장한다.⁴⁶⁾” 이 회의는 미국의 승리였고, 당초의 목적 대부분을 실현하였다. 실제 회의에서는 영국, 미국, 벨기에의 특허법이 추천되어 이것에 따른 독일 기술자협회(VDI)가 준비한 특허법 초안이 제안되었다. 이 독일 기술자협회의 특허법 초안은 비스마르크가 반대한 내용이었지만, 의회에서는 반대로 이 내용이 추천되어 평가되는 등 긍정적으로 다루어졌다. 이는 지멘스의 노력의 성과이기도 하였다.

다. 독일의 특허법의 탄생

빈에서의 국제회의는 독일로부터 큰 영향을 받았다. 회의의 다음해에 지멘스는 독일 기술자협회와는 별개로 독일특허보호연맹(Patentschutzverein)⁴⁷⁾을 결성하여 의장이 되었다. 지멘스는 특허보호연맹 내에 위원회를 결성하여 위원회에서의 검토결과에 따라

-
- (g) 능률적으로 조직되어 있는 특허청을 통해서 누구라도 각 특허의 명세서를 입수하는 것을 용이하게 해야 한다. 또한 이른바 특허의 유효성을 용이하게 판별할 수 있어야 한다.
 - (h) 특허된 발명이 문제가 된 나라에서 발명을 실시하지 않은 것은 특허의 소멸을 일으키지 않는 것으로 한다. 단지 특허된 발명이 적지 않게 다른 나라에서 실시된 경우가 아니면 본국의 국민에게 해당발명을 취득시키고, 실시하는 것이 가능하지 않는 경우에만 예외로 한다.
 - (i) 게다가 본 회의는 공익상 요구에 있어서 특허보유자는 자기의 발명을 상당한 보수를 받는다는 조건 아래에서 각각의 신청인이 해당 특허를 공동 이용하는 것이 가능하다는 법규를 작성할 것을 권고한다. 특히 특허의 부여에 관한 절차에 대하여 본 회의는 영국·미국 및 벨기에의 특허법을 참조한 것을 칭찬하였다. 그밖에 연맹에 의한 독일의 특허법안을 주목할 것을 지적한다(マークス・E. R., 앞의 책, 251-253頁).

46) Kronstein, H. & Till. I., *supra* note 33, p.769.

47) 독일특허보호연맹은 지멘스를 중심으로 하여, 독일 각지의 유력 기업가로 하여금 특허제도를 적극적으로 지지할 것을 주장하며 조직한 것으로, 1874년 5월에 발족한 이사회는 공업경영자가 10인, 대학교수가 6인, 법률가가 3인으로 기술자는 단 한명도 없었다.

새로운 특허법 초안을 작성하였다. 그 초안이 1876년 2월 의회에 제출되었다.⁴⁸⁾

지멘스의 주장과 특허보호연맹의 의견을 종합한 특허법 초안의 핵심내용은 다음과 같다.

- ① 특허 보호대상을 제한한다.
- ② 기술전문가에 의한 발명의 심사 및 심사결과를 공고함으로써 이의신청을 가능하게 한다.
- ③ 특허 연금은 누진제로서 일정기간 이상 고액의 특허료를 부과한다.
- ④ 강제실시허락제도를 도입하여 이를 허락하지 않을 경우에는 특허가 취소된다.
- ⑤ 소발명을 위한 실용신안제도를 도입한다.

1876년 8월에는 의회에서 특허법 청문회가 열리고 11월에는 정부의 특허법 개정준비안이 공표되었는데, 이것은 지멘스가 책정한 연맹안과 내용이 거의 동일하였다. 따라서 이것이 그대로 다음해에 독일의 특허법이 되었다. 그때까지는 프로이센에서 실시해온 엄격한 특허심사의 경험을 활용하였고, 영국에서 19세기 초부터 말까지의 특허제도 개혁의 움직임, 특히 특허명세서의 필요성과 더불어 특허 심사와 특허권리범위를 확정하는 것, 또한 명세서가 널리 공개될 것 등이 모두 포함되어 있었다. 또한 미국의 1832년 특허법도 크게 참고 되었다.

그때까지도 특허된 발명은 실시할 것이 요구되어졌지만, 독일 특허법에서는 그것이 보다 명확하게 법제화되었다. 강제실시허락제도(제11조)가 그것이며,⁴⁹⁾ 이는 발명을 실시하지 않을 경우에 특허권이 취소될 것, 혹은 공공의 이익을 위하여 타자에게 특허권의 실시를 허락해 줄 것을 강제한 규정이다. 이 강제실시허락제도는 지멘스가 결성한 독일 특허보호연맹내부에서도 비판이 많았지만, 특히 기술자협회(VDI)의 비판이 심했다. 그러나 반대로 지멘스는 강제실시허락규정이 없으면 독일에서 통일된 특허제도가 될 수 없다는 확신을 갖고 있었다.

48) 당초 1874년 10월경에 연맹내부에서 독자적인 특허법안의 작성을 위한 검토가 이루어져, 연말에 초안이 완성되고, 바로 다음 해 1월 의회에 제출되었다. 그러나 연맹 내부에서는 이 의회에 제출된 연맹초안에 대한 비판이 있었다. 특히 강제실시에 관한 부분에 대해서는 기술자협회(VDI)의 비판이 있었으며, 심지어 그들 중에는 연맹을 탈퇴하는 사람도 있었다. 따라서 그 후 연맹에서 수정작업이 행하여졌고, 11월 임시총회에서 새로운 초안이 개정되었다. 이를 검토하여 이사회가 최종 초안을 작성하여 이것이 다음해 1876년 2월 의회에 제출된 것이다(大本富夫, 앞의 책, 109-110頁).

49) “특허권자가 그 발명을 국내에서 실시하거나 또는 실시를 확실하기 위하여 필요한 일정한 조치를 취하는 것을 게을리할 경우, …… 혹은 공공의 이익을 위하여 …… 필요하다고 생각할 수 있는 것임에도 불구하고, 특허권자가 상당한 보상금 및 충분한 담보에 대해서도 허가해 주는 것을 거절하는 경우에는, ……3년경과 후에 삭제될 수 있다.” (大本富夫, 위의 책, 112頁의 해석에 의한다)

이에 더하여 사전심사하고, 특허여부의 결과를 공고하여 이의신청의 기회를 부여한 공고·이의제도로써 부여받은 특허에 대하여 신중한 의견을 구하는 제도를 도입하였다. 또한 심판제도까지 만들었으며, 특허연금을 누진시켜 나가서 최후에는 고액의 연금을 지급하도록 하는 제도도 만들었다. 이들 사이에는 독일 내의 반특허 주장에 대하여 특허권자의 부담 증가라는 반응도 있었고, 또한 1815년 특허법에서 기관의 엄격한 심사로 인해 특허기간을 짧게 설정하자는 의견도 있었다.

전형적인 부분은 실용신안제도로, 소발명에 실용신안등록이라는 권리를 부여한다고 하였지만, 그때까지도 독일은 영국과 미국에 비해 뒤쳐져 있었다. 따라서 소발명을 위한 실용신안제도의 도입은 영국과 미국과 같이 훌륭한 발명을 창출할 수 있다고는 해석하지 않지만, 그러한 정도의 기술적 진보 없이 약간의 개량을 한 것과 같은 소발명도 보호하자는 발상으로 제안되었다.

라. 파리조약이라고 하는 국제특허제도

1878년 파리에서 만국박람회가 개최된 해에 다시 파리에서 공업소유권에 관한 국제회의가 개최되어 500여명이 참석하였다. 공업소유권에 관해서 내국민대우를 인정할 것, 국제박람회에 출품된 것에 관한 발명은 보호될 것, 각국에 있어서 특허는 독립한 것으로 할 것 등이 확인되었다. 그러나 당초의 목표였던 통일 공업소유권법의 작성이 곤란하다는 것이 점차 명백해졌다. 이와 같은 인식 위에 조약 작성에 관한 상설위원회가 설치되어, 프랑스를 중심으로 특히 자자에르슈미가 내국민대우와 우선권제도를 기본으로 한 초안을 작성하였고,⁵⁰⁾ 이를 프랑스 정부안으로서 제시하였다. 이것을 받아들인 위원회는 1879년 동맹조약초안을 작성하여 각국에 송부하였다.

1880년에는 각국에 송부된 조약 초안을 검토하는 국제회의가 파리에서 개최되고, 3년 후 파리에서 개최된 조약회의에는 미국, 영국 등 21개국이 참가하고 11개국의 서명하여 “공업소유권보호에 관한 1883년 3월 20일 파리동맹조약”이 시작되었다.

파리조약의 몇 개의 기본 원칙과 이에 더해 어떠한 논의가 있었는지도 살펴본다.

우선 내국민대우의 원칙이 있다. 이것은 동맹국에 있어서 다른 동맹국의 국민을 자국의 국민과 동일한 대우를 해주어야 한다는 것으로, 이것에 의해 국내 발명자와 외국 발명자는 평등하게 취급되어 특허권 등 공업소유권을 동일하게 누릴 수 있게 된다.⁵¹⁾

50) Penrose, E. T., supra note 30, p.54-55.

51) 파리조약 제2조: (1) 각 동맹국의 국민은 공업소유권의 보호에 관하여 이 조약에서 특별히 정한 권리를 해쳐서는 안되고, 다른 모든 동맹국에 대하여 해당 다른 동맹국의 법령이 내국

국제적인 관계에 있어서는 내국민대우원칙 외에 상호주의원칙을 채용하는 것도 가능하며, 실제 파리조약 회의에서는 이 문제가 논의되었다. 네덜란드와 스위스에서는 특허 제도가 없는 한 그 나라의 국민은 특허를 취득할 수 없고, 외국인 또한 특허를 취득할 수 없다. 그러한 한도에서 내국민대우원칙을 따르고 있었으나, 네덜란드와 스위스의 국민은 미국과 영국에서 특허를 취득하는 것이 가능하였다. 결과적으로 이들은 분균형하며, 복수의 나라 간 규칙을 정할 때에도 본질적인 문제가 된다. 내국민대우원칙을 채택할지 상호주의원칙을 채택할지는 전체로서 또는 부분적으로 어느 한 원칙을 채택하는 경우도 있다.

미국은 이 파리조약 때부터 항상 상호주의원칙을 주장해 왔었다. 예를 들면 파리조약에 관한 브뤼셀 회의에서도 미국은 요금, 연금과 게다가 특허판단기준까지도 상대국에 적용할 수 있다고 주장하였으며, 이러한 미국의 주장은 1925년의 헤이그 회의에서도 반복해서 나타났다.⁵²⁾

다음으로 우선권제도가 있다. 이는 조약 동맹국인 1개의 나라에서 한 최초의 출원에 의거하여 일정 기간 내(특허는 12개월, 의장·상표는 6개월)에 한 제2국에서의 출원은 신규성과 선후 출원에 대하여 제1국에서의 출원일로 소급적용하는 제도이다. 이것에 의해 통신에 대하여도 국경을 두고 기간을 요하는 외국에서 불이익을 받는 일 없이 출원하여 권리를 얻을 수 있다.⁵³⁾

우선권의 기간을 당초 6개월이라고 한 제안을 1년간으로 한 것이다. 이는 물론 외국에서의 절차적인 문제도 있었지만, 실제 외국에서 특허출원을 한 경우에는 고액의 비용이 요구되고 그 비용을 들여서까지 외국에서 특허를 취득할 필요가 있는지를 판단하기에는 일정한 기간이 요구된다는 것이 그 배경에 있었다. 이를 주장한 것은 스웨덴의

민에 대해 현재 부여하고 또는 장래에 부여할 이익을 누리게 된다. 즉 동맹국의 국민은 내국민에게 부여한 조건 및 절차에 따라 내국민과 동일한 보호를 받고, 또 권리의 침해에 대해서도 내국민과 동일한 법률상의 구제를 받는다.

52) 1925년 헤이그 회의에서 미국은 다음과 같은 개정내용을 제2조에 넣을 것을 요구하였다.

‘각국은 다른 나라의 국민에 대하여 각각의 나라에서 요구하고 있는 공업소유권에 관한 모든 조건을 해당국에 강제하는 권한을 갖는다. 이것은 확실한 상호주의의 표현이며, 다른 나라에서 미국 국민이 불합리한 조건을 강요받고 있는 경우에는 미국도 해당국의 국민이 미국에서 한 특허출원에 대하여 같은 조건을 부과한다는 것이다. 미국은 이와 같은 상호주의의 주장을 반복하였지만 동맹에서 모두 부결되었다(Penrose, E. T., *supra* note 30, p.64-66).

53) 파리조약 제4조 A (1) 몇 개의 동맹국에서 세기에 특허출원 혹은 실용신안, 의장 혹은 상표의 등록출원을 한 자 또는 그 승계인은 다른 동맹국에서 출원을 하는 것과 관계하여 이하에서 정한 기간 중 우선권을 갖는다. C (1) A (1) 에 규정한 우선 기간은 특허 및 실용신안에 대해서는 12개월, 의장 및 상표에 대해서는 6개월이다.

대표였고, 이러한 주장은 실제 상황을 절적하게 이해한 것이라고 말할 수 있다.

더 나아가 각국 특허독립원칙이 있다. 이것은 동맹국에서 취득한 특허는 다른 국가에서 취득한 특허로부터 독립해 있다는 원칙으로, 여기에서 독립의 의미는 특허요건과 권리기간 등에 관하여 다른 나라와의 관계에 종속되지 않는다는 것을 말한다. 예를 들어 어느 발명이 다른 나라에서 특허되지 않는다고 하여 해당국에서도 그대로 특허되지 않는 것은 아니라는 것이다.⁵⁴⁾

회의에서 이 각국 특허독립원칙에 대해 검토할 때 문제된 것은 특허제품의 수입문제였다. 동일한 특허권자가 별개의 나라에서 특허를 취득하고 각국에서 제품을 제조하여 해당국에 수입할 때, 그것을 어떻게 취급할 것인가가 문제되었다. 해당국에서도 특허를 취득하고 있는 경우에는 아무런 문제가 되지 않는데, 이것을 파리조약에서 확인적으로 규정하고 있다.⁵⁵⁾

그런데 이 규정에 관하여 프랑스의 강한 반대가 있었다. 프랑스 특허법에는 특허된 제품이 수입될 때에 그 특허권은 효력을 잃는다는 취지의 규정이 아직 존재하고 있었기 때문이다. 따라서 프랑스는 당초 회의 때마다 이 조항의 개정을 요구하였지만, 결국은 동의를 얻지 못하였다.⁵⁶⁾

마. 파리조약에 있어서 강제실시허락

이러한 파리조약 제3원칙 외에 나아가 중요한 논의가 별도로 있었다. 그것은 강제실시허락제도로, 이미 빈 회의에서 제2결의의 (h) 와 (i)항에서 강제실시허락에 관한 결의를 정리하고 있었다.

즉 특허된 발명이 문제된 나라에서 (h)항 - 실시하지 않은 발명에 대해 특허의 소멸을 일으키지 않을 것, (i)항 - 특허보유자는 자신의 발명을 상당한 보수지급이라는 요건 아래에서 신청인이 개별 당해 특허를 공동으로 이용할 수 있다는 법규를 작성할 것을 권고한다는 것이었다.

이 논의들은 최종적으로 파리조약 제5조 A (2) 이하에 규정되었다.⁵⁷⁾ 여기에서는 요

54) 파리조약 제4조의 2(1) 동맹국의 국민이 각 동맹국에서 출원한 특허는 다른 나라(동맹국에 있는지를 문제 삼지 않는다)에서의 동일한 발명에 대하여 취득한 특허와는 독립된 것이다.

55) 파리조약 제5조 A(1) 특허는 그 특허를 취득한 나라에 몇 개의 동맹국에서 제조된 그 특허에 관한 물건을 수입한 경우에도 효력을 잃지 않는다.

56) 石井 正, 앞의 논문, 35-36頁.

57) 파리조약 제5조 A(2) 각 동맹국은 특허에 기초한 독점배타권의 행사로 인하여 생긴 폐해, 예를 들면 특허가 실시되지 않을 것을 방지하기 위한 강제실시를 법으로 규정할 수 있다.

컨대 동맹 각국은 특허가 실시되지 않는다는 폐해를 방지하기 위한 입법조치를 취할 것, 이 입법조치에서는 특허실시허락의 강제적 설정 또한 불충분한 경우에 한하여 특허권의 효력 상실이 가능하다는 것, 강제적 실시권 설정을 행할 수 있는 조건, 특허권의 효력을 잃는 조건 등을 규정하고 있다.

이 강제실시허락에 관한 규정은 1873년의 빈 회의와 1878년, 1880년에 각각 개최된 조약검토회의에서 항상 논의의 대상이 되었다. 1873년의 빈 회의에서는 그 결의에서와 같이 강제실시규정의 필요성에 대한 합의는 형성되었지만, 반면에 1878년의 회의에서는 부정적인 의견이 나왔다. 또한 1880년의 조약 초안에 관한 회의에서는 벨기에, 영국, 러시아, 터키가 반대하였으며, 이들 국가들은 동맹의 목적과 맞지 않는다는 것을 반대 이유로 내세웠다. 그러나 이 시기에는 이러한 강제실시허락규정이 필요하다는 견해가 주를 이루었으며, 특히 스위스는 강제실시허락규정을 강하게 요구하고 있었다.

파리조약은 현행 제5조 A (2) 이하의 내용에 맞춰진 것이었지만, 그 후 개정회의 때마다 그 내용의 개정이 요구되었다. 당초에는 각국도 다양한 경우에 따라 혹은 이론적 사고방식에 따라 강제실시허락제도에 대한 찬반의견을 표명하고 있었다. 그러나 차후에 그 본질적인 의미를 이해하고 나아가 각국 산업혁명의 진행상황과 국제경쟁력 등을 고려하여, 각국의 국익을 명확히 의식한 주장이 나오게 되었다.

그 중심에는 미국이 있었으며, 미국은 이 강제실시허락 국제제도의 주장에 상호주의 원칙을 더하여 주장하였고, 또한 1911년 워싱턴조약개정회의에서는 독일과 함께 강제실시허락규정 자체의 폐지를 주장하였다. 한편, 독일은 역사적으로는 오히려 특허권의 강제실시에 강한 관심을 갖고 있었다. 17세기·18세기 특권부여의 시대와 나아가 19세기 특허제도에 있어서도 특허권의 실시를 강하게 요구하였다. 또 19세기 말 통일 특허법을 성립시킨 때에도 이 강제실시제도에 대한 독일 내의 이해를 얻어온 과정이 있었음에도 불구하고 1911년 워싱턴 조약 개정회의에서는 미국과 함께 독일이 강제실시의 규정을 폐지하자는 주장을 하였다. 그 배경에는 독일 화학산업이 강력하게 추진하고 있던 화학의 국제특허 카르텔이 존재하고 있었기 때문에, 그 점에서 독일은 미국의 주장을 따른 것으로 보인다.

1925년 헤이그 회의에서는 이 강제실시허락규정이 폐지되기 직전까지 논의가 진행되었으며, 단 반대한 나라는 일본, 폴란드, 유고슬라비아 3국이었다. 폴란드 주장은 다음과 같다. ‘유럽의 강한 나라들과 비교해서 개발이 늦은 각각의 나라 상황에 있어서 실시 의무규정을 억제한다는 것에는 동의할 수 없다. 폴란드는 국내생산을 보호하지 않으면 안되기 때문에 산업개발을 확실하게 추진하여야 한다. 따라서 특허 보호 아래, 수입 제품에 의하여 국내 산업이 질식되는 것에는 동의할 수 없다’⁵⁸⁾고 주장하였다.

파리조약에 있어서 강제실시허락규정의 개정 움직임은 항상 있었지만, 결국은 개정되지 않고 오늘날에 이르게 되었다. 오히려 TRIPs 협정(무역관련 지적재산권에 관한 협정)의 제31조에서 강제실시허락제도를 보다 명확하고 폭넓게 규정하고 있었다.⁵⁹⁾

II. 우리나라에서의 특허제도의 성립과 변천

1. 서언

세계 최초의 특허제도는 1824년에 영국에서 제정된 특허법(Statute of Monopolies)의 실시이다. 우리나라는 20세기 초에 특허제도의 실시를 보게 되었으니 불과 100여 년의 역사에 지나지 않는다. 그러나 1900년대의 70년 동안은 정치적으로나 경제적으로나 미증유의 격변을 거듭해온 변천의 역사로 이루어졌다고 할 수 있다. 그것은 산업재산권법의 발전에 있어서도 같은 영향을 미쳤다.⁶⁰⁾

특허제도의 도입에 대한 단순한 시기의 고찰보다는 제도의 도입 당시의 시대상황과 현대적인 특허제도의 정립까지의 변천과정을 고찰함으로써 우리나라 특허제도의 이해를 한층 두텁게 할 것이다. 시대적 배경을 중심으로 하되 크게 구한말에서 일제식민지시대까지, 미군정시대, 정부수립 후, 독자적인 특허법의 제정 및 발전으로 나누어 살펴보기로 한다.

2. 특허법 제정 전의 우리나라의 특허제도

가. 구한말에서 일제식민지시대까지(여명기)

소위 우리나라 특허제도의 도입기로 볼 수 있는 구한말 이후의 우리나라 특허제도는 최초의 공식적인 제시로 볼 수 있는 지식영의 시무소(1882년)에서 우리나라에서의 특허제도의 필요성이 주장되었지만 이러한 자주적인 각성이 뿌리내리기도 전에 청일전쟁과 러일전쟁에서 승리한 일본에 의해서 좌절되었다.

구한말 이후의 우리나라의 특허제도는 국민의 기술적 창작물을 보호함으로써 산업발

58) Penrose, E. T., *supra* note 30, p.84.

59) 石井 正, 앞의 논문, 36-37頁.

60) 이수웅, 「특허법」, 한국교육문화원, 2006, 26면.

달을 촉진시키고자 하는 국민적 합의가 기초가 되어 만들어진 것이 아니라 열강에 의한 시장지배의 일환으로 외국의 산업재산권을 보호할 필요에서 제정된 것이다. 그 구체적인 근거는 청일전쟁과 러일전쟁에서 승리한 일본이 우리나라를 지배하게 되자 미국이 한국 내에서의 자국의 특허권 보호를 요구하여 최초로 체결된 1908년 8월 12일 한국에 있어서 발명·의장·상표 및 저작권에 관한 한일조약(韓日條約)이다.⁶¹⁾ 이 조약에 의해 1908년 8월 12일 한국특허령(칙령 제196호)이 공포되어 동년 8월 16일부터 시행되었다. 이에 의거하여 약 2년간 특허행정이 실시되었는데 특허 제1호로 발명특허를 허여한 것이 정인호 씨의 「말총모자」이다.

그러나 곧 일제의 침략이 있어서 1910년 8월 29일 이른바 한일합병이 되자 한국특허령은 폐지되고 그 대신 일본의 특허법·디자인보호법·실용신안법이 한국에서 시행되었으며, 특허행정도 일본의 중앙기관에서 흡수하여 일괄 취급하기에 이르렀다. 이로 인해 한국인의 발명의욕이 크게 저하되었으며 우리나라 고유의 산업재산권법의 발전을 기대할 수 없게 되었다.

나. 미군정시대

8·15 해방 후 미군정 초기에는 잠정적으로 일제시대의 특허제도가 그대로 답습되었으나 8·15 해방 이후 독립국가로서의 특허제도 필요성이 대두되자 미군정청은 1946년 1월 12일 임시조치인 미군정청령 제44호를 공포하였다.⁶²⁾

1946년 1월 12일자로 공포된 군정법령 제44호는 특허권·실용신안권·디자인권·상표권 및 저작권 등의 지능적 소산인 무체재산권에 관한 사무를 관장하기 위하여 특허원을 창설하고, 특허법 제정을 위하여 기초에 착수하는 한편, 1946년 1월 28일자로 특허원장령 제1호에 의하여 특허보호원제도를 채택하였다.⁶³⁾

특허원이 창설된 후 1946년 10월 5일에 군정법령 제91호로 특허법이 제정 공포되고, 동 일자로 특허법 시행규칙도 공포되었다. 이에 따라 특허국이 발족되었으며, 한편 일제시대에 유효하게 성립한 특허권·실용신안권·디자인권에 대하여는 신평특허법에 의하여 그 권리의 존속을 인정하지 않고 과거에 취득한 권리자라도 일정한 기간 내에 재출원하도록 하되 특허등록여부의 구비여부를 심사함이 없이 무조건 우선적으로 특허하도록 하였다.

61) 황중환, 「특허법」, 한빛지적소유권센터, 2001, 11면.

62) 이종일, 「특허법」, 한빛지적소유권센터, 1996, 79면.

63) 이수웅, 앞의 책, 27면.

미군정에 의한 제도창설로 1946년 특허법은 미국의 특허법이 크게 영향을 미쳐 특허법 내에 발명특허·실용신안 및 의장특허를 모두 포함시켰으며, 식물특허제도의 도입과 아울러 발명특허권의 존속기간을 미국과 같이 17년으로 하였다. 그러나 강제실시권제도의 도입 및 의약품질 또는 그 제조방법 등을 불특허사유로 규정한 것 등에 대해서는 긍정적인 평가가 될 수 있을 것이다.⁶⁴⁾

다. 정부수립 후의 특허제도

대한민국 정부가 수립됨에 따라 정부조직법에 의거하여 특허국에서 취급하던 저작권에 관한 사항은 공보실 소관으로 이관되었다. 1946년 5월 23일 대통령령 제119호로 특허국 직제가 공포 시행됨에 따라 국장·심사장 이외에 4과를 두게 되었으며, 이 때 비로소 실용신안법·디자인보호법·상표법 등이 특허법으로부터 분리되어 단행법으로 각각 제정되기에 이르렀다.

즉, 당시의 특허법은 군정법령으로서 장기간 적용할 수도 없었거니와 그 내용에 있어서도 모순과 비현실적인 점이 많았었고 또한 실용신안과 디자인고안은 기술사상에 있어서 발명과는 정도의 차이가 현저함으로 법적 처우도 달리하여야 할 것이므로 새로 특허법을 제정하기로 함과 동시에 실용신안과 디자인고안에 대하여는 별도로 이를 규율할 법을 제정하고자 장기간 심의를 거듭한 결과, 이의 3개 법안을 완성하여 1959년 2월에 법제실에 회부된 상태에서 1961년 5월 16일 군사혁명이 발생하여 중지되었다.⁶⁵⁾

3. 독자적인 대한민국 특허법의 제정 및 발전

가. 1960 ~ 1980년대

1961년 특허법은 군사혁명정부가 혁명사업의 하나로서 구제도의 청산과 우리나라 근대화 작업의 일환으로서의 구법 정비에 취지를 두고 제정되었다. 1970년대에는 1970년대에는 특허출원에 대한 심사·심판 기능의 엄정을 기하도록 하고 권리의 남용을 방지함으로써 기업의 자유로운 활동을 저해하는 특허제도의 부작용을 제거하며, 새롭고 유용한 발명에 대하여는 이를 강력히 보호하여 국가산업 발전에 기여함과 동시에 일본과의 공업소유권상호보호협정의 체결을 앞두고 근대적 법체제를 갖추기 위하여 전문 개정(1973. 2. 8, 법률 제505호)을 하였다.⁶⁶⁾

64) 황중환, 앞의 책, 12면.

65) 이수웅, 앞의 책, 27면.

1980년 5월 1일 파리 조약의 가입에 따른 개정에서는 파리협약의 동맹국 공통규정사항을 법제화하고 특허청구범위 기재방법의 다항제, 출원공개제도 및 심사청구제도를 도입하는 한편 중전법 중 운영상 일부 불합리한 점을 개선하고 미비사항을 보완하였다.

1986년에는 미국의 통상압력에 따라 물질특허제도의 도입을 결정하고, 동 개정에서는 물질특허제도를 인정하는 등 특허 받을 수 있는 발명의 보호범위를 넓히고, 특허발명이 성실하게 실시되도록 하기 위하여 통상실시권의 허여제도를 개선하며, 출원 중인 발명을 신속히 권리화하고 거절사정에 불복하는 항고심판을 원활하게 처리하기 위하여 심사전치제도를 도입함과 아울러 당시 규정의 시행상 나타난 미비점을 정비·보완하였다.

나. 1990 ~ 2000년 대

1990년대에 들어서 국내우선권제도 도입 등에 따른 개정이 있었다. 이 개정(1990. 1. 13, 법률 제4207호)에서는 특허보호대상을 확대하여 국내우선권제도를 도입하여 발명자 및 권리자의 권익보호를 강화하였으며, 일부 불합리하거나 미비한 점을 개선·보완하였다. 이 후, 특허청 내의 항고심판소와 심판소를 통합하여 특허심판원을 설치함으로써 특허심판의 독립성과 전문성을 확보하는 한편, 특허심판원 심결에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 하고 이에 대한 불복은 대법원에 상고할 수 있도록 하는 심판제도 개혁을 위한 개정(1995. 1. 5, 법률 제892호)이 있었다. 또한 등록전 이의신청제도를 폐지하고 등록 후 이의신청제도로 전환하는 것을 골자로 하는 일부개정(1997. 4. 10, 법률 제329호)이 이루어졌고, 후에 전자서면제도 및 전자출원에 관한 규정을 신설하였고, 실용신안등록제도가 도입됨에 따라 특허·실용신안간의 출원변경제도를 폐지하고 이중출원제도를 새로이 채택하는 개정(1998. 9. 23, 법률 제5576호)이 있었다.

2000년대 들어와서는 보정제도의 개선 등에 따른 일부개정(2001. 2. 3, 법률 제6411호)과, 이의신청, 무효심판제도 통합 등에 따른 일부개정(2006. 3. 3, 법률 제871호), 특허청구범위 기재유예제도 도입 등에 따라 특허출원 명세서의 작성시 발명의 설명에 관한 기재요건을 완화하고, 특허출원인이 보호받고자 하는 특허출원서의 특허청구범위에 대하여 특허출원 후 출원공개 전까지 충분한 시간을 가지고 기재할 수 있도록 하였다. 2009년에는 국제공개어에 관한 특례 규정을 정비하고, 거절결정에 대하여 재심사청구제도를 도입(2009. 1. 30 법률 제9381호)하였다. 또한 세계무역기구(WTO) 무역관련 지적재산권 협정(TRIPs)에 비해 엄격하게 제한하여 규정하고 있는 현행 특허발명의 정부 실시 관련 규정을 동 협정에 맞추어 개정(2010. 1. 27, 법률 제9985호)하였다.⁶⁷⁾

66) 국회의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/jsp/main.jsp> 참조.

제3절 소결

특허제도의 발전 배경 및 연혁적 흐름을 살펴보건대, 특허법에 의해 정보에 독점적 이익을 인정하는 것은 순기능적 측면이 역기능적 측면보다 크다고 하는 실증적 증명은 어렵다고 할 수 있다. 하지만 특허법을 비롯한 지재법은 독점에 의한 창작 등에 따른 인센티브를 부여하는 방식이 경제발전·문화발전에 도움이 된다고 하는 정책적 판단에 따르고 있다. 이 문제에 대해서는 미국을 중심으로 지재법의 경제분석도 이루어지고 있으나 반드시 이렇다 할 정설은 없는 것 같다. 지재법의 범위는 아주 넓고 그 실증적 분석은 매우 곤란하다. 역사적으로 19세기 후반 유럽에서는 반특허사상이 매우 거칠게 일어난 관계로 특허제도가 경제발전에 있어서 역효과라고 하여 네덜란드에서는 1869년에 그나마 존재하고 있던 특허법을 폐지하였으며, 스위스에서는 특허법의 제정이 지연되고, 독일에서도 각 지방의 특허제도의 존립이 위기에 처해 있었다.

그러한 상황에 있었으나, 1873년의 빈 국제회의를 전환기로서 유럽 각국의 특허제도는 많은 변화가 있었다. 그리고 빈 회의 후의 파리 회의에서 설계된 국제조약에는 많은 나라가 참가하고 있었다. 영국은 1883년 개정특허법이 심의되고, 성립되었다. 이 개정법에는 강제실시허락제도가 도입되었다. 이것에 의해 길게 논의되어 온 특허제도의 독점에 따른 폐해문제에 대해서 해소되게 되었다. 개정특허법의 제22조이었다.⁶⁸⁾ 한편, 네덜란드는 1886년에 네덜란드 특허옹호연맹이 결성되었다. 국회에서는 1908년~1910년에 특허제도의 심의가 행해지고, 1910년 국회는 특허법을 가결했다. 특허제도는 네덜란드에 있어서 부활한 것이다.⁶⁹⁾ 오랜 시간동안 특허제도의 도입을 국민투표에 의해 부정하고 있었던 스위스의 경우도 1887년 7월 10일의 국민투표에 의해 특허제도를 도입하였다.⁷⁰⁾ 다만, 이때 정부에 부여된 권한은 산업상 이용할 수 있는 기계장치에 관한

67) 국회의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/jsp/main.jsp> 참조.

68) 영국 1883년 특허법 제22조 통상위원회는 이해관계자의 차원에 기초해서 특허권 소유자가 타당한 조건으로 특허실시권의 허락을 주장 않기 때문에 이하와 같은 사태가 생기고 있는 것이 명확하게 된 경우, 즉

(a) 특허발명이 특허권 취득 후, 대영제국 내에서 이용하고 있지 않다. 또는

(b) 발명된 것에 대한 공공의 타당한 요구가 충족되지 않는다. 또는

(c) 제3자가 자신이 소유한 발명을 가장 유리하게 활용하는 것이 방해되고 있다.

이것들의 사태가 확인된 경우에는 발명의 성질과 당해 청원의 제사정을 감안한 위로 특허권 소유자에 대해서 통상산업위원회가 적당하게 판단한 특허실시료, 지불보정, 그 기타 조건하에서 특허실시허락을 명할 수 있다. 이 명령은 영달에 의해 강제집행된 것이다(이 해석은 大河内曉男, 앞의 책, 161-162頁에 의한다).

69) Schiff, E., *supra* note 25, p.69-73.

발명에 한정하였다. 유럽은 이러한 특허폐지론의 논란에서 선회하여 국제특허제도의 틀을 확립하였다.

그러한 논쟁은 특허제도의 경제적 기능을 중심으로 하여 전개되었으며, 각국의 특허제도를 폐지시켜 기술사상의 교류를 촉진하는 것이야말로 경제발전에 이바지할 수 있다는 발상이었다. 이 논쟁에 결론을 내린다는 것은 불가능에 가까울 것이다. 이러한 19세기 후반의 논쟁은 이론적인 결론 없이 불황이 닥쳐와 보호주의가 대두됨에 따라 소멸되고 말았다. 엄밀하게 말하면 경제학자에 의한 분석이 있어야 할 것이나 아마도 기술발전, 나아가 경제발전에 있어서 특허제도의 역할은 모든 기술에 대하여 일률적으로 판단할 수는 없을 것이다.

그러나 대체적인 경향은 화학 특히 의약분야에서는 하나의 특허로써 세계시장을 지배하는 것도 가능하므로, 특허권은 본래의 의미에서 독점권으로서 기능하는 데 비하여 전기나 기계분야에서는 한 개의 제품 중에 여러 개의 특허권이 부여되어 있어 단독기업이 하나의 제품에 대한 기술을 독점하는 것이 어려우며 오히려 특허권은 크로스 라이선스의 도구로서의 의미가 더 크다. 또 동일한 기술 분야에 있어서도 어떤 경우에는 기술개발에 큰 인센티브가 되기도 하지만, 다른 경우에는 그렇지 못할 수도 있다. 특허제도가 인센티브가 되는가 아닌가 하는 것은 개발자·연구자에 의해서도 달라질 수 있다. 이와 같이, 특허법의 경제적 의의에 대해서는 성급하게 결정하기는 어렵다 할 수 있다.⁷¹⁾

한편, 우리나라의 경우 뒤늦게 특허제도를 정비한 국가에 속하지만, 여러 차례의 특허법 개정과 함께 우리나라는 전자출원율 세계 1위, 특허출원 규모 세계 4위 등 조약과 외국법과 비교했을 때 선진국과 유사한 수준까지 도달하였다. 그러나 현재 Patent Troll의 권리남용으로 인하여 연구·개발 활동에 투입되어야 할 기업의 인력과 예산이 특허분쟁에 소진되어, 결과적으로 특허법이 오히려 기술개발을 저해하는 단계에까지 이르렀다는 우려가 제기되고 있으며, 해외 NPE에 의한 국내 기술의 해외유출 문제도 부각되고 있는 실정이다.

이와 더불어 리서치툴 특허에서도 리서치툴의 권리자는 사회적 이익을 공유하지 않으려 하고, 연구성과물 자체에 대한 대가 요구가 기존 특허권자의 권리를 지나치게 확장시키고 후속 연구개발자의 권리를 불합리하게 제한하는 문제점이 발생한다. 또한 기후변화대응과 의약품 등 공익관련 기술에 있어서도 강제실시권의 제약에 따라 문제점이 나타나고 있다. 이 외에도 특허권 보호가 미흡하여 특허를 받아도 소용없다는 특허

70) Ritter, D. S., "Switzerland's Patent Law History" - *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 14, No. 2, 2004, p.477.

71) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2010, 8-11頁.

무용론이 제기되고 있으며, 징벌적 손해배상제도 등 특허권 강화를 위한 대책이 필요하다는 요구가 대두되고 있는 실정이다.

이러한 대공황에 의한 보호무역으로의 전환, 미국의 국제특허정책, 유럽 각국의 산업혁명의 진전, 강제실시허락제도 등 19세기의 특허제도의 탄생에서 국제특허제도로의 변천에 관한 역사적 전개에 비추어 보면, 새로운 패러다임이 거듭되는 시기였다고 할 수 있을 것이다. 이점은 오늘날 제기되는 특허제도에 대한 비판론 내지는 개혁론이 시사하는 바도 역시 특허제도가 19세기와 같이, 다시 한번 새로운 패러다임에 직면하고 있다고 할 수 있을 것이다. 오픈 이노베이션, 공익과 기술혁신, 특허남용에의 대응이라는 측면에서 특허제도의 보완하기 위한 새로운 사고가 필요한 시기라고 생각된다.

제3장 제도론적 관점에서의 특허제도의 한계

제1절 서설

오늘날 특허제도는 공익(공중보건, 환경 등)적 측면과 기술 혁신적 측면, 그리고 특허권 남용 등 여러 가지 측면에서 새로운 패러다임에 직면해 있다고 할 수 있다.

기후변화 문제에 대해서는 선진국과 개도국의 현저한 입장차이로 인해 해결의 실마리가 보이지 않고 있으며, 공중보건이나 의약품 분야에 있어서도 마찬가지로 상황에 놓여있다. Patent Troll이나 특허풀에 있어서의 특허남용의 문제도 해결되지 않은 과제로 남아있다. 이러한 문제들의 이면에는 특허제도의 독점배타성이 가장 문제가 되고 있다.

따라서 이하에서는 공익 및 기술혁신, 그리고 특허남용과 관계되어, 현시점에서 논의되고 있는 기후변화, 공중보건, 리서치툴, 패튼트툴, 특허풀에 대한 각각의 논의 동향과 실태 파악을 전제로 하여, 특허제도가 제도론적 관점에서 어떠한 한계에 직면해 있는지를 살펴보고자 한다.

제2절 공익 및 기술혁신과 관계된 특허제도의 한계

I. 기후변화 대응과 특허제도

1. 기후변화협약의 의의

기후변화협약의 정식명칭은 '기후변화에 관한 유엔 기본협약(United Nations Framework Convention on Climate Change)'이며, '리우환경협약'이라고도 한다. 1979년 G. 우텔과 G. 맥도날드 등 과학자들이 지구온난화를 경고한 이래, 기후변화 문제에 대한 논의가 계속되었다. 그 후, 1987년 제네바에서 열린 제1차 세계기상회의에서 정부 간 기후변화패널(Inter-Governmental Panel on Climate Change: IPCC)을 결성되었다. 또한 1988년 6월 캐나다 토론토에서 주요 국가의 대표들이 모여 지구온난화에 대한 국제협약 체결을 공식으로 제의하였고, 1990년 제네바에서 열린 제2차 세계기후회의에서 기본적인 협약을 체결하고, 1992년 5월 정식으로 기후변화협약을 체결하였다.

이 협약의 목적은 이산화탄소를 비롯한 온실가스의 방출을 제한하여 지구온난화를 방지하고자 하는 데에 있다. 규제대상 물질은 탄산·메테인가스·프레온가스 등이 대표적이다. 협약 내용은 기본원칙, 온실가스 규제문제, 재정지원 및 기술이전문제, 특수상황에 처한 국가에 대한 고려로 구성되어 있다. 기후변화협약 체결국은 염화플루오린화탄소(CFC)를 제외한 모든 온실가스의 배출량과 제거량을 조사하여, 이를 협상위원회에 보고해야 하며 기후변화 방지를 위한 국가계획도 작성해야 한다.

2. 기후변화협약과 환경문제

인간의 사회생활은 자연환경에 많은 영향을 준다. 이러한 인간이 환경에 주는 부담으로 인해 현대사회에 있어서 공해 등의 형태로 표면화되어 사회문제가 되기에 이르렀다. 특히 최근에는 이산화탄소, 메탄 등 온실효과로 인한 가스의 대기 중 농도가 상승함에 따라 지구온난화와 기후변화라는 전지구적 환경문제로 인식되고 있다. 이러한 환경문제에 대하여 국제적 협력에 기한 대응이 요구되고 있는 실정이다. 그래서 국제적 협력의 일환으로서 기후변화조약은 "기후에 대하여 위험한 인위적 간섭을 미치게 하지 않는 수준에서 대기 중의 온실가스의 농도를 안정화시킬 것"을 목적으로 체결된 것이다.⁷²⁾

우리나라에서는 이 협약에 따라, 온실가스 배출량의 감축을 목표로 하고 있다. 무엇보다, 온실가스 배출이 사회생활과 밀접한 관계에 있는 점에 비추어, 기후변화조약이 목표하는 바와 같이, 현 생활수준의 유지와 향상을 도모하면서 온실가스 배출량을 감소시키기 위해서는 그에 합치된 기술 수준의 향상이 요구되는 것이 적지 않다.

예를 들면, 우리나라가 배출한 온실가스에 대해 살펴보면, 그 9할 이상이 화석연료를 연소할 때 생긴 이산화탄소이다. 일반적으로 온실가스의 대기 중 농도의 상승이 주요한 요인으로 보고 있다. 즉 석유와 석탄 같은 화석연료의 연소가 주된 요인이라고 생각된다.

그러므로 현대사회에서 불가결한 각종 에너지의 대부분을 화석연료에 의존하고 있다는 점에서 에너지 효율 향상의 실현과 석유대체에너지 등 이른바 환경 관련 기술의 연구·개발, 그리고 보급이 하나의 해결방법이 된다. 또한 환경이라는 일반적인 문제라는 측면에서도 문제의 발견과 그 원인의 특정, 문제의 성질·규모·영향에 대한 과정의 해명, 문제에 대한 효과적인 대처방안의 분석, 그리고 문제의 구체적 대응 등 다양한 측면에서의 기술이 요구된다.

72) 기후변화 조약 제2조(목적): 이 협약과 당사자총회가 채택하는 모든 관련 법적문서의 궁극적 목적은, 협약의 관련규정에 따라, 기후체계가 위험한 인위적 간섭을 받지 않는 수준으로 대기 중 온실가스 농도의 안정화를 달성하는 것이다. 그러한 수준은 생태계가 자연적으로 기후변화에 적응하고 식량생산이 위협받지 않으며 경제개발이 지속가능한 방식으로 진행되도록 할 수 있기에 충분한 기간 내에 달성되어야 한다.

3. 기후변화협약에 있어서 특허권 문제

가. 선진국과 개도국과의 입장차이

세계 각국은 온실가스의 배출량을 삭감하기 위한 기술, 즉 '환경관련기술'의 연구, 개발 및 보급을 위한 노력이 이루어지고 있다. 그러나 세계의 모든 나라가 요구하는 환경기술을 실현할 수 있느냐에 대해서는 의문이다. 특히 이 문제는 개도국을 중심으로 심각하게 받아들여지고 있다. 그러한 이유로 온실가스 배출삭감을 위한 대처방안의 실효성을 확보하기 위해서는 선진국에서 개도국으로의 기술협력 또는 기술이전 등의 지원이 필요하다고 한다. 기후변화협약에 있어서도 이러한 문제의식에 따라 기술이전과 이를 위한 자금 원조 등에 대한 규정이 설치되어 있다.⁷³⁾

무엇보다 선진국과 개도국 사이에는 기술적 지원의 방법, 장벽, 지식재산권의 영향 등에 대한 인식 등 다양한 측면에서의 격차가 존재한다. 특히 개도국은 지식재산권의 영향을 부정적으로 파악하여, 지식재산권의 존재가 자국으로의 환경 기술의 이전·보급의 장애가 되고 있다는 취지의 주장을 하고 있다. 특히 2008년 12월에 개최되었던 제14차 기후변화협약 체결국 회의(COP14)에서도 개도국의 이하와 같은 주장이 전개되었다.⁷⁴⁾

<표 III-1> COP14에서의 개도국이 주장한 내용

- ▶ 환경 관련 기술이 고가이며, 노하우의 이전이 불충분하다. 지식재산이 기술이전의 장벽이 되지 않으므로 유연성을 확대해야 한다.
- ▶ 지식재산의 보호와 개도국으로의 기술이전 확대와의 밸런스를 맞춰야 한다.
- ▶ 정부지원을 받아서 개발된 환경기술은 적극적으로 이전해야 한다. 선진국에 의한 연구개발투자의 2~4할은 정부에 의한 것이다.
- ▶ 기후변화문제는 TRIPS 협정 제31조에서 생명·안전과 국방에 필요한 경우 등의 긴급사태에는 강제라이선스 할 수 있는 규정이 있다. 기후변화문제는 해당 긴급사태에 해당한다.

73) 기후변화협약 제4조 1(c)조: 에너지·수송·산업·농업·임업 그리고 폐기물관리분야를 포함한 모든 관련분야에서 몬트리올 의정서에 의하여 규제되지 않는 온실가스의 인위적 배출을 규제·감축 또는 방지하는 기술·관행 및 공정을 개발·적용하고, 이전을 포함하여 확산시키는 것을 촉진하고 협력한다.

74) 財團法人國際投資研究所公正貿易センター 『「TRIPS 研究会」報告書・平成20年度』, 2009, 90頁 참조.

이러한 주장에 근거해 개도국이 환경기술의 이전에 대해 공통의 인식을 가지고 있는지는 명확하지 않다. 다만, 기후변화협약의 교섭에 대해서는 일관하여 G77⁷⁵⁾과 중국 등의 교섭단체가 개도국으로 구성되어 있다. 이 교섭단체의 핵심인 G77은 1960년대 GATT에 대응하기 위해 개도국이 유엔무역개발회의(United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD)의 창립 시에 창설된 것이다. 이점에서 위의 주장은 1960년대 이래 계속된 남북문제의 연장선상에 있는 주장으로 볼 수 있다⁷⁶⁾.

이는 1970년대에 국제경제학자에 의해 제창된 이른바 '종속론'을 논거로 한 주장이다. '종속론'은 선진국·다국적기업의 기술에 계속 의존하는 것은 개도국의 과학기술력이 영속적으로 향상되지 않고, 선진국과 선진국과의 기술격차가 양자의 경제격차를 고착화시킨다는 개념이다. 이른바, 선진국과 도상국의 기술격차를 고착화하는 요인이 되는 TRIPS 협정에 기초한 지식재산권의 보호수준을 낮추는 것이 개도국의 발전으로 이어진다는 개념이다.

나. 환경관련 기술에 관계한 특허권의 제한

일반적으로 기술이전에 관해 개도국은 비용문제를 제기한다. 특히 높은 비용문제의 하나의 요인으로 지식재산권의 존재를 들고 있다. 즉 기술의 사용할 때 로열티 등을 지불하는 것을 의미한다. 이러한 점에서 기술이전을 촉진하는 대책으로 지식재산권의 개방이 필요하다고 하며, 기후변화협약의 교섭에 있어서도 동 조약의 목적달성에 필요한 환경관련 기술의 이전을 촉진하기 위해 환경관련 기술을 제한하고 한다.⁷⁷⁾

그러나 선진국에서는 '특허권의 효력제한'을 통한 대응이 대기 중의 온실가스 농도의 안정화에 유효하고 적절한 수단이 될 수 없다고 주장한다. 특히 어떠한 기술을 어떻게 이용하면 온실가스 배출을 삭감할 수 있는가에 대한 구체적인 방안이 특정되어 있지 않고, '특효약'이 될 수 있는 환경관련기술을 찾을 수 없다고 한다. 또한 환경관련 기술의 이용을 통하여 온실가스 배출량을 삭감하기 위해서는 각 지역의 지리적 조건, 생활습관, 산업구조 등 사회적 사정을 종합한 환경관련기술을 선택하는 것이 요구된다는

75) 1964년 개최된 제1회 UNCTAD(유엔무역개발회의)에서 77개 개발도상국이 그룹이 되어 공동선언을 채택함으로써 출범하게 되었다. 특정한 기구는 없으며 UNCTAD 총회 등 국제회의에 대비하여 각료회의를 열고, 개발도상국의 의견조정 및 선진국에 대한 종합적인 요구 등을 통해서 개발도상국의 경제, 사회발전을 지향하고 있다.

76) 上野貴弘・杉山大志, "温暖化防止技術の国際技術移転-中國への技術移転の事例分析を通じて-", 『電力中央研究所報告 Y08023』, 電力中央研究所, 2009, 5頁.

77) 財團法人國際投資研究所公正貿易センタ, 앞의 보고서, 89頁 참조.

점에서 온실가스절감의 '특효약'을 찾기란 기대하기 어렵다고 한다.

또한 이러한 상황 하에서 강제실시권 등의 부여를 통해 특허권의 효력을 제한하게 되면, 해당 특허권에 관계한 환경관련기술로 행해진 연구·개발 투자를 회수할 기회를 상실시킬 우려가 있다. 그 결과 온실가스 배출삭감과 관련된 기술개발은 지속성을 가져야 하는데 특허권의 효력이 제한되면 관련 연구개발의 의욕을 현저히 감소시키게 된다. 그러므로 특허권의 효력을 제한하는 것이 타당하지 않다고 한다.

II. 의약품(공중보건)과 특허제도

1. TRIPS 협정과 공중의 건강에 관한 선언

도하선언은 "...TRIPS 협정은 가맹국이 공중의 건강을 보호하기 위한 조치를 취하는 것을 방해할 수 없고, 방해해서는 아니된다"고 합의하여 "공중의 건강을 보호하고, 특히 모든 사람들에 대하여 의약품으로의 접근을 촉진하는 WTO 가맹국의 권리를 지지하는 방법으로 동 협정이 해석되고 실시될 수 있고, 있어야만 한다"는 것을 확인하였다. 도하선언은 "...TRIPS 협정에 대한 각각의 약정(Commitment)을 반복하여 강조한다"고 명기하고 있으며, 개도국의 경과기간에 관한 para 7의 일부⁷⁸⁾를 삭제하여 TRIPS 협정의 변경은 없게 되었다.⁷⁹⁾ 다만, para 6⁸⁰⁾에 대응한 결정방법이 2003년 8월 30일 WTO 일반이사회에서 채택되어(결정 L540)⁸¹⁾, 구속력이 있는 제도가 성립하였다. 이

78) para 7은 LDC가 2016년 1월까지 TRIPS 협정 제5절 및 제7절의 실시 혹은 적용, 또는 이 절에 규정된 권리를 행사하는 의무를 의약품에 관해서는 부담하지 않는다는 것에 합의하였다.

79) 도하선언의 법적성격은 분명하지 않고, WTO설립협정 제10조의 협정수정 절차가 채택되지 않는 것은 물론인 점, 제11조 2항에서 말하는 "각료회의에 의한 배타적인 협정해석"으로서 가맹국의 4분의 3 이상 다수에 의한 채택 절차를 통해 "해석"으로서 의도적으로 채택된 것도 각료회의의 '결정'도 아니다(J. ジャクソン, "ドーハ閣僚会議の印象", 『經濟經濟ジャーナル』 Vol. 35, No.2, 2002, 12頁).

80) 의약품분야의 생산능력이 비존재 혹은 불충분한 WTO 가맹국이 TRIPS 협정 하에서 강제실시권을 효과적으로 사용할 때 곤란한 상황에 직면할 수 있음을 인정하여, TRIPS 이사회에 대해서 본 문제에 대한 조속한 해결을 표명하고, 2002년 말까지 일반이사회에 보고할 것을 지시하였다.

81) Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health, WT/L/540(and Corr. 1), 1 September 2003. 이 결정에 의해 이하의 조건 하에서 수출하기 위한 강제실시권의 설정이 가능하다.

(i) 의약품 수출국은 합의된 규정에 기초해 실시권을 허락할 것 및 그 조건(제품의 명칭, 수량, 실시권 허락의 기간 등)을 TRIPS 이사회에 통보한다.

(ii) 실시권자는,

제도는 의약품에 관해서 TRIPS 협정 31조(f)의 의무를 면제하고, 수출국에 대해서 해당 의약품에 특허가 있어도 일정한 조건을 충족한 경우는 강제실시권 하에서 의약품의 생산능력이 없는(혹은 불충분한) 국가로 복제(copy) 의약품의 수출을 가능하게 하였다.

한편, 도하선언은 의약품에 관한 TRIPS 협정 제5절(특허) 및 제7절(개시되지 않은 정보의 보호) 규정의 채택 상 영향을 가지고 있어 WTO 가맹국의 국내법 및 국내법원의 판결에 영향을 주고 있다. WTO의 분쟁처리에 대해서는 '분쟁해결규칙및절차에관한양해'(DSU)에 의거해 '해석에 관한 국내법상의 관습적 규칙'에 따른 고려가 행해지게 될 것이다.

도하선언의 para 4에 의하면 TRIPS 협정은 “모든 개인에 대하여” 의약품으로의 허용을 촉진⁸²⁾하는 것을 지지하도록 해석되고 실시되어야만 하며, 이러한 목적을 위해서 WTO 가맹국은 TRIPS 협정의 유연성을 최대한으로 이용할 권리를 갖는다. para 5는 그것들을 위한 TRIPS 협정 해석방법⁸³⁾, 강제실시권의 부여 이유와 '무엇이 국가긴급사태 그 밖의 극도의 긴급사태'인가를 결정하는 '이유'를 'TRIPS 유연성'의 예로 들고 있다. 이와 더불어, 동 선언은 “TRIPS 협정이 이들 문제에 대처하기 위해 보다 광범위한 국내 및 국제적 행동의 일보일 필요성을 강조한다(para 2)”고 하고 있다. 이에 따라,

- 특허권자에 상응한 보수를 지급한다. 그 때, 수입국 측에서의 특허의 사용가치가 고려된다. 수출국에 대해서 대가가 지급된 제품에 대해서 수출국의 TRIPS 협정 31조 (h)의 의무는 면제된다.
- 선적 전, 웹사이트에 목적지와 적하량, 제품을 식별하는 특징 등을 기재한다.
- (iii) 의약품 수입국은,
 - 해당 의약품의 특허가 존재하는 경우, 강제실시권 부여와 거기에 반한 조건에 관한 정보를 TRIPS 이사회에 통보한다.
 - 의약품이 공중위생상의 목적에 한하여 수입된 것을 확보하기 위한 능력에 대응하여, 재수출을 막기 위한 합리적인 수단을 구한다. 이것이 곤란한 상황의 경우 선진국은 기술면 및 경제면에 협력한다. 이 밖에 수입국에 의약품의 생산능력이 불충분한지 여부에 대한 확인에 관해서도 규정한다.

82) 이와 관련하여 캐나다의 온타리오 주 유전자 진단 신기술에 관한 위원회는 2002년 1월, 도하선언 이 일절에 언급해, 개개인이 언제 어떤 의약품을 필요로 하는가에 대하여 진단한 최신의 특허기술도 공중위생과 관련된 것이라고 하였다. 이 위원회의 검토대상이었던 BRCA 특허(유방암에 걸리기 쉬운 유전자의 진단기술)는 이러한 점에서 문제시된다. 미리아드사의 유방암 특허(BRCA1, BRCA2)의 진단적 사용(변이유전자를 계승한 사람의 유방암 발병확률을 진단한다)이 매우 곤란한 것, 로열티가 고액인 것도 문제가 된다(WHO.UNDP Remuneration Guidelines for Non-Voluntary Use of a Patent on Medical Technologies(WHO/TCM/2005.1), James Love, Consumer Projects on Technology(CP Tech), Washington D.C, WHO/UNDP Remuneration Guidelines), p. 34-36).

83) 제5절 (a) 해석에 관한 국제법상의 관습적 규칙을 운용할 때 TRIPS 협정의 각 규정은 협정의 목적에 비추어 해석된다.

WTO가 관할하는 TRIPs 협정의 해석은 의약품에 관한 한 이것에 의해 WTO가 관할한 TRIPs 협정의 해석은 의약품에 관한 한, WHO, UNCTAD, 국제연합인권위원회와 그 밖의 국제연합기관의 정치적 영향권 안에 놓이기 쉽게 되었다.

2. 의약품과 특허권

의약품 특허는 건당 가치가 매우 높고, 여러 특허에 의해 하나의 제품이 보호되고 있다는 점에 특징이 있다. 1건의 특허침해로 인해 판매중지와 고액의 실시료의 지불을 명할 수 있게 된다. 연구개발형 제약회사는 발명의 독점적인 실시를 목표로 하지만, 실제 제품시장에서는 후발 제약회사의 유사 의약품이 경쟁하게 된다. 의약품 시장에서 동일한 효능을 가지는 의약품이 시판되고 있는 경우가 대부분이다. 그래서 실질적으로 특허가 부여된 의약품이 시장지배력을 가지는 것이 많지는 않다. 현재까지 미국과 유럽의 여러 국가에서 어떠한 종류의 항생물질과 특수한 진통제 등 극히 한정된 제품이 시장지배력을 가지고 있다고 판단되고 있다.⁸⁴⁾ 경쟁법을 적용할 경우 의약품에 대하여 소비자는 선택할 수 없고, 의사의 처방에 의해 결정되므로 관련시장의 획정에 SSNIP 테스트⁸⁵⁾는 사용될 수 없다. 그러나 '치료 상의 대체성'을 가리키는 Anatomical Therapeutic Chemical classification system(ATC 해부학, 치료학, 화학의 면에서 의약품을 분류한 시스템)을 시장의 상황과 아울러 조정해 의료보험에 의한 지불, 선전효과와 처방전을 통해서 관련시장을 확정한다.

의약품 기술 분야에서 지재의 취득과 관리에 막대한 노력을 들이고, 특허를 기반으로 한 비즈니스가 이루어지고 있는 이유는 정보만 있으면 제조비용은 저렴하다는 분야의 특질과 관련된다. 신약 개발의 R&D 비용은 높고, 제조비용은 낮은 의약품 분야야말로 모방의 수익률이 높고 지재권 보호가 중요하다. 이점에 대해서는 맨스필드의 실증연구에 대해서도 분명했다.⁸⁶⁾ 그래서 다른 분야에서 나타나고 있는 제품화에 대한

84) Napp v OFT, Competition Commission Appeal Tribunal, [2002]Comp. AR, 13몰핀 정제(시장 독점률 85%라고 인정); Genzyme Ltd. v OFT, Competition Appeal Tribunal, 1016/1/1/03 고셔병 치료 물질 Cerezyme(시장 점유율 100% 인정); Conseil de concurrence, Decision(2007.3.14) Zinnat(항생물질, GSK의 약탈적 가격인정)

85) SSNIP 테스트란 가상적인 독점기업이 SSNIP(작지만 의미 있고 일시적이지 않은 가격인상)의 실행을 통하여 이윤을 증대시킬 수 있는 최소 범위의 상품(지역)을 관련시장으로 확장하는 방법론이다.

86) E Mansfield, M Schwartz and S Wagner, 'Imitation Costs and Patents: An Empirical Study', The Economic Journal, 91(1981. 12) at 907-918. 'imitation Cost' is defined as 'all costs of developing and introducing the imitative product, including applied

속도에 대한 인센티브는 의약품 분야에서는 희망하지 않는다.

한편, HIV/AIDS, 결핵, 말라리아와 같은 전염병을 고려하여, 이러한 전염병 치료약을 특정한 후 제조능력이 있는 나라에서 해당 치료약에 관한 특허권을 선진국 기업이 보유하고 있다는 이유로 특허권의 효력을 제한하려고 한다.⁸⁷⁾ 또한 이러한 전염병, 크게 보면 공중보건과 관련된 문제가 개도국에서 심각한 실정에 있다. 그래서 특허 라이선스 조약에 기해 특허권자에게 허용되고 있는 치료약의 제조량과 비교하여, 보다 많은 치료약을 제조하는 잉여능력을 갖춘 국가에서 강제실시권의 부여 등을 통해 특허권을 제한하고, 치료약의 제조를 허용하기를 요구하는 것이다.

III. 리서치 툴과 특허제도

1. 리서치 툴 특허의 의의 및 유형

가. 리서치 툴 특허의 정의

리서치 툴(Research tool) 특허란, '연구자들이 연구(research)를 수행하는 데에 필요한 수단 또는 도구(tool)로 사용되는 특허'를 지칭하는 표현으로 연구자들이 연구수행 과정에 필요한 시간과 자금을 절약하는 역할을 한다.⁸⁸⁾⁸⁹⁾ 리서치 툴은 화학, 생명과학, 정보과학과 약학 및 진단약품의 개발 분야에서 광범위하게 채택되고 있다.⁹⁰⁾ 리서치 툴

research, product specification, pilot plant or prototype construction, investment in plant and equipment, and manufacturing and marketing startup'

87) 山根裕子, “知的財産權のグローバル化-醫藥品アクセスと TRIPS 協定, 2008, 83頁 참조.

88) 조명선, “Research tool 특허에 관한 생명과학분야의 최근 이슈”, 「지식재산21」(통권 제101호), 특허청, 2007, 24면.

89) 미국국립보건원(National Institute of Health)은 리서치 툴을 ‘과학자가 실험실에서 도구 또는 수단으로 사용하는 모든 자원을 지칭하는 것(the full range of resources that scientists use in the laboratory)’ 이라고 정의하고 있다(강경남, 「지식재산권이 연구 개발 활동에 미치는 영향에 대한 연구」, 특허청, 2008, 1면).

90) OECD의 ‘유전학적 발명의 라이선스를 위한 가이드라인(Guidelines for the licensing of genetic inventions)’에서는 리서치 툴을 실험과정에서 사용되는 합성물 또는 방법이라고 정의하고 있다. 이 용어는 과학자들이 실험실에서 사용하는 광범위한 자원을 포괄할 수 있으며, 세포 주, 단일클론 항체, 시약, 동물모델, 성장인자, 조합화학, 게노믹과 프로테오믹 자료실(genomic & proteomic library), 약물 및 약물대상, 클론 및 클로닝 도구, 방법, 실험장비 및 기계 데이터베이스, 소프트웨어를 포함하지만 이에 국한되지 않는다고 하고 있

의 구체적 예로는 특허가 인정된 분석표, 절차, 세포계(cell line), 유전자조합형 DNA 구조, 방법, 효소, 고속 처리 약물검사를 위한 DNA 미시배열(microarray), 연구용 동물, 컴퓨터프로그램과 같은 생물정보적 도구, 단백질과 조합된 화학 자료실(chemistry library), 시약, 약물과 약물의 대상(target), 기타 많은 특허 기계나 도구가 이에 해당한다.⁹¹⁾

나. 리서치 툴 특허의 유형

리서치 툴은 적용성을 기준으로 분류할 때 특화된 리서치 툴과 광범위한 리서치 툴로 구분할 수 있다. 특화된 리서치 툴은 유전자, 세포계 등과 같이 매우 제한적으로 리서치 툴이 적용되는 경우를 말하며, 광범위한 리서치 툴은 새로운 기술, 데이터베이스, 기구 등의 다양한 분야의 연구 수행 및 연구목적 달성에 리서치 툴을 이용하는 경우를 말한다.⁹²⁾

또한, 리서치 툴은 제공자가 누구인지에 따라 분류하는 경우, 회사나 기타 이윤을 최대화하고자 하는 산업계와 같은 사적기관이 제공하는 리서치 툴, 공적자금에 의해 지원을 받는 기관인지 아니면 사적 기부금에 의해 지원을 받는 연구기관인지를 불문하고 대학, 연구소와 같은 공적기관이 제공하는 리서치 툴, 개인이 제공하는 리서치 툴로 구분할 수 있다.⁹³⁾

다. 리서치 툴의 특허성

리서치 툴에 대하여 특허권이 인정되기 위해서는 먼저 리서치 툴이 특허의 보호대상(발명)이 되어야 하는데, 리서치 툴 특허 보호에 대해 가장 활발하게 논의가 되고 있는 미국의 경우 리서치 툴이 당연히 특허대상(발명)이 될 수 있는 것으로 보고 있다.⁹⁴⁾⁹⁵⁾

다.(육소영, “리서치 툴 특허와 그 보호의 정당성”, 「산업재산권」(통권 제28호), 한국 산업재산권법학회, 2009, 6면).

91) 육소영, 위의 논문, 3면.

92) 리서치 툴은 연구목적 달성에 부수적인 것이 아니라 그 자체가 연구 및 개발의 직접 목적이 된다. 따라서 이들의 개발에는 많은 비용이 소요되며 개발 후에는 광범위한 시장을 갖게 된다(Marlan D. Walker, "The Patent Research Tool Problem After Merck v. Integra", 14 Tex. Intell. Prop. L. J, 2005, pp.4-5)

93) 육소영, 위의 논문, 6-9면.

94) 생명체의 특허성 문제와 관련한 Diamond v. Chakrabarty 판결에서 연방대법원은 살아있고 인공적인 미생물은 제조(manufacture) 또는 합성물(composition of matter)로서 미국특허법 제101조에 규정된 특허 가능한 주제(patentable subject matter)라고 판시하였는데, 이는

결국 리서치 툴은 특허보호요건을 만족하는지에 따라 그 보호 여부가 결정된다고 할 수 있다. 리서치 툴의 특허성을 판단함에 있어 가장 문제가 되는 점은 유용성(산업상 이용가능성)의 만족여부이다. 미국 특허상표청의 유용성에 대한 심사지침과 법원의 판결은 출원인이 단순히 연구매개물로의 사용을 입증하는 것으로는 충분하지 않으며 신뢰할 수 있는 특화된 실질적 유용성을 입증할 것을 요구하고 있다. 따라서 단순히 연구 도구로만 사용되는 리서치 툴은 특허를 받을 수 없으며 그 자체로서 특정된 실질적 유용성이 있는 경우에만 특허로 보호될 수 있다.

1960년대까지 미연방대법원은 특허에 의해 그 보호범위를 확정할 수 없는 경우 즉, 발명의 유용성이 특정될 수 없거나 실질적이지 않은 경우 특허를 인정하지 않았으므로 화학방법에 대한 특허를 부정하였다. 그러나 미국 특허상표청은 1990년대에 들어 유용성에 관한 지침을 수정하여 실질적 유용성 요건을 삭제하였으며, 법원도 유용성 판단 시 유연한 입장을 취하기 시작하였다. 2001년에는 유용성 판단을 위한 지침을 수정하여 신뢰할 수 있는 특정되고 실질적 유용성을 출원인이 입증할 것을 요구하였는데, 여기서 실질적 유용성이란 발명이 즉각적이고 현재성 있는 이익을 공중에게 제공해야 함을 말하며 장래의 연구나 발명을 위해 유용하다는 증명으로는 충분하지 않다. 특정된 유용성이란 출원인이 광범위한 범위의 발명에 적용할 수 있거나 너무나 막연하여 무의미한 용도가 아닌 잘 정의된 특정 용도를 입증할 것을 요구한다.⁹⁶⁾⁹⁷⁾

2. 리서치 툴 특허의 문제점

특허제도가 발명에 대한 인센티브를 제공함으로써 산업발전을 도모한다는 긍정적인 측면을 갖고 있는 반면, 배타적 독점권으로 인하여 파생되는 부정적인 영향도 적지 않으므로 이들 사이의 적절한 균형을 유지하는 것은 매우 중요하면서도 어려운 일이다. 리서치 툴 특허 역시 특허권자와 제3자간의 적절한 균형이 요구된다는 점에서 특허제

‘세상의 모든 인공적인 것은 특허대상이 될 수 있다’ 고 보았다. 미국 특허법은 그 보호대상 여부 판단 및 법해석 시에 비교적 광범위한 기준을 적용하고 있는 것으로 보아 판단컨대, 리서치 툴 역시 특허의 보호대상이 된다는 견해에 대해서는 크게 논란이 없을 것이다.

95) 리서치 툴의 특허성에 대하여 적극적 찬성 입장을 보이는 측에서는 저울, 간접계, 현미경과 같이 합성물을 평가하고 감정하기 위한 방법은 그 자체로서 가치를 가진 과학적 툴이라는 입장을 취하고 있다(Jonathan Kahn, "What's the Use? Law and Authority in Patenting Human Genetic Material", *14 Stan. L. & Pol'y Rev.*, 2003, p.416, 435).

96) USPTO, Revised Interim Guidelines Training Materials.

97) 육소영, 앞의 논문, 9-15면.

도에서 파생된 공통적인 문제 중 하나라고 할 수 있다. 대개 리서치 툴의 권리자는 연구 속도가 향상됨에 의한 사회적 이익을 공유하지 않으려 한다. 리서치 툴을 사용하여 나온 연구성과물 자체에 대한 소유권 요구, 장래의 연구 성과에 대한 로열티, 라이선스비 등 대가 요구는 'reach-through right',⁹⁸⁾ 'reach-through royalty'에 해당하는 것으로, 기존 특허권자의 권리를 지나치게 확장 시키고 후속 연구 개발자의 권리를 불합리하게 제한하는 문제점을 내포하고 있다.⁹⁹⁾

특히 생명과학의 경우에는 각 물질들 즉, 특정한 유전자나 단백질이 제각기 독특한 기능을 갖고 있어서 다른 합성 화합물이나 기계부품과 달리 후발연구자들이 이들 특허를 회피할 대체물질을 찾는 것이 실질적으로 불가능한 경우가 대부분이다. 이러한 특징으로 인해 후발연구자들은 자신들의 연구를 수행하기 위한 툴로써 특허 받은 upstream 물질¹⁰⁰⁾에 의존할 수밖에 없게 되며 그 특허에 접근하는 것의 장벽은 연구 진행의 장벽을 의미하게 된다. 나아가, 물질특허뿐만 아니라, 방법 자체에 특징이 있는 특허의 경우에도 모든 생명과학분야 연구에 공통적으로 응용될 만큼 리서치 툴로서 영향력이 대단한 발명이 대부분이어서(예를 들어, 유전자를 다량으로 발현시키는 방법, 유전자를 증폭시키는 방법, 유전자 서열을 결정하는 방법, 유용한 물질을 스크리닝하는 방법 등) 이러한 획기적 방법 발명에 관한 특허들의 후발연구에 대한 영향력도 대단한 것이었다.¹⁰¹⁾

후발연구자들이 리서치 툴로 사용해야만 하는 이들 특허에 쉽게 접근할 수 없다면 연구의 진행 자체가 곤란한 지경이 되므로 후발연구자들은 매번 특허권자와의 라이선스 계약을 통해 원하는 툴에 접근하여야 하는데 이는 후발연구자들, 특히 상업적 목적을 가진 연구기관에게는 큰 부담이 아닐 수 없고 사업을 막 시작하려는 작은 기업들에게는 연구방법을 전환하지 않으면 안 되는 상황도 발생하게 된다. 이러한 면에서 리서치 툴 특허의 원활한 사용이 강조되었으며 특허권의 지나치게 높은 장벽이 문제가 되곤 하였다. 하지만, 한편으로는 앞서 언급한바와 같이, 리서치 툴 특허는 작은 생명공학벤

98) 생명과학분야 발명에서 자신이 수행하지 않은 발명에 대해서까지 청구범위를 확장하여 설정하는 것에 대해 reach-through claims라 부르는 것과 동일한 개념을 권리설정에서 사용한 용어이다. 즉, 실제로는 자신의 발명이 완성한 부분이 아닌데도 자신의 연구에서 파생될 수 있는 다른 결과물까지 권리범위로 확장시켜 주장하는 것을 의미한다.

99) 강경남, 앞의 보고서, 21면.

100) 생체반응(세포분열, 면역반응, 세포 간의 신호전달 등)의 초기단계를 규명한 발명을 소위 'upstream invention'이라 부르는데, 그 연구결과물들은 그의 조절을 받아 진행되는 다양한 후발 프로세스의 연구(즉, downstream invention)를 수행하는 데에서 회피할 수 없는 필수불가결한 리서치 툴이라고 할 수 있다.

101) 조명선, 앞의 논문, 25면.

처 기업 등이 특허권 양도나 라이선싱을 목적으로 개발하는 경우도 많다. 의약품과 같이 최종물질을 시장에 진입시키기까지의 복잡한 과정과 과도한 비용을 감당할 여력이 없는 작은 규모의 생명공학업체들은 활용도가 높은 우수한 ‘tool’을 개발하고 특허를 받아 기술료를 벌기 위해 주력하는 경우가 많으므로 리서치 툴 특허는 중요한 보호대상으로 간주되어야 된다는 주장도 상당한 설득력을 갖는다.¹⁰²⁾

IV. 정리

이상으로 공공의 이익과 기술혁신과 관련된 특허제도의 한계에 대하여 살펴보았다. 이를 요약하면 다음과 같이 정리할 수 있을 것이다.

첫째, 인류의 삶과 직결된 기후변화문제, 보다 넓게는 지구의 환경문제에 대처함에 있어서도 선진국과 개도국간의 현저한 입장 차이를 나타내고 있다. 무엇보다, 이러한 국제교섭에 있어서 환경관련기술에 대한 유연한 강제실시권의 허락을 구하는 개도국의 주장에 대해 특허제도는 하나의 걸림돌이 되고 있다. 물론, 이러한 문제는 선진국과 개도국간의 ‘첨예한 이해대립’이라는 속사정이 있기는 하나, 지구환경의 문제라는 거시적 측면에서 볼 때 특허제도의 본질적이며 구조적인 문제가 있다고 볼 수 있을 것이다. 이러한 현행 특허제도를 어떻게 보완할 것이냐가 앞으로 21세기를 사는 인류 혹은 후세를 위해 어떠한 지구를 물려 줄 수 있을 지도 상당한 고민이 필요하다고 생각된다.

둘째, 의약품과 특허권에 관한 논의의 방향성도 기존에 공중위생의 문제와 환경문제 모두 공공의 이익에 깊이 관계있는 사례라는 점에서 공통된다는 인식으로부터, 공중위생과 의약품 등에 관한 특허권과의 관계를, 환경문제와 환경관련기술의 지식재산권과의 관계와 유사하다고 할 수 있다. 이러한 측면에서 개도국의 특허권 효력제한은 일정한 설득력을 갖는다고도 볼 수 있을 것이다. 공중보건(의약품)과 특허권에 관계한 문제는 개도국 국민, 넓게는 지구라는 인류의 공존의 차원에서 검토되어야 한다. 즉 의약품과 특허권에 관한 문제도 역시 특허제도가 가지고 있는 내재적 문제라고 할 수 있을 것이다.

셋째, 리서치 툴 특허는 ‘연구자들이 연구(research)를 수행하는 데에 필요한 수단 또는 도구(tool)로 사용되는 특허’를 의미하는데, 유전자, 세포계 등의 생명공학 분야를 비롯하여 새로운 기술, 데이터베이스, 기구 등의 다양한 분야에서의 연구 수행 및 연구목적 달성을 위해서 광범위하게 사용되고 있다. 리서치 툴 특허는 독점배타적 권리인

102) 조명선, 앞의 논문, 26면.

특허권의 본질상 개발자들에게 당연히 인정되어야 마땅하지만, 특히 생명공학 분야에서 리서치툴 특허를 지나치게 광범위하게 인정하게 되는 경우 연구자 및 개발자들은 매우 큰 어려움에 처할 수 있다. 만약 특허 받은 리서치 툴을 대체할 만한 다른 특허가 없다면 후발 연구자들은 특허권자와 라이선스 계약 및 로열티 지급 문제와 같은 부담을 가지게 되는데, 생명공학 분야의 경우 거의 대부분의 리서치 툴이 대체물질을 찾기 어렵다는 특징으로 인해 타 산업분야에 비하여 후발연구자들이 받게 되는 부담이 클 수밖에 없다. 이는 결국 기술혁신을 저해하고 해당 산업 및 관련 산업의 발전에 장애물로 작용하고 있으므로, 이 역시 특허제도의 한계를 드러내는 사례라고 할 수 있을 것이다.

제3절 특허권의 남용과 관계된 특허제도의 한계

I . Patent Troll과 특허남용

1. Patent Troll의 의의 및 유형

가. 의의

‘Patent troll’이란 용어는 1991년 Intel사의 고문변리사였던 Peter Detkin에 의해 최초로 사용되었다. Detkin는 ‘Patent troll’을 “현재 발명을 실시하지 않으며, 실시할 의도도 없고, 대부분의 경우 결코 실시할 리가 없는 특허로부터 많은 수익을 얻고자 하는 자”로 정의하였다.¹⁰³⁾

‘Patent troll’과 유사한 명칭으로 유사한 호칭으로서 ‘특허착취자’(patent extortionist), ‘특허기생자’(patent parasite), ‘특허 해적’(patent pirate), ‘특허투기자’(patent speculator)를 들 수 있다. 그런데 현재 Detkin가 상무이사로 있는 Intellectual Ventures LLC사는 특허관리회사로서, 이 회사를 ‘Patent troll’ 보는 사람도 있다. 그 때문에 Detkin는 Patent troll이 가지는 나쁜 이미지를 없애기 위해 “‘Patent troll’이라는 단어는 당신이 좋아하지 않는 모든 원고에 대해 널리 애용하고 있으나, 그러한 넓은 정의에 따르면, 캘리포니아 대학과 Intel사, IBM사, Thomas Edison도 patent troll이다”라고 언급하였다.¹⁰⁴⁾

103) Breda Sandburg., “Inventor's Lawyer Makes a Pile from Patents”, *The Recorder*, July 30, 2001.

나. 유형

'patent troll'은 몇 가지 유형으로 분류된다.¹⁰⁵⁾ 첫째, Acacia Technologies사와 같이 특허권의 이용을 목적으로 그 특허를 취득한 기업이다.¹⁰⁶⁾ 둘째, Mosaid사와 Patriot사와 같이, 특허를 이용하여 제품의 제조와 판매를 하고 있었으나, 영업을 정지하여 사실상 특허권만을 보유한 기업을 들 수 있다.¹⁰⁷⁾ 셋째, IP Value Management사와 같이 특허권자의 입장에서 권리를 주장하는 대리인(Agent)의 경우도 'patent troll'이라고 할 수 있을 것이다.¹⁰⁸⁾ 마지막으로, 미니애폴리스의 Robin, Kaplan, Miller & Ciresi과 델러스의 Makool Smith, PC라는 법률 사무소의 경우도 'patent troll'이라고 볼 수도 있을 것이다.¹⁰⁹⁾

다. 관련 사례

최근 특허분야에서 패튼트롤(Patent troll)이라는 말이 유행되고 있다. 이 말이 유행하게 된 이유는 미국의 특허관련 사건에서 기인한다.

MercExchange v. eBay 사건은 1998년 MercExchange사의 창립자인 Thomas Woolston은 온라인 경매에 관한 특허를 취득하고 회사를 운영하였으나, 경영악화로 인해 종업원을 해고하고 특허만을 보유하고 있었다. 한편 eBay사는 온라인 경매·쇼핑 웹사이트를 개설하고, 2005년에는 45억 5000만 달러를 판매하였다.¹¹⁰⁾ 이에 MercExchange사는 eBay사가 온라인 경매에 관한 MercExchange사의 특허를 고의로 침해하였다고 하여, eBay사를 고소하였다. 이에 배심원은 eBay사에 대하여 3500만 달러의 배상금을 판결하도록 하였다. 1심법원은 그 배상액을 2900만 달러로 감액하고, MercExchange사의 eBay사에

104) "Has the Enemy of Patent Trolls Become One?", CIO Insight, (December 5, 2005).
(<http://www.cioinsight.com/article2/0,1540,1902291,00.asp>).

105) Jeremiah Chan & Matthew Fawcett, "Footsteps of the Patent Troll", Vol.10 No.1 *Intell. Prop.L.Bull.*, 2005, p.1-2 .

106) Acacia Technologies, About Us, http://www.acaciatechnologies.com/aboutus_main.htm.

107) Mosaid Technologies Inc., <http://www.mosaid.com/corporate/about/profile.php>;
<http://www.us.designreuse.com/news/news10022.html>

108) IPValue Management Inc., <http://www.ipvalue.com/company/index.html>.

109) Mark Voorhees, *Ethereal Asset*, *Intell. Prop. L. & Bus.*, June 2004 at 40.

110) Ellen McCarthy, *Waiting Out A Patent Fight With EBay*, *Washington Post*, Jan. 6, 2005, at E01 (<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A51969-2005Jan5.html>).

대한 금지청구를 각하하였으나, 항소심은 1심판결을 부인하고 금지명령을 인정하였다. 그 후 eBay사는 연방대법원에 상소하였고, 연방대법원은 4가지 테스트를 거쳐 사건을 파기 환송하였다.¹¹¹⁾

또한, Eolas v. Microsoft사건에서 Eolas사는 캘리포니아 대학의 Michael Doyle 박사에 의한 스핀 오프(spin-off)기업으로서 1994년에 설립되었고, 브라우저 플러그인에 관한 특허를 보유하고 있다. Eolas사는 Microsoft사의 Internet Explorer가 Eolas사의 특허를 침해하고 있다고 하여 Microsoft사를 상대로 소를 제기하였다. 배심원은 5억 2000만 달러의 배상을 평결하고, 1심법원은 Microsoft사에 Internet Explorer의 배포를 금지하였지만, 금지명령은 항소를 위해 보류되었다.

그 후 연방항소법원은 지방법원에 환송하였으나, 특허법 제271조 (f)항¹¹²⁾의 해석에 관해서는 지방법원의 판결을 지지하였다. 즉 Microsoft사는 해외의 OEM기업에 수출한 소프트웨어의 마스터디스크 뿐만 아니라 마스터디스크로부터 복사된 소프트웨어 부분에 대해서도 침해의 책임을 진다고 하였다.¹¹³⁾

NTP v. RIM사건에서, RIM사는 캐나다의 온타리오를 근거지로 한 기업으로, BlackBerry라는 휴대형 전자 메일기기의 판매로 2005년에는 13억 5000만 달러를 판매하였다. 한편

111) eBay Inc. v. MercExchange LLC, 126 S.Ct. 1837 (2006) ("That test requires a plaintiff to demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction).

112) 미국 특허법 § 271 (f)항: (1)정당한 권한없이 특허발명의 구성요소들(components)의 전부 또는 상당한 부분을 미국 내에서 혹은 미국으로부터 공급하거나 공급되도록 초래하는 자는 누구든지, 그러한 구성요소들(components)이 전부 또는 부분적으로 결합되지 않은 상황에서, 그러한 구성요소들(components)의 결합이 미국 내에서 이루어진다면 특허권 침해가 성립하는 방식으로 미국 밖에서 결합되도록 적극적으로 유도하는 방식으로 공급하거나 공급되도록 초래하는 경우 침해자로서의 책임을 진다.

(2) 정당한 권한 없이 특허발명의 구성요소로서(component) 그 발명에 대하여 사용되기 위하여 특별하게 만들어졌거나 개조되었고 일상적 제품(staple article) 혹은 실질적인 비침해적 용도(substantial noninfringing use)에 적합한 상업적 물품이 아닌 것을 미국 내에서 혹은 미국으로부터 공급하거나 공급되도록 초래하는 자는 누구든지, 그러한 구성요소(component)가 전부 또는 부분적으로 결합되지 않은 상황에서, 만약 해당 구성요소(component)가 그렇게 만들어졌거나 개조되었음을 알면서도 그러한 구성요소들(components)의 결합이 미국 내에서 이루어진다면 특허권 침해가 성립하는 방식으로 미국 밖에서 결합되도록 의도할 경우 특허 침해자로서의 책임을 진다.

113) Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325, 1328-32 (Fed. Cir. 2005).

NTP사는 발명자 Thomas J. Campana 주니어의 무선전자 메일에 관한 특허의 라이선스를 목적으로서 Thomas J. Campana와 특허변리사 Donald E. Stout가 설립한 회사이다.¹¹⁴⁾

2001년에 NTP사는 특허권침해로 RIM사를 고소하였고, 2002년에 배심원은 약 2300만 달러의 배상금을 판결하였다. 2003년에 미국 특허상표청은 NTP사가 보유한 특허를 재심사한다고 발표했지만, (재심사의 결과를 기다리는 일 없이) 그 해의 말 지방법원은 NTP사를 지지하는 판결을 내리면서 추가손해로 증액된 5370만 달러의 배상금의 지급을 RIM사에 명함과 동시에 RIM사에 대한 판매 금지도 인정했다.¹¹⁵⁾

그 후 금지명령은 항소를 위해 유보되고 2005년에는 양사가 4억 5000만 달러의 배상금으로 화해하려고 하였으나, 교섭은 결렬되었다. 연방항소법원의 재심리 후 판결의 일부가 변경되고 금지명령을 무효로 하면서 사건을 지방법원에 환송하였다.

환송한 심리에 대해 지방법원은 특허상표청에 의해 재심사 중의 소송수속의 중단을 인정하지 않았다. RIM사는 연방대법원에 상소하였으나, 각하되었다. 2006년 지방법원으로 환송된 이 사건은 양사의 6억 1250만 달러를 배상한다는 합의로 종결되었다.¹¹⁶⁾

2. Patent Troll이 특허제도에 미치는 영향

최근 특허권을 보유하고 있으나, 실시하지도 아니하고 제3자에게 라이선스를 부여하지도 않으면서 해당 특허기술을 이용하는 기업을 상대로 특허침해소송을 제기하여 금전적 이익만을 취하는 특허권자의 행위가 증가하고 있다.¹¹⁷⁾

114) Mike Hughlett, Blurry on Blackberry, Chicago Tribune, Feb. 19, 2006 available at <http://www.chicagotribune.com/technology/chi-0602190193feb19,1,2188886.story?coll=chi-techtropheds-hed> (describing Campana's history of invention and formation of NTP); Kim Isaac Eisler, BlackBerry Blues, Washingtonian (Sept.1,2005), available at <http://www.wrf.com/docs/news/2125.pdf> (detailing the dispute from the point of view of the law firms involved).

115) NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1290 (Fed. Cir. 2005).

116) NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 397 F.Supp.2d 785 (E.D. Va. 2005).

117) 미국에서는 '잠수함 특허'를 이용한 특허제도를 남용하는 자를 Patent troll의 시초로 볼 수 있다고 한다. 이러한 '잠수함 특허'는 '선출원시부터 장기간에 걸쳐 공개된 특허를 일컫는 비공식 법률 용어'이다. 즉 잠수함과 같이 수면 아래 장기간 묻혀 있다가, 갑자기 출현하여 사람들을 놀라게 하는 것이다. 특허로 보면, 장기간 공개되어 있지 않다가 어느 순간 특허로 공개되어 시장을 어지럽히는 것이다. 과거 미국에서는 특허공개제도가 없었고, 또한 권리기간이 발행일 기산이었으므로, 출원인은 계속 출원을 이용함으로써 발명을 장기간 비공개로 할 수 있었다. 그러나 현재는 특허공개제도를 채용하고 있고, 권리기간의 출원일 기산으로 변경함에 따라 잠수함 특허의 출현 가능성은 낮다(Press Release, RIM,

일단 법원의 침해금지명령이 내려지면 'Patent Troll'은 손해배상액과 실시료에 대한 협상에서 유리한 지위를 확보하기 때문에 현실적으로 인정되는 손해배상액보다 훨씬 많은 막대한 자금을 특허권자에게 요구할 수 있다. 예컨대 수개의 특허 기술이 포함되어 있는 소프트웨어가 일반대중에서 널리 이용되고 있는 상태에서 그 소프트웨어의 운용에 절대적으로 필요한 일부 특허기술에 대해 금지청구를 당할 경우 침해자로서는 특허권자에게 막대한 로열티를 지불하고서도 특허권자의 금지청구를 피해야할 상황에 처하게 된다.¹¹⁸⁾

이러한 'Patent Troll'의 위협은 권리자를 두텁게 보호하는 미국에서 비롯되었으나, 세계 각국도 이러한 문제에 대한 우려에 직면하고 있다. 이와 같이 오늘날 'Patent Troll'이 야기하는 문제는 단순히 특허법을 악용한 'Patent Troll'이라는 새로운 비즈니스 모델의 특징적인 문제라고 볼 수만은 없다. 이러한 문제는 특허제도 자체가 처음부터 내재하고 있는 구조적 문제라고 할 수 있을 것이다.

II. 특허풀과 특허남용

1. 특허풀의 의의 및 종류

가. 특허풀의 개념

특허풀은 복수의 권리자가 각자 보유하는 특허나 이의 실시허락에 대한 일정한 권한을 일정한 기업체나 조직체에 집중해 해당 기업체나 조직체를 통해서 특허풀의 구성원 등이 필요한 실시허락을 받는 것이다.¹¹⁹⁾ 특허풀이 결성되면 중앙관리기관을 통하여 특허풀 참가자들 및 특허풀 밖의 제3자에게 실시허락을 하게 된다. 특허풀은 특히 다수의 특허가 존재하고 다수의 실시허락을 받고자 하는 자가 있는 경우에 효과적인 수단이 된다. 특허풀은 적게는 2개의 특허로 이루어지기도 하지만, 600개 이상의 특허로 구성된 Hartford-Empire 풀과 같이 몇 백개의 특허로 이루어지는 경우도 있다.¹²⁰⁾

Research In Motion and NTP Sign Definitive Settlement Agreement to End Litigation (Mar. 3, 2006)(http://www.rim.com/news/press/2006/pr-03_03_2006-01.shtml)참조).

118) 이주현, "Patent Troll의 특허권 남용에 대한 법적대응방안검토", 「Law & Technology」 (제5권 제1호), 서울대학교 기술과 법센터, 2009, 88면.

119) 정연덕, “특허풀에 관한 법적 연구-활성화 방안을 중심으로-”, 서울대학교 법학박사논문, 2005, 14면.

역사상 최초의 특허풀은 1856년의 재봉틀(sewing machine)관련 특허풀로 알려지고 있으며, 1908년에는 Armat, Biograph, Edison, Vitagraph 등 4개의 회사가 ‘영사기(movie projector) 특허풀’을 결성하여 제3자에 대한 로열티를 징수하였다. 1916년에는 접는 침대.bed)에 관한 특허풀이 형성되어 Seng社가 독점사용권을 부여받고 특허풀에 고정사용료를 지불하였고, 이를 특허권자들에게 분배하였다. 제1차 세계대전 중에는 미국정부가 당시 Wright사와 Curtiss사가 독점하고 있는 시장으로부터 항공기의 원활한 수급을 위해서 다른 회사들로 하여금 특허풀을 결성토록 우회 지원하였고, 1917년에 ‘항공기(air craft) 특허풀’이 형성되었다. 최근에는 MPEG LA, VIA Licensing, 1394 LA 등 IT 분야에서 다수의 특허풀이 결성 또는 논의되고 있다.¹²¹⁾

나. 특허풀의 발생 배경

특허를 받을 수 있는 대상의 범위가 점차 확대됨에 따라 수많은 특허가 수많은 특허권자들에게 각기 부여된 결과, 홀드업(hold-up)¹²²⁾, 특허 덩불(patent thicket)¹²³⁾, 비공유지의 비극(tragedy of anticommons)¹²⁴⁾, 차단특허(blocking patents)와 보완특허

120) 이대희, “특허풀 및 그 유효성에 관한 연구”, 「산업재산권」, 한국산업재산권법학회, 2004, 181면.

121) 전기억·박진우·최성진, “국내 특허풀의 결성전략에 관한 소고”, 「지식재산 21」(통권 제100호), 특허청, 2007, 75면.

122) ‘홀드업’은 ‘정지!’, ‘손들어!’ 등의 의미를 가진 말로서, 개발자가 특정 특허를 모르고 그 특허기술을 상업적으로 이용할 때 나타날 수 있다. 특허이용자가 그 특허의 존재를 알았었다면 그는 해당 특허를 우회하는 설계를 하거나 사업화 이전에 사용허락계약을 시도했을 것이다. 그러나 개발자가 이 특허가 등록되어 있다는 사실을 모른 채, 이 특허기술을 이용하여 상업 제품이나 방법을 개발하는 데 상당한 자원을 투자하였다면 그는 이제 약자의 위치에 있게 된다. 특허권자는 개발자의 투자비를 고려하여 고액의 로열티를 요구할 수도 있고 개발자의 회사를 조업 중단시키겠다고 위협할 수도 있다. 개발자가 늦게나마 그 제품을 재설계하고 싶어도 상호연동성, 표준, 그리고 호환성도 유지해야 할 뿐 아니라, 이미 연구개발이 상당히 진전된 상황이기 때문에 그 특허를 침해하지 않는 방식으로 재설계하는 것이 극히 어렵다. 이러한 경우 개발자는 특허권자에게 홀드업을 당할 수 있다(구대환, “특허풀의 결성과 운영”, 「저스티스」(통권 제109호), 2009, 195면).

123) ‘특허덩불’이란 일련의 중복하는 특허권이 존재하기 때문에, 새로운 기술을 상업화하려는 자가 복수의 특허권자로부터 사용허락을 취득하지 않으면 안 되는 상황을 말한다. 시장참가자는 이 ‘특허 덩불’을 제거하기 위하여 크로스라이선스와 특허풀이라는 자연스럽고 효과적인 방법을 사용하고 있다(구대환, 위의 논문, 196면).

124) “비공유지의 비극”은 너무 많은 사람들이 하나의 재산에 사적 소유권을 갖게 되면 권리들이 서로 충돌하여 누구도 그 재산을 사용하는 실질적인 권리를 가질 수 없게 되어 버린

(complementary patents)의 비용 등의 문제를 해결하기 위하여 특허풀을 결성하고 운용하기 시작하였다. 특허풀은 복수의 특허권자들의 특허기술을 활용하여야 제품의 생산이 가능한 경우 나타날 수 있는 홀드업(hold-up)의 문제를 해결하기 위하여, 혹은 특허분쟁을 해결하기 위한 시도로 특허소송과 더불어 형성되는 경우가 많다.

다. 특허풀의 종류

특허권의 종류 내지 성질은 특허풀의 구성과 관련하여 여러 가지로 분류할 수 있다. 하지만 통상적인 분류는 경쟁특허, 차단특허, 보완특허 등으로 나뉜다. 경쟁특허는 시장에서 대체재로서 기능하는 특허를 의미하며, 발명자가 기존의 제품과는 전혀 다른 신규한 것을 발명해 낸 경우나, 기존의 특허를 침해하지 않는 주변발명을 한 경우에 발생한다.¹²⁵⁾ 차단특허는 서로 상대방의 특허발명의 실시를 차단하는 역할을 하는 특허를 말한다. 다시 말해, 다른 사람의 특허발명을 실시하지 않고는 (즉, 다른 사람의 특허권을 침해하지 않고는) 자신의 특허발명을 실시할 수 없고, 그 반대의 경우도 성립하는 때 이들 특허발명을 차단특허라고 한다.¹²⁶⁾ 보완특허는 커다란 하나의 발명의 요소들을 서로 다른 발명자가 발명하였을 때 이들에게 부여된 특허를 말한다. 보완특허의 특허권자들이 서로 협력하지 않으면 보완특허 발명은 상업적으로 이용될 수 없다. 즉, 보완특허는 특허된 다른 발명들에 대한 사용허락을 취득할 수 없으면 쓸모없는 것이 되고 만다. 그래서 보완특허권자가 자신의 발명을 상업적으로 이용하기 위해서는 다른 모든 보완특허권자들로부터 사용허락을 받아야 하고, 제3자가 이들 보완특허 발명을 상업화하기 위해서는 모든 보완특허에 대한 사용권을 얻지 않으면 안 된다.¹²⁷⁾

상황을 일컫는다. 비공유지의 비극은 제품 개발자가 어떤 유용한 제품을 생산해내는 데 과도하게 많은 수의 특허를 이용해야 하고, 이들 특허발명에 대한 권리자가 모두 배타적 권리를 가지고 있어서 다른 사람의 이용을 배제할 권리를 가지고 있을 때 발생한다(구대환, 위의 논문, 198-200면).

125) 정연덕, 앞의 논문, 16면.

126) 특허권은 배타적 권리이기 때문에 타인이 자신의 특허를 허락없이 사용하는 것을 저지할 수 있다. 따라서 이들 두 특허는 특허권의 배타적 성격과 기술혁신의 연속적·누적적 특성 때문에 서로에게 차단특허로서 기능하게 되는 것이다. 한마디로 차단특허는 서로 이용관계에 있는 특허를 말한다(구대환, 위의 논문, 196면).

127) 구대환, 앞의 논문, 198면.

2. 독점규제 방지를 위한 특허풀 제한

특허권자들의 일괄 라이선스를 위한 특허풀은 라이선스 교섭비용을 없애고 기술혁신을 앞당기는 매우 중요한 경제적 효용성을 가진다. 반면에 특허풀의 구성 및 운영에 있어 독점규제법 가장 엄격히 금지하는 경쟁사업자간의 부당한 공동행위의 가능성이 증가하고 있다.¹²⁸⁾ 특허풀은 수평적 경쟁자들 간의 공모를 가능하게 함으로써 시장에 피해를 줄 수 있다. 경쟁하는 회사들에 의하여 특허풀이 형성된 경우 이러한 피해는 더 커질 수 있는데, 이 경우 특허풀은 여러 회사들을 수평적으로 합병시키는 효과를 가져오며 경쟁관계이어야 할 시장에 독점적 가격을 형성시킬 수 있게 되기 때문이다.¹²⁹⁾¹³⁰⁾ 독점금지법의 관점에서 특허풀이 가지고 있는 협조적 특징은 공동행위로 쉽게 전이될 수 있기 때문에 미국이나 우리나라의 경쟁당국 모두 특허풀의 친경쟁적 효과와 반경쟁적 효과를 모두 형량하도록 하고 있다.¹³¹⁾ 우리나라 공정거래위원회는 최근에 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」¹³²⁾을 전면 개정하여 2010. 4. 7.부터 시행하고 있는데, 개정 심사지침에서 제시하고 있는 대표적인 남용행위의 유형 중 하나로 ‘특허풀 관련 특허권 남용행위’를 포함시켜 규제하고 있다.¹³³⁾

동 지침에서의 특허권 남용의 유형으로는 ① 특허풀 운영과정에 이와 관련된 거래가격, 수량, 지역, 상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위, ② 부당하게 특허풀에 참여하지 않은 다른 사업자에 대한 실시를 거절하거나, 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하는 행위, ③ 특허풀 운영과정에 다른 사업자가 독자적으로 취득한 지식과 경험, 기술적 성과 등을 부당하게 공유하도록 하는 행위, ④ 부당하게 특허풀에 무효인 특허 또는 공동실시에 필수적이지 않은 특허를 포함시켜 일괄실시를 강제하는 행위, 특허풀에 포함된 각 특허의 실시료를 합산한 금액보다 현저히 높은 일괄실시료를 부과하여 실시권자에게 과도한 불이익을 제공하는 행위 등을 규제대상으로 하고 있다.¹³⁴⁾

128) 오승한, “EU경쟁법에 의한 특허권자의 특허풀 및 특허플랫폼에 대한 규제”, 「경쟁법연구」, 한국경쟁법학회, 2008, 173면.

129) 이대회, 앞의 논문, 191면.

130) 또한 구성된 특허풀을 라이선스하는 과정에서도 독점금지법에 포함된 특허권들을 기초자산으로 유동화하려고 하는 경우에는 유동화법제와 관련된 문제점들이 있다(최승재, “IT 기술 혁신을 위한 특허풀의 유용성과 전망-미국 사례를 중심으로-”, 「IT와 법 연구」(제3집), 경북대학교 IT와 법 연구소, 2009, 13면).

131) 최승재, 위의 논문, 13면.

132) 공정거래위원회 예규 제80호.

133) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」Ⅲ.2.가.

이와 같이, 특허풀의 순기능도 있으나 특허풀을 통한 특허권 남용행위가 발생할 경우에는 다수의 특허권의 공동 독점현상을 초래하게 되어 결국 지나친 독점에 의한 기술혁신이나 기술 활용을 저해하는 결과를 야기하게 된다. 이러한 점에 있어서는 특허풀의 경우에도 특허제도가 가지고 있는 일정한 한계를 드러내는 것이라고 볼 수 있을 것이다.

III. 정리

이상으로 'Patent Troll'과 '특허풀'에 의한 특허권 남용현상에 대하여 살펴보았다. 'Patent Troll'이 야기하는 문제는 단순히 특허법을 악용한 새로운 비즈니스 모델의 특징적인 문제라고 볼 수 없다. 이는 특허제도가 탄생할 때, 미처 상정하지 못한 즉 특허제도 자체가 가지고 있는 내재적 문제점이라고 할 수 있을 것이다.

또한 특허풀의 경우에도 이용저촉관계에 있는 경쟁자들 사이의 특허문제를 해결해 주고, 거래비용을 감소시켜 주며, 신속하게 기술발전을 촉진시킬 수 있다는 점에서 산업발전에 긍정적으로 작용하기도 한다. 그러나 한편으로 특허풀은 복수의 권리자가 공동으로 라이선싱 행위를 한다는 점에서 경쟁을 제한하거나 저해하는 부정적인 측면도 존재한다. 이러한 남용행위로 인하여 기술발전 및 관련 산업발전 도모를 목적으로 하는 특허법의 취지가 몰각될 수 있으며, 이는 결국 건전한 시장질서 확립에 걸림돌로 작용할 수 있다. 즉 특허풀 제도의 순기능에도 불구하고, 이를 악용한 남용이 발생할 경우에는 공동특허에 의한 공동 독점현상을 초래할 수 밖에 없게 된다. 이 경우 특허제도가 염두해 두지 않았던 지나친 독점에 의한 기술혁신이나 기술 활용을 저해하게 되고, 이는 특허제도가 드러내는 문제점이라 할 수 있을 것이다.

134) 하지만 이와 같은 예시가 절대적인 것은 아니며, 공정거래 저해효과와 효율성 증대효과를 비교형량하여 위법성 여부를 판단하고 있으므로, 행위의 목적, 태양, 경쟁에 주는 영향의 크기에 따라 남용행위 여부가 달라질 수 있다(지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 II.2.다.- 지식재산권 행사가 공정거래저해효과와 효율성 증대효과를 동시에 발생시키는 경우에는 양 효과의 비교형량을 통해 법 위반 여부를 심사함을 원칙으로 한다. 해당 행위로 인한 효율성 증대효과가 공정거래저해효과를 상회하는 경우에는 위법하지 않은 행위로 판단할 수 있다. 단, 법 제29조의 재판매가격유지행위 중 최저가격유지에 해당하는 행위는 공정거래저해효과와 효율성 증대효과에 대한 구체적인 분석 없이 위법한 것으로 본다. 법 제23조 제1항 제3호 중 위계(偽計)에 의한 고객유인에 해당하는 행위는 위법성 판단 시 효율성 증대효과를 고려하지 않음을 원칙으로 한다.).

제4절 소결

이상으로, 오늘날 특허제도와 관계된 논의와 문제들을 살펴보았다. 공익, 기술혁신과 관계된 특허제도의 한계, 그리고 특허제도를 남용한 독점에 폐해도 특허제도의 한계를 드러는 현상이라고 볼 수 있다. 지식기반 경제사회에 있어서 지식재산은 성장을 위한 자유 자원으로 인식되어 왔으며, 특허 보호대상 및 범위의 확대는 신기술 개발 및 관련 연구에 대한 유인을 제공한다고 생각되어 왔다. 이러한 인식은 1970-80년대 정책입안자들과 정치가들을 비롯하여 여러 경제학자들에 의해 법률적이고 경제적인 근거와 토대를 마련하는 기초가 되었다.

그러나 20세기에 접어들면서, 과학기술의 발전과 경제성장간의 연관관계에 대하여 공공재와 지식의 사유화가 반드시 사회 전반의 이익에 부합하지 않을 수 있다는 반론이 제기되기 시작하였다. 지재권 특히 특허권의 독점적 활용이 강조되면서 특허소송 및 라이선싱을 통한 로열티 및 비용의 증가는 후속 혁신을 저해하고 있다.¹³⁵⁾ 또한 인간유전자에 특허를 부여함으로써 예전에는 특허의 대상이라고 생각하지 않았던 공공영역이 사유화 되어가는 문제나 20여년 전만해도 대부분의 학자들이 특허될 수 없는 것이라고 생각했던 아이디어에 특허가 부여되는 등 특허의 보호대상이 무리하게 확대되는 현상은 모두 특허권제도의 폐해로 지적되고 있다.¹³⁶⁾

최근 지식재산이 갖는 도덕적 가치 인식이 점차 확산되면서 지식과 기술, 혁신을 공유하면서 사적 이익과 공적 이익의 균형이루는 방법에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있으며, 실제로 기업들 간에 기술개방 및 공유를 통한 개방형 혁신을 이룩하는 사례가 많아지고 있다. 그 대표적인 사례가 ‘Eco-Patent Commons’과 ‘오픈소스 SW’ 등이라고 할 수 있다. 이러한 운동은 기존의 특허제도를 전면 부인하자는 것도 특허권을 완전히 기부하거나 포기하는 것도 아니다. 이것은 "특허권비행사 서약(patent pledge)"¹³⁷⁾이라

135) 기존의 지식재산권 제도는 원래 정책결정자나 학자들의 예상과는 달리 혁신을 보호하는 메커니즘으로 현실적인 한계가 드러나고 있다고 할 수 있으며, 혁신자의 사적인 혜택(private benefit)이 혁신으로 인한 사회 공적인 혜택(public benefit)보다 커지고 오히려 후속 혁신을 저해하는 현상이 나타나고 있다(김영배, “사용자 혁신(User Innovation)과 기술공유: 혁신의 새로운 추세”, 「IP Policy」(통권 제3호), 한국지식재산연구원, 2010, 23면).

136) 정연덕, “공공기술의 사유화와 기술공유”, 「IP Policy」(통권 제3호), 한국지식재산연구원, 2010, 37면.

137) 1인 혹은 복수의 자에 대하여 특허기술의 실시를 이유로 침해를 주장하지 않겠다는 공공의 선언.

고 하여 자신의 권리는 유지하면서 다른 사람이 자신의 권리를 사용할 경우 일정한 제한이 가능한 것을 말하는 것으로 기존의 개념과 구분되는 새로운 형태라 할 수 있다.¹³⁸⁾ 현행 특허제도를 유지하면서도 보완책으로써 기술공유 운동을 통해 특허제도의 폐해를 극복하고 기술혁신을 도모하면서, 더 나아가 공공의 이익을 추구하고 기업의 사회적 책임을 다하겠다는 의지라고 할 수 있다.

산업 발전을 위해 탄생한 특허제도는 지금까지 충분한 역할을 해 왔고, 특허제도가 산업의 발전, 넓게는 인류의 발전을 저해하는지 여부에 대해서는 명확한 근거는 없다. 다만, 오픈 이노베이션, 공중보전, 환경 등이 중요해진 현 시점에서는 현행 특허제도의 한계를 보완할 새로운 장치가 필요해졌다. 특히 환경문제나 인류의 건강과 관련된 영역에 대해서는 기술공유의 필요성이 더욱 높아지고 있는 실정이다. 따라서 기술공유제도의 도입에 대한 적극적인 검토가 필요하다.

138) 신지연, 기술공유화에 대한 정책적 논의(Policy Focus 전문가 좌담회 토론회), 「IP Policy」, 한국지식재산연구원, 2010, 16면.

제4장 기술공유제도에 대한 설문조사

제1절 설문조사 실시 목적 및 개요

I. 설문조사 실시 목적

한국지식재산연구원은 특허제도 보완을 위해 국내 학계·산업계·연구계 등의 기술 공유화 전문가 집단을 대상으로 특허제도의 문제점과 이를 보완하기 위한 관련 제도 및 정책에 대한 의견을 수렴하고자 ‘기술공유화’에 관한 인식조사 및 법·정책적 방향성을 조사하였다. 설문 조사의 목적은 의약품 및 리서치 툴 관련 특허의 독점, 환경(기후변화)관련 특허의 독점으로 인한 문제, Patent troll(특허권 비실시자의 특허권 행사) 등 기존 특허제도의 문제들을 해결하는 방안으로서 특허제도를 보완하기 위하여 각계의 전문가 분들의 의견을 수렴·분석을 통하여 특허제도를 보완하기 위한 제도적·정책적 방안을 모색하는 데 있다.

II. 설문조사의 개요

본 설문조사는 특허제도의 보완책으로써 기술공유제도 도입에 관한 의견 수렴을 위하여 약 보름간(2010. 12. 1 - 17) 실시되었으며, 법대 및 공대 교수, 과학기술 관련 연구원 및 진흥원 담당자, 기업의 IP 담당자, 시민단체 대표, 변리사 등 각계 전문가 20인을 대상으로 하였다.

본 조사는 “기술 공유에 대한 인식조사에 대한 설문”과 “특허제도를 보완하기 위한 법제도 및 정책적 방향성 조사에 대한 설문”으로 나누어 진행되었다. 기술 공유에 대한 인식조사에 대한 조사는 “(1) 현행 특허제도의 문제점, (2) 특허제도 보완을 위한 기술공유의 필요성 및 도움이 되는 부문, (3) 기술공유에 대한 사례 인지도와 활용 경험 및 효과, (4) 기술공유의 지지도 및 활용분야, (5) 공익 관련 정부 주도의 기술공유 정책에 대한 동참의향”을 그 내용으로 하고 있다.

한편, 특허제도를 보완하기 위한 법제도 및 정책적 방향성 조사는 “(1) 특허법상 공익관련 특허실시제도의 인지도, (2) 공익관련 특허 실시제도의 효율성, (3) 특허법상 공익관련 특허 실시제도의 확대 의견, (4) 정책적 측면에서의 제도보완의 방향성 및 적절

한 수단”을 중심으로 설문을 실시하였다.

그 밖에 공익과 혁신의 관점에서 향후 특허제도를 보완하기 위한 방안과 산업발전 측면에서 특허제도가 나아가야 할 방향이 무엇인지에 대한 기타 의견을 수렴하였다.

본 설문은 학계나 연구계의 경우, 실제 특허·기술공유, 강제실시권, 오픈소스 등에 관심을 갖고 있거나 관련 연구 및 업무에 종사하고 있는 전문가들만을 설문조사 대상으로 선별하여 실시하였다. 그러나 모집단의 개체 수가 매우 적은 점, 산업계의 경우 대기업을 제외하고, 기술공유실시 기업이 드물거나 현황파악이 곤란한 점 등은 본 조사의 한계라고 할 수 있을 것이다. 본 설문은 구조화된 설문지를 활용하여, 개별면접조사 형태로 행해졌으며 이메일, FAX 조사도 병행하였다.

<표 IV-1> 조사 설계의 내용

조사 설계	
자료 수집 방법	구조화된 설문지를 활용한 개별 면접조사 (이메일, fax 조사 병행)
모집단	학계/ 산업계/ 연구계/ 기타
조사 대상	기술공유화 관련 전문가 집단
조사 기간	2010년 12월1일 ~ 12월17일
조사 샘플 수	N=20

제2절 설문 항목별 조사 결과 및 분석

I. 특허제도의 문제점과 기술공유에 대한 인식

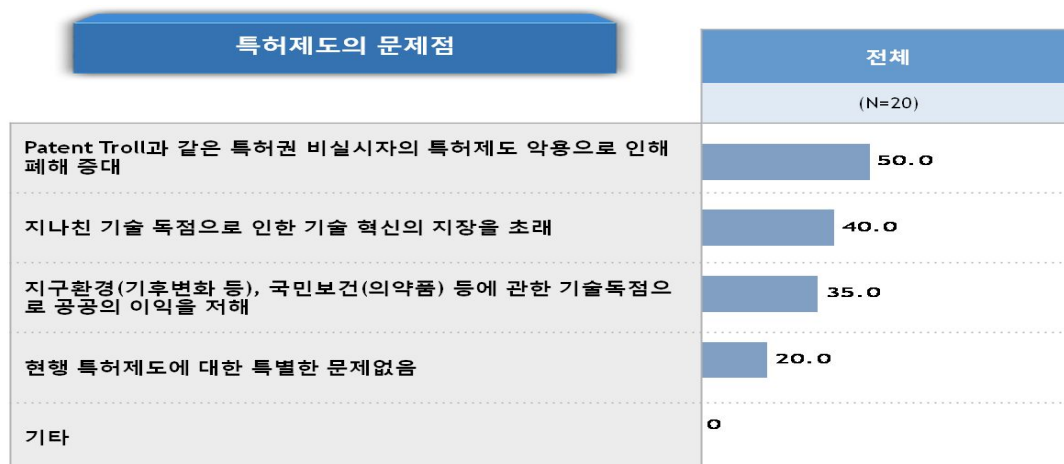
1. 특허제도의 문제점 조사

설문1. 귀하는 현행 특허제도의 문제점을 무엇이라고 생각하십니까?(복수응답가능)

- ① 지나친 기술 독점으로 인한 기술 혁신의 지장을 초래
- ② 지구환경(기후변화), 국민보건(의약품) 등에 관한 기술 독점으로 공공의 이익을 저해
- ③ Patent Troll과 같은 특허권 비실시자의 특허제도 악용으로 인해 피해 증대
- ④ 현행 특허제도에 대한 특별한 문제없음
- ⑤ 기타()

국내 학계·산업계·연구계의 기술공유화 전문가 집단을 대상으로 한 현행 특허제도의 문제점에 대한 복수 응답한 결과를 보면, 특허괴물과 같은 특허권 비실시자의 특허제도 악용으로 인해 피해가 증대한다는 응답이 50%, 지나친 기술 독점으로 인한 기술 혁신에 지장을 초래한다는 응답이 40%, 기후변화 등의 지구환경과 의약품 등의 국민보건 등에 관한 분야에 기술독점으로 인해 공공의 이익을 저해한다는 응답이 35%로 나타났다. 반면에 위와 같은 문제점과 달리 현행 특허제도에 대해 특별한 문제가 없다는 응답이 20%를 차지하여 현행 특허제도의 문제점에 대해 인식을 하지 못하는 경우도 있는 것으로 나타났다(그림 IV-1 참조).

<그림 IV-1> 특허제도의 문제점



<그림 IV-1>은 현행 특허제도의 가장 큰 문제점으로 Patent Troll¹³⁹⁾과 같은 특허권 비실시자의 특허제도 악용으로 인한 피해를 들고 있다. 특히 우리나라 대기업의 경우, Patent Troll에 의한 특허소송 수난시대를 맞고 있다는 보도 자료를 자주 접할 수 있는데,¹⁴⁰⁾ 본 설문 결과의 결과는 이러한 실태를 그대로 반영한 것이라 할 수 있다.

또한 지나친 기술 독점으로 인하여 기술혁신을 저해한다는 응답도 40%를 차지하고 있는데, 이러한 결과는 20세기부터 선진국을 중심으로 강화되어 왔던 특허정책 및 산업정책에 의하여 특허권의 사유화가 지나치게 되어 홀드업의 문제나 비공유지의 비극과 같은 특허권의 폐해가 증가하고 이에 대한 비판이 제기되고 있는 것과 같은 맥락이라 할 수 있을 것이다.

2. 기술 공유의 필요성 및 기술공유가 도움이 되는 부문

설문2. 특허제도를 보완하기 위해 특정분야의 기술 공유가 필요하다고 생각하십니까?

- ① 그렇다 ② 아니다(☞문4로 이동)

설문3. 기술 공유(특허 공유)가 어떤 면에서 도움이 된다고 생각하십니까?(복수응답가능)

- ① 기술 공유를 통한 기술혁신
 ② 기술 개발에 따른 비용 절감
 ③ 불필요한 특허권 침해 소송 예방
 ④ 인간의 삶과 밀접한 분야의 공공의 이익 달성
 ⑤ 기타()

설문4. 기술 공유(또는 특허 공유)가 도움이 되지 않는다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

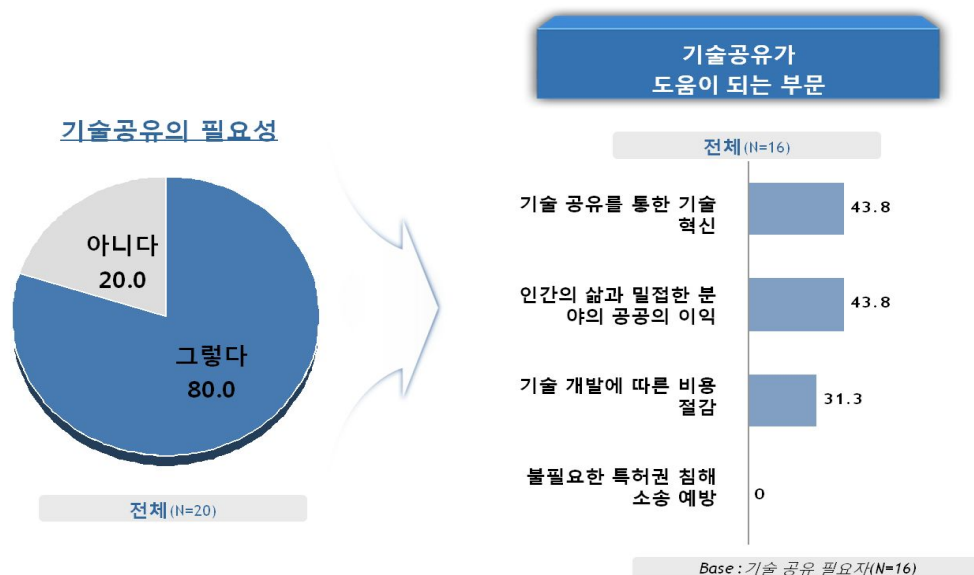
- ① 기술 공유보다는 독점권 보장을 통해 기술 혁신이 가능하므로
 ② 기술 공유가 자칫 기술의 하향평준화를 초래할 수 있으므로
 ③ 권리자에게 부여되는 독점 배타권은 특허권 등의 지식재산권 본질이므로 권리자에게 공익 추구를 강요하는 것 자체가 모순이므로
 ④ 기술 공유가 관련 산업발전에 미치는 실효성이 부족하므로
 ⑤ 기타()

139) Patent Troll은 자신이 직접 발명을 실시할 의지가 없이 단순히 거액의 로열티나 손해배상액을 요구하기 위하여 돈이 될만한 특허기술들을 매입하는 자를 지칭하는 말로 2000년 초부터 최근까지 특허권 남용과 관련한 문제로 많은 비판이 있어왔다.

140) 삼성은 최근 5년 동안 피소 건수 세계 1위, LG는 6위라는 언론자료를 통해서도 알 수 있듯이 국내 대기업을 상대로 한 Patent Troll의 위협은 매우 크다고 할 수 있다(세계일보 2009. 09.28일자 참조).

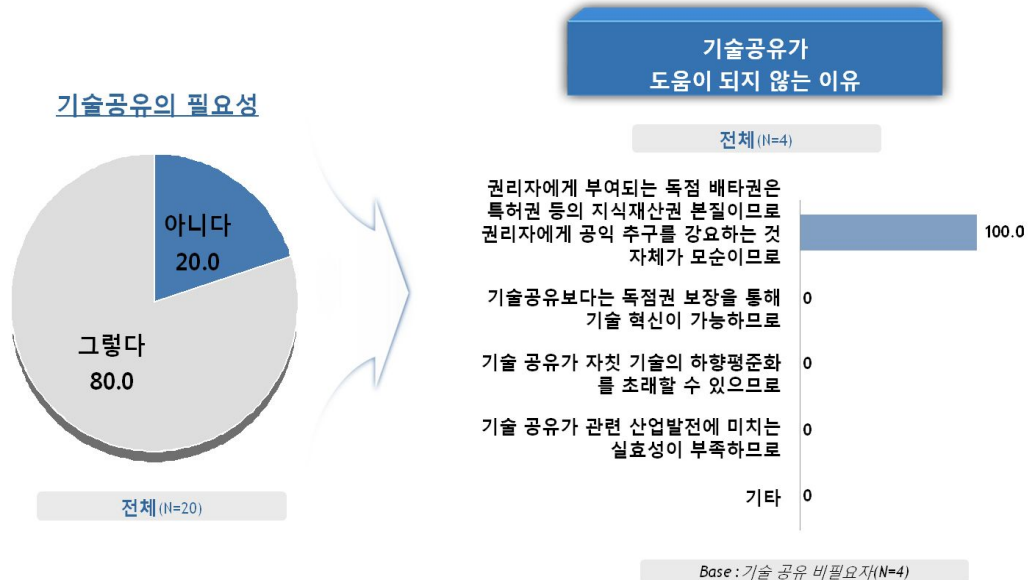
<아래 그림 IV-2>에서 보는 바와 같이 특허제도를 보완하기 위해 특정분야의 기술공유 필요성에 대한 설문에서는 특정분야의 기술공유가 필요하다는 의견이 80%를 차지하여 전체 응답자 대부분이 특정분야에 대한 기술공유의 필요성을 찬성하고 있는 것으로 파악되었다. 이들의 찬성 이유로는 기술공유를 통하여 기술혁신을 도모할 수 있다는 의견과 인간의 삶과 밀접한 분야에서 공공의 이익을 달성할 수 있다는 의견이 각각 43.8%로 나타났다. 또한 기술 개발에 따른 비용절감에 기술공유가 도움이 된다고 하는 응답도 31.3%로 나타나 이 역시 기술공유를 통해 얻을 수 있는 장점으로 인식될 수 있음을 알 수 있다.

<그림 IV-2> 기술공유의 필요성 및 기술공유가 도움이 되는 부문



한편, 기술공유가 필요하지 않다고 응답한 20%의 응답자 모두는 기술공유가 도움이 되지 않는 이유에 대해서 권리자에게 부여되는 독점 배타권은 특허권 등의 지식재산권이 가지는 본래의 특성이므로 권리자에게 공익추구를 강요하는 것 자체가 모순이라고 응답하였다. 이는 기술공유제도의 도입이 특허제도의 근간을 훼손할 가능성이 있다는 인식하에 이러한 응답이 나온 것으로 예측된다(그림 IV-3 참조).

<그림 IV-3> 기술공유가 도움이 되지 않는 이유



3. 기술공유에 대한 사례 인지도와 활용 경험 및 효과

설문5. 실제 기술 공유에 대한 사례를 알고 계시거나, 기술 공유를 활용하신 경험이 있으십니까?

- ① 예 ② 아니오(→문8로 이동)

설문6. 기술 공유의 활용가치는 어느 정도라고 생각하십니까?

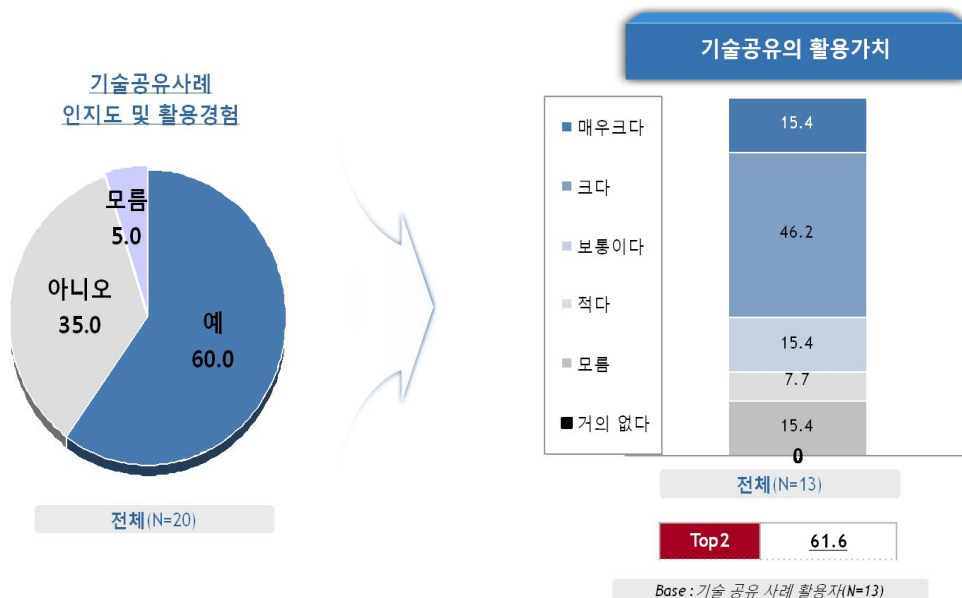
- ① 매우 크다 ② 크다
③ 보통이다 ④ 적다
⑤ 거의 없다

설문7. 기술 공유(혹은 저작권 공유)제도의 활용하여 결과적으로 어떠한 측면에서 효과를 보셨습니까?

- ① 기술 개발에 드는 시간·비용의 절감
② 풍부한 연구자료 확보를 통한 후속연구 활성화
③ 기술혁신 활성화
④ 기타()

<아래 그림 IV-4>는 기술공유에 대한 인식 및 활용 여부에 대한 조사 결과이다. 기술 공유 사례를 알고 있는 경우는 95%로 대부분 인지하고 있는 것으로 나타났으며, 실제 기술공유제도를 활용한 경험에 있는 응답자는 60%로 전체의 절반 이상을 차지하고 있다. 또한 기술공유제도의 활용가치에 대해 '매우 크다'고 응답한 경우가 15.4%, '크다'의 경우가 46.2%로 전체의 약 61.6%가 그 활용가치에 대해 높게 평가하고 있는 것으로 나타났다.

<그림 IV-4> 기술공유사례 인지도 · 활용경험 및 활용가치

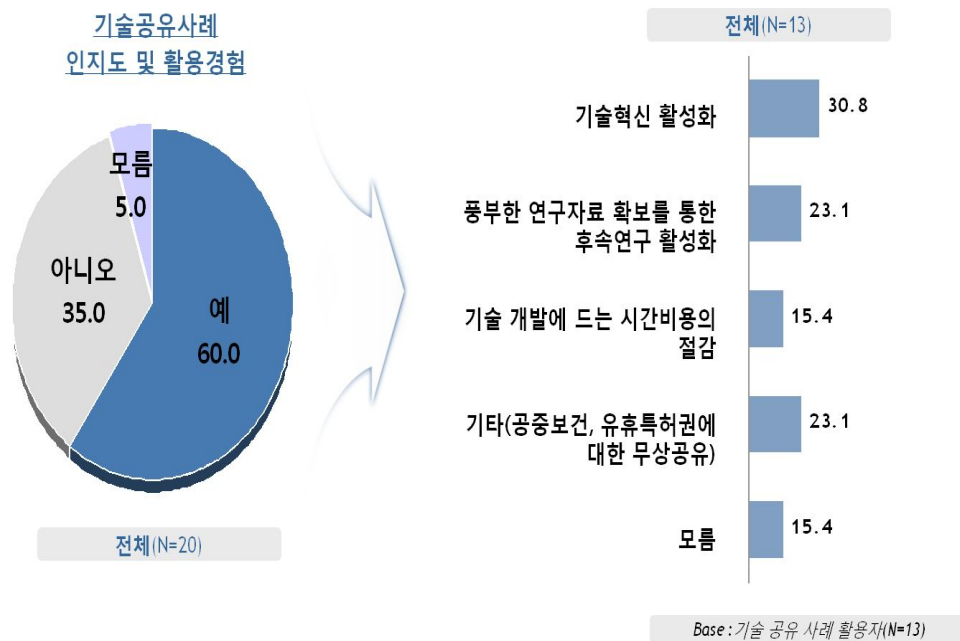


<아래 그림 IV-5>는 기술 공유(혹은 저작권 공유)를 활용하여 어떠한 측면에서 효과를 보았는지에 대한 결과를 나타내고 있다. 기술혁신 활성화에 도움이 된다는 의견이 30.8%로 가장 많은 응답을 차지하고 있으며, 풍부한 연구자료 확보를 통하여 후속연구 활성화에 기여하였다는 응답이 23.1%로 그 뒤를 이었다. 또한 기술개발에 드는 시간비용이 절감되었다는 응답이 15.4%로 나타났으며, 공중 보전에 기여했다는 의견과 유희 특허권에 대한 무상공유를 추진했으나 큰 효과는 없었다는 기타 의견도 있었다.

설문3에서 기술공유가 필요한 이유에 대하여 43.8%가 기술혁신 도모라고 응답한 설문 결과와 연관지어 생각해 보건대, 설문 응답자 중 상당수가 기술공유 도입의 장점 및 도입 후 얻을 수 있는 효과로 '기술공유화를 통한 기술혁신'을 기대하고 있다고 할 수 있다. 따라서 다양한 산업 분야 중에서도 관련 산업 또는 경쟁 업체와의 기술 개방

및 공유를 통해 기술혁신을 통한 이익을 얻을 수 있는 분야에서 기술공유제도를 활용할 가능성이 클 것으로 판단된다.

<그림 IV-5> 기술공유제도의 활용효과



4. 기술공유의 지지 및 활용 분야

설문8. 귀하는 앞으로 특허제도를 보완하기 위하여 기술 공유를 적극적으로 지지할 계획이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오(☞문10으로 이동)

설문9. 기술 공유 개념을 적용하기에 가장 적합한 산업 분야는 무엇이라고 생각하십니까?(복수응답 가능)

- ① 제조업 분야 ② 제약 분야
③ 생명공학 분야 ④ 에너지 분야
⑤ 환경 분야 ⑥ IT 분야
⑦ 기타()

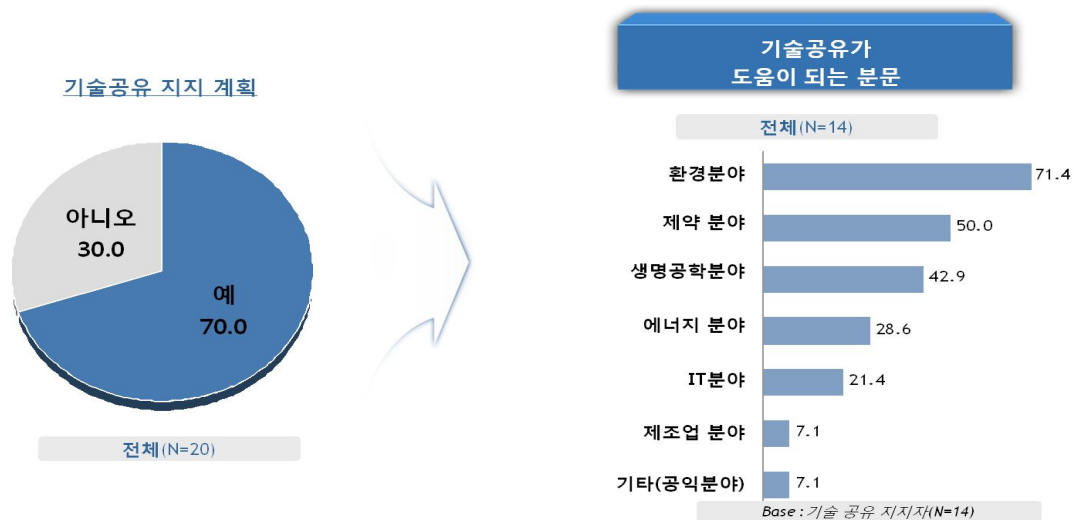
설문10. 기술 공유에 관한 정책을 적극적으로 지지하지 않는 이유는 무엇입니까?

- ① 기술공유에 관한 정책이 특허제도를 형해화 시킬 가능성이 있으므로
- ② 또 다른 법적 분쟁을 야기할 소지가 크므로
- ③ 국가 경쟁력 차원에서 현행 특허제도를 유지하는 것이 바람직하므로

- ④ 정부 주도의 기술공유 정책보다는 민간 차원의 자발적인 기술공유 운동으로 충분하므로
- ⑤ 현행 특허제도의 보완(강제실시권 확대 등)으로 충분하므로
- ⑥ 기타()

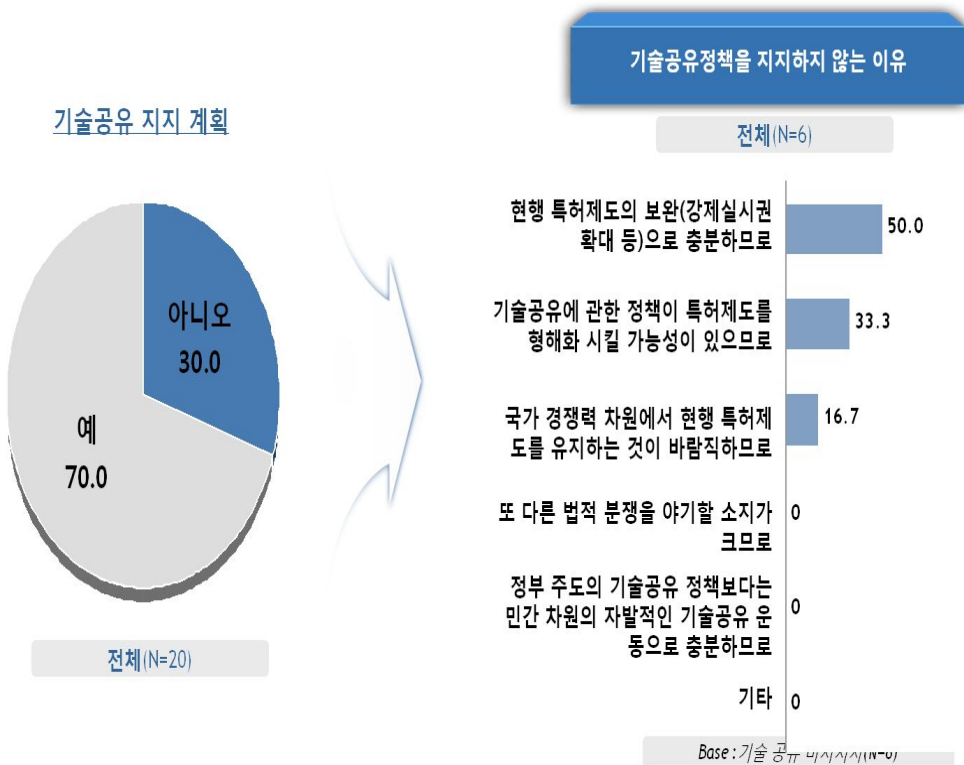
<아래 그림 IV-6>은 특허제도를 보완하기 위하여 향후 기술 공유 지지 여부 및 기술 공유를 적용하기에 가장 적합한 산업분야의 조사에 대한 설문결과이다. 앞으로 특허제도를 보완하기 위하여 기술공유를 적극적으로 지지할 것이라 응답한 수는 전체의 70%를 차지하고 있으며, 그 중 기술공유를 적용하기에 가장 적합한 산업 분야는 환경 분야가 71.4%로 가장 높게 나타났다. 그 다음으로 제약 분야가 50%, 생명공학 분야가 42.9%를 차지하였다. 제조업, IT, 에너지 분야에 비하여 환경, 제약, 생명공학 분야에서 더 높은 비율의 응답이 나온 것으로 보아, 지구온난화와 기후변화라는 전지구적 환경 문제로 인식되어 꾸준히 활발한 논의가 되고 있는 환경 분야, HIV/AIDS, 결핵, 말라리아와 같은 전염병과 최근 들어 크게 문제가 되고 있는 신종인플루엔자 등 인간의 생명과 건강을 담보로 하고 있는 의약품과 같은 보건분야, 유전자 공학과 같은 생명공학 분야 등의 공익 부문에 대한 기술공유제도 도입의 기대가 큰 것으로 생각된다.

<그림 IV-6> 기술공유제도의 지지도 및 활용분야



한편, 기술 공유제도를 지지하지 않는다는 응답자 30%는 기술공유를 지지하지 않는 이유에 대하여 강제실시권의 확대 등과 같이 현행 특허제도의 보완만으로도 충분하다는 응답이 50%, 기술공유에 관한 정책이 특허제도를 형해화시킬 가능성이 있다는 응답이 33.3%로 나타났다. 이와 더불어 국가경쟁력 차원에서 현행 특허제도를 유지하는 것이 바람직하다는 의견은 16.7%에 그쳤다. 이는 기술공유제도 도입에 대한 우려의 목소리로 볼 수 있으므로 특허제도에 대한 보완책으로서 기술공유제도 도입이 우리나라 현행 법제도 및 산업 환경에 적합한지에 대한 검토가 필요하다는 점을 시사한다(그림 IV-7 참조).

<그림 IV-7> 기술 공유제도를 지지하지 않는 이유



5. 공공의 이익 관련 정부 주도의 기술공유 정책

설문11. 기술 공유는 위에서 언급한 민간 차원의 노력뿐만 아니라, 국제기구 및 정부차원에서 공공 분야의 지식재산 관련 정책의 일환으로 논의되는 경우도 있습니다. 가령, 보건·환경·식품 등의 공공정책과 지식재산권의 조화를 위한 WIPO의 국제회의 개최, UN 기후 변화 협약에서의 기술 공유화 논의, OECD의 ‘유전자관련발명의 라이선스 공여에 관한 가이드라인’ 제정, 일본의 ‘라이프사이언스 분야에 있어서 리서치툴 특허의 사용 원만화에 관한 지침’ 제정 등이 있습니다. 만약, 우리나라에서 보건·환경 등의 공공의 이익과 관련된 문제를 해결하기 위하여 정부 주도의 기술 공유정책을 추진한다면 귀하는 적극적으로 동참할 생각이 있습니까?

- ① 예(☞문13로 이동) ② 아니오 ③ 잘 모르겠다

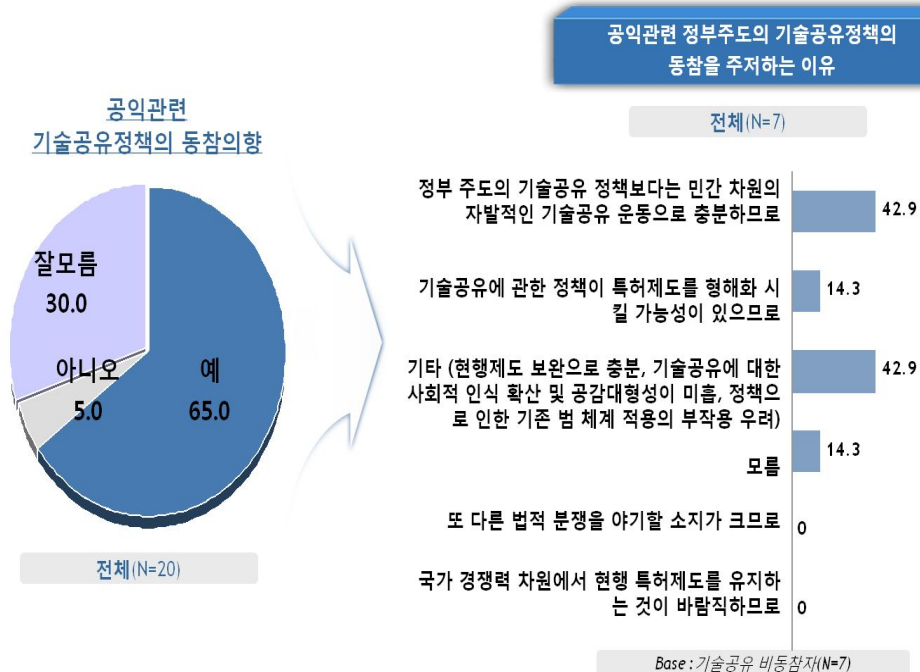
설문12. 공익과 기술 혁신을 위한 정부 주도의 기술 공유 정책의 추진임에도 불구하고 귀하께서 적극적 동참을 주저하시는 이유는 무엇입니까?(복수응답가능)

- ① 기술공유에 관한 정책이 특허제도를 형해화 시킬 가능성이 있으므로
 ② 또 다른 법적 분쟁을 야기할 소지가 크므로
 ③ 국가 경쟁력 차원에서 현행 특허제도를 유지하는 것이 바람직 하므로
 ④ 정부 주도의 기술공유 정책보다는 민간 차원의 자발적인 기술공유 운동으로 충분하므로
 ⑤ 기타()

보건·환경 등 공공의 이익과 관련된 문제를 해결하기 위하여 정부 주도 하에 공공 분야에 대한 기술공유 정책을 추진하는 것에 대하여 동참 의사를 조사한 결과, 65%가 동참 의사를 밝혔고, 30%는 잘 모르겠다고 답하여 전체 응답자의 과반수 이상이 정부 주도의 기술공유 정책 추진을 긍정적으로 보고 있는 것으로 파악된다.

반면, 동참하지 않겠다고 답한 5%의 응답자 중 약 43%가 동참하지 않는 이유에 대하여, 정부 주도의 기술공유 정책 추진 보다 민간 차원의 자발적인 기술공유 운동 추진이 바람직하다고 보았다(그림 IV-8 참조).

<그림 IV-8> 공익관련 기술공유정책의 동참의향



II. 기술 공유 관련 법제도 및 정책

1. 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 인지도

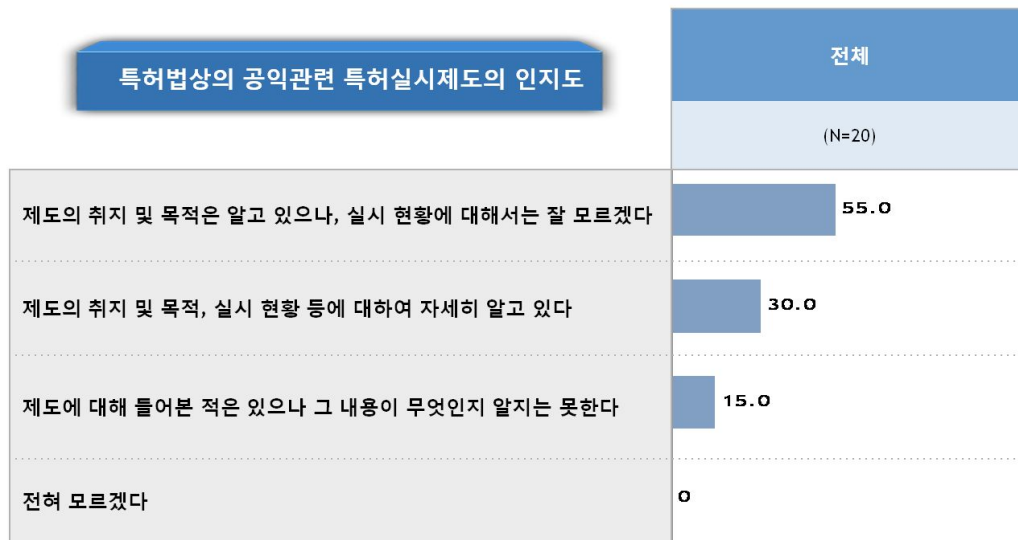
설문13. 귀하는 위와 같은 특허법상의 공익관련 특허실시제도에 대하여 알고 계십니까?

- ① 제도의 취지 및 목적, 실시 현황 등에 대하여 자세히 알고 있다
- ② 제도의 취지 및 목적은 알고 있으나, 실시 현황에 대해서는 잘 모르겠다
- ③ 제도에 대해 들어본 적은 있으나 그 내용이 무엇인지 알지는 못한다
- ④ 전혀 모르겠다

<아래 그림 IV-9>는 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 인지도에 관한 설문결과를 나타내고 있다. 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 취지 및 목적은 알고 있으나, 실시 현황에 대해서는 잘 모르겠다고 답한 응답자는 55%, 제도의 취지 및 목적, 실시 현황 등에 대하여 자세히 알고 있다는 응답자는 30%로 나타났다. 반면 15%는 제도에 대

해 들어본 적은 있으나 그 내용이 무엇인지 알지는 못한다고 응답하였다. 대체적으로 본 제도에 대해 취지 및 목적은 정확히 판단하고 있는 반면, 응답자 중 과반수 이상의 응답자가 실시 현황에 대해 인식이 부족한 것으로 나타났다.

<그림 IV-9> 특허법상 공익관련 특허실시제도의 인지도



2. 공익관련 특허 실시제도의 효율성

설문14. 현재 위와 같은 공익관련 특허 실시제도가 효율적으로 시행되고 있다고 생각하십니까?

- ① 그렇다(☞문16로 이동) ② 그렇지 않다

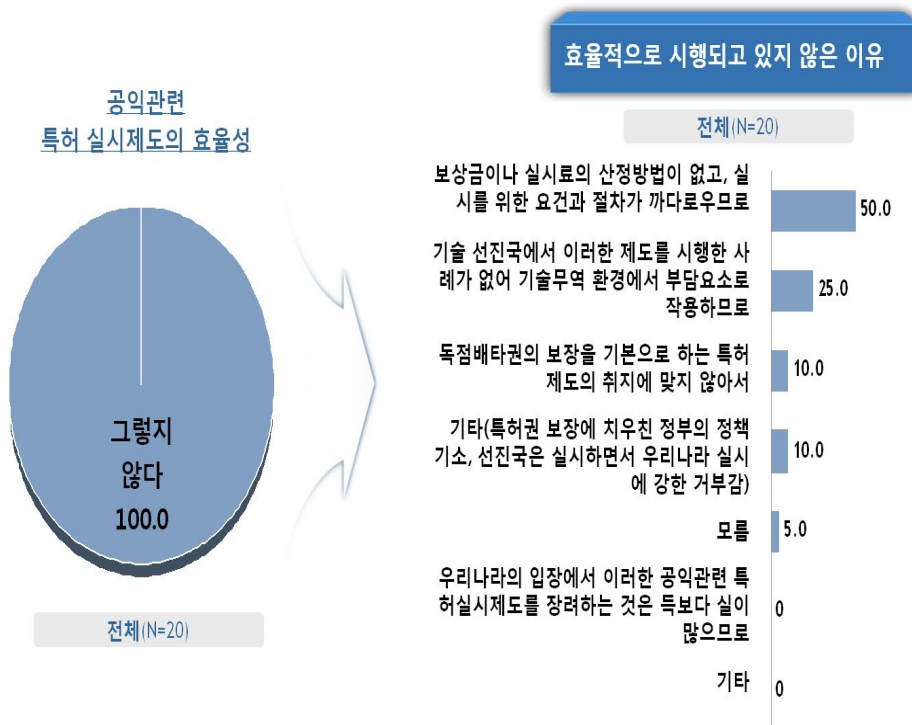
설문15. 공익관련 특허 실시제도가 효율적으로 시행되고 있지 않다면 그 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 독점배타권의 보장을 기본으로 하는 특허제도의 취지에 맞지 않아서
 ② 기술 선진국에서 이러한 제도를 시행한 사례가 없어 기술무역 환경에서 부담요소로 작용하므로
 ③ 우리나라의 입장에서 이러한 공익관련 특허실시제도를 장려하는 것은 득보다 실이 많으므로
 ④ 보상금이나 실시료의 산정방법이 없고, 실시를 위한 요건과 절차가 까다로우므로
 ⑤ 기타()

<아래 그림 IV-10>에서 보는 바와 같이, 공익관련 특허 실시제도가 효율적으로 시행되고 있는지 여부에 대해서는 응답자 전원이 효율적으로 시행되고 있지 않다고 응답하였고, 그 이유로는 보상금이나 실시료의 산정방법이 없고 실시를 위한 요건과 절차가 까다롭다는 답변이 50%를 차지했다. 이 외에 기술 선진국에서 이러한 제도를 시행한 사례가 없어 기술무역 환경에서 부담요소로 작용하기 때문이라는 응답이 25%, 독점배타권의 보장을 기본으로 하는 특허제도의 취지에 맞지 않는다는 응답이 10%로 나타났다.

기타 의견으로는 특허권 보장에 치우친 정부의 정책기조 때문이라는 의견과 선진국은 실시하지 않는데 반해, 우리나라가 실시하는 것에 대해서는 강한 거부감을 갖는 등의 통상마찰 때문이라는 의견도 나왔다. 이러한 설문결과를 통해, 공익관련 특허 실시제도의 효율적인 시행을 위하여 보상금 또는 실시료 산정방법을 마련하도록 해야 할 것이며, 특허 실시에 관한 요건을 정비하고 이에 대한 절차적 용이성을 확보할 수 있는 개선방안이 마련되어야 한다고 판단된다.

<그림 IV-10> 공익관련 특허실시제도의 효율성



3. 특허법상 공익관련 특허 실시제도의 확대 의견

설문16. 기후변화 및 지구온난화 등의 환경문제와 공중위생 문제(의약품 등) 등의 공공 분야에 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 범위를 확대하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까?

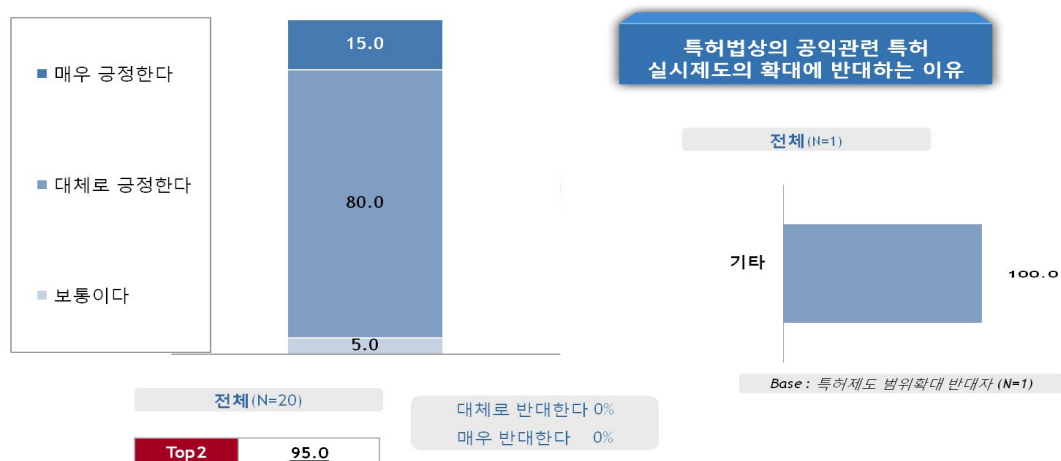
- ① 매우 긍정한다(☞문18로 이동)
- ② 대체로 긍정한다(☞문18로 이동)
- ③ 보통이다
- ④ 대체로 반대한다
- ⑤ 매우 반대한다

설문17. 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 범위 확대에 반대하는 이유는 무엇입니까?

- ① 이러한 제도의 남용이 우려되므로
- ② 독점 배타권이라는 특허제도의 형해화가 우려되므로
- ③ 국익의 입장에서 이러한 제도를 장려하는 것은 득보다 실이 많으므로
- ④ 기타()

기후변화 및 지구온난화 등의 환경문제와 공중위생 문제(의약품 등) 등의 공공분야에 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 범위를 확대하는 것에 대하여 대체로 긍정한다는 응답이 80%를 차지하였고, 매우 긍정한다는 응답이 15%, 보통이라는 응답이 5%로 나타났다. 따라서 인류의 삶과 직결된 환경문제와 공중위생 문제 등의 공공분야에 특허법상 공익관련 특허실시제도의 범위 확대에 있어서 모두 긍정적인 의견을 갖고 있는 것으로 파악되었다(그림 IV-11 참조).

<그림 IV-11> 공공분야의 특허법상 공익관련 특허실시제도의 범위 확대



4. 정책적 측면에서의 제도보완의 방향성 및 적절한 수단

설문18. 정책적 측면에서 특허제도의 보완의 방향성은 무엇이라고 생각하십니까?

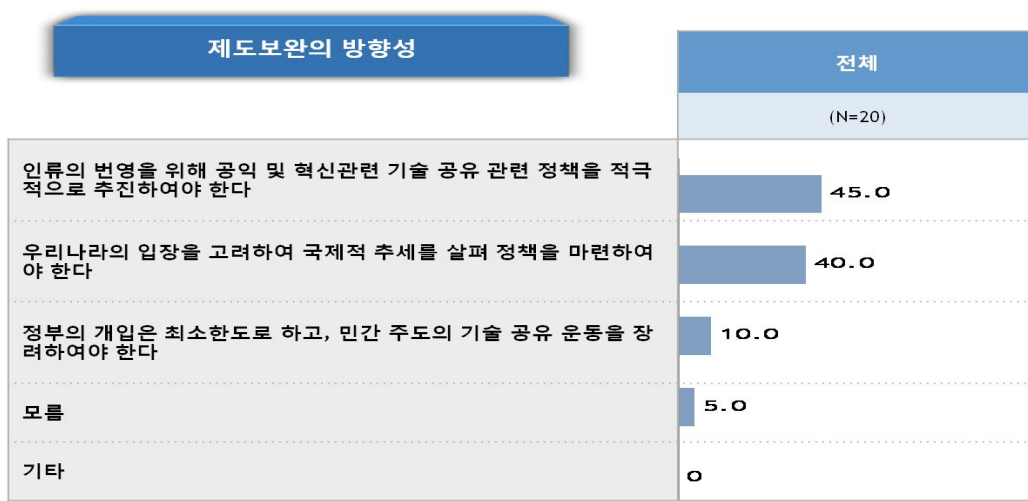
- ① 정부의 개입은 최소한도로 하고, 민간 주도의 기술 공유 운동을 장려하여야 한다
- ② 인류의 번영을 위해 공익 및 혁신관련 기술 공유 관련 정책을 적극적으로 추진하여야 한다
- ③ 우리나라의 입장을 고려하여 국제적 추세를 살펴 정책을 마련하여야 한다.
- ④ 기타()

설문19. 정책적 측면에서의 특허제도를 보완한다면, 다음 중 가장 적절한 수단은 무엇이라고 생각하십니까?(복수응답가능)

- ① 특허 기부제 활용을 활용하여 공익 및 혁신에 대한 기술 보급
- ② 민간 주도 기술 공유 운동(eco-patent commons, Science commons) 장려
- ③ 범국가적 차원에서 지구환경, 공중보건과 직결되는 특허의 공유화를 위한 기금조성
- ④ 공익 및 혁신과 관련된 기술의 특허풀 장려
- ⑤ 기타()

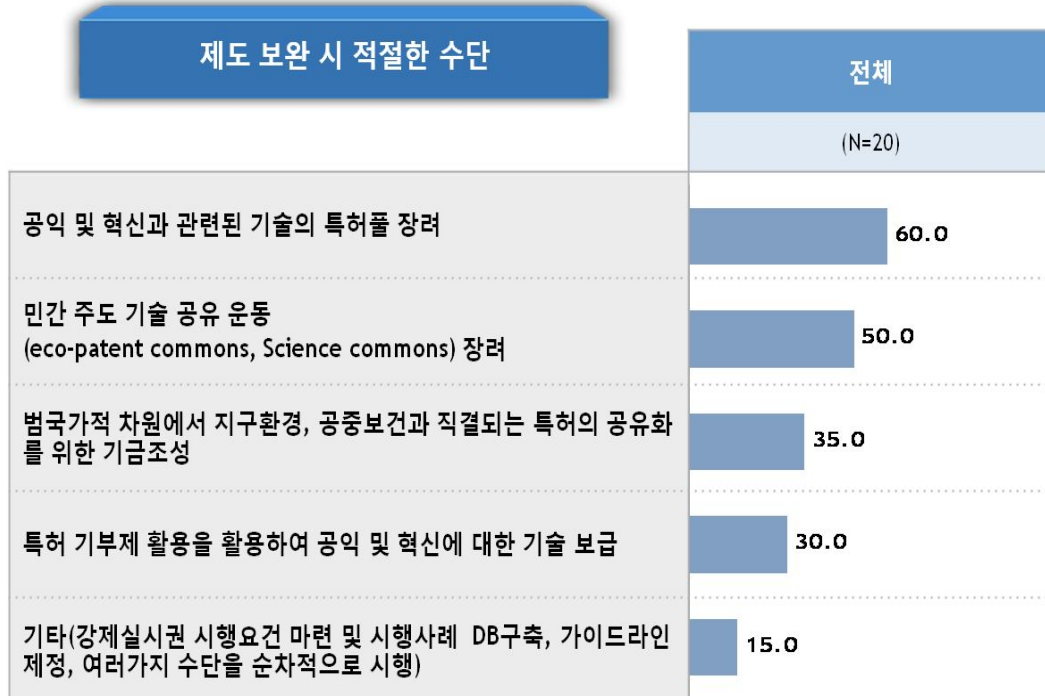
<아래 그림 IV-12>에서 보는 바와 같이, 정책적 측면에서 특허제도 보완의 방향성에 대한 설문 결과, 인류의 번영을 위해 공익 및 혁신관련 기술 공유 정책을 적극적으로 추진하여야 한다는 응답이 45%를 차지하였고, 우리나라의 입장을 고려함과 동시에 국제적 추세를 살펴 정책을 마련하여야 한다는 의견이 40%로 나타났다. 그 외에 정부의 개입은 최소한도로 하고, 민간 주도의 기술공유 운동을 장려해야 한다는 응답은 10%로 나타났다.

<그림 IV-12> 정책적 측면에서의 제도보완의 방향성



<그림 IV-13>은 정책적 측면에서 특허제도 보완 시의 적절한 수단에 대한 조사 결과이다. 공익 및 혁신 관련기술에 대해 공동의 이익을 목적으로 결성한 특허풀을 장려한다는 응답이 60%로 조사되었고, Eco-patent commons와 Science commons와 같은 민간 주도의 기술공유운동을 장려한다는 의견도 50%로 높게 나왔다. 이밖에 범국가적 차원에서 지구환경·공중보건과 직결되는 특허의 공유화를 위한 기금조성에 대한 의견은 35%, 기부기업과 수탁기관 모두에 이익을 주면서 동시에 휴면 특허권의 활용을 촉진할 수 있는 특허 기부제를 활용하여 공익 및 혁신에 대한 기술을 보급하자는 의견이 30%를 차지하였다. 기타 의견으로는 강제실시권 시행요건 마련 및 시행사례 DB구축과 가이드라인을 제정하자는 의견이 나왔으며, 특허제도 보완을 위해 제시된 여러 가지 수단을 순차적으로 시행하자는 의견도 있었다. 또한 WTO Trips 협정의 강제실시권 범위와 선진 외국사례나 그 범위 수준으로 보다 용이하게 강제실시될 수 있도록 특별법상 강제실시권 규정을 개설하고, 다른 부분들은 WTO의 제소 등 통상마찰의 우려가 있으므로 국제 무역규범 내지 지재권 보호수준으로 접근하는 것이 필요하다는 의견도 있었다.

<그림 IV-13> 제도보완 시 적절한 수단



Ⅲ. 기타 의견

설문20. 본 설문에서 논의된 것 외에 공익과 혁신의 관점에서 특허제도를 보완하기 위한 방안에 대해 자유롭게 기술해 주세요(서술형).

설문에서 논의된 것 외에 공익과 혁신의 측면에서 특허제도를 보완하기 위한 방안에 대한 설문 결과로는 다음과 같은 의견이 제시되었다. 이에 대해 간략히 요약해보면, 공익과 혁신 측면의 기술공유의 필요와 공익과 사익의 적절한 균형, 보상시스템의 개선 및 특허제도 보완 차원의 진정한 공익에 대한 공감대 형성이 필요하다고 하였다. 주요내용은 이하와 같다.

- ▶ 공공연구기관 보유의 특허권을 민간기업에 분양하여 공공연구기관 보유 특허권 활동의 촉진 필요(창업장려 및 신사업투자로 일자리 창출효과)
- ▶ 정부와 기업의 괴리점에 있어서 공익에 대한 정확한 명분이 확립되어야 하고, 특허제도 보완 차원의 진정한 공익에 대한 공감대 형성이 필요함
- ▶ 기술공유를 한 기업·개인에 대한 인증제도의 도입을 통해 사회적 기여에 대한 보상받을 수 있는 정책마련이 필요함
- ▶ 독점과 경쟁의 한계 설정이 보다 구체화되어야 하고, 국제적으로 공익·혁신 관점에서 국제적인 협조를 통한 특허제도 보완 방안의 모색
- ▶ 현실성을 고려한 보상시스템과 현금 및 명예와 같은 실질적 보상을 위한 모델이 마련되어야 하는 등의 보상시스템에 대한 인식 필요함
- ▶ 특허에 대한 엄격한 심시를 통해 특허권을 최소화하여 특허제도가 진정으로 혁신에 기여하고 있는지에 대한 포괄적인 검토가 필요함
- ▶ Patent troll과 같이 새로운 기술 연구 및 투자 없이 특허권을 매집하여 권리행사를 하는 자에 대한 강력한 제재 필요
- ▶ IT분야, 특히 소프트웨어 분야에서의 기술공유 혁신사례를 통해 우리 특허제도에 주는 함의에 대한 검토 필요
- ▶ 민간의 자유와 창의를 저해할 우려가 있는 정부의 개입은 신중히 하는 반면 기업에서의 기술혁신으로 이어진 특허공유에 대한 홍보는 지지
- ▶ 공익과 관련된 특허에 대해 보상해주면서 관련 분야 혁신을 유도하는 정책의 마련 필요
- ▶ 제약 산업분야에 있어서 공익과 기술공개에 따른 사익간의 적절한 균형 필요
- ▶ 대기업의 중소기업에 대한 기술공유 및 공여에 대한 정부의 세제지원 확대와 지원책 강화 필요

설문21. 특허제도의 목적에 비추어 볼 때, 공익과 혁신을 통한 산업발전을 위해 특허제도가 나아가야 할 방향은 무엇이라고 생각하십니까?

특허제도의 목적에 비추어 공익과 혁신을 통한 산업발전을 위해 특허제도가 나아가야 할 방향에 대한 설문결과로는 다음과 같은 의견이 제시되었다. 이를 요약해보면, 독점과 공유의 적절한 균형 및 Patent troll의 부작용에 대한 제도개선 등이 필요하다고 하였다. 주요 의견은 이하와 같다.

- ▶ 공익목적 및 창업촉진목적 특허보유정책의 확대 필요 및 일정기간이 지난 공공 부문보유 특허를 공개입찰 통해 민간 기업이 활용할 수 있는 정책 추진 필요
- ▶ 대기업의 과점 현상 등의 문제점에 대해서 공익·기술혁신 측면의 특허제도상의 중재 및 조정제도 보완
- ▶ 독점과 공유의 적절한 균형 필요 및 각 분야별 문제점에 대한 접근 방식 타당
- ▶ 유연성을 확보하여 과잉이 아닌 적정수준에서의 질적 개선을 위한 노력 필요
- ▶ 독점보다는 실시 및 활용에 초점을 둔 정책 필요
- ▶ 기술혁신을 장려하기 위한 인센티브(독점권 부여)는 유지하되, 공익을 위한 기술 공유(강제실시권)를 위한 보완적 세부 이행조치 마련 필요
- ▶ 특허제도에 대한 포괄적 검토를 통해 혁신에 기여하는 특허제도의 영역에 한정하여 특허권 부여
- ▶ 공익목적의 특허발명실시제도가 활성화되지 않는 분야 및 이유를 파악하여 공익 목적 및 효과가 큰 분야에 있어서 강제실시토록 하여 공익을 우선시함
- ▶ IT분야에서의 Patent troll 등 부작용을 최소화할 수 있는 제도개선이 필요하고, 아울러 에너지·환경 등 공익분야에서 특허제도가 긍정적 역할을 할 수 있도록 현 제도 보완
- ▶ 기술발전촉진의 특허제도의 본래적 취지를 전파하고 교육하는 동시에 이러한 취지가 정책 전반으로 확산될 수 있도록 하여야 함

제3절 소결

국내 산업계·연구계·학계 등의 기술공유화 전문가 집단을 대상으로 실시한 특허제도 보완을 위한 기술공유화에 대한 설문 결과를 종합하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

I. 현행 특허제도의 문제점과 기술공유에 대한 인식

최근에 Patent troll과 같은 특허권 비실시자의 특허제도 악용으로 인한 폐해가 증대하고 있으며 지나친 기술 독점으로 인해 기술 혁신에 지장을 초래하는 경우가 많은 것으로 나타났다. 또한 기후변화와 같은 지구환경과 의약품과 같은 국민보건 등에 관한 기술독점으로 공공의 이익을 저해하는 경우도 있어 ‘공유’가 아닌 ‘독점’으로 인해 문제점이 나타나며 이러한 문제점은 우리나라뿐만 아니라 미국, 유럽, 일본 등의 여러 나라에서도 나타나고 있다.

이러한 기존 특허제도의 문제들을 해결하는 방안으로서 특허제도 보완을 위해 기술공유의 필요성이 크게 느껴지며 기술혁신과 인간의 삶과 밀접과 분야의 공익, 기술개발에 따른 비용 절감 등이 기술공유가 도움이 되는 부문으로 판단되었다. 반면 권리자에게 부여되는 독점 배타권을 특허권 등의 지식재산권 본질이므로 권리자에게 공익추구를 강요하는 것 자체가 모순이라는 이유로 기술공유에 대해 부정적으로 인식하는 경우도 있었다. 따라서 기술공유를 통해 경제적·산업적 측면에서 큰 이점이 있다 할지라도 자유주의 경제체제 하에서의 소유권 원칙을 전제로 특허권이 가지는 본질을 훼손하지 않는 범위 내에서 기술공유를 도입하고 이와 관련된 정책을 마련해야 할 것으로 판단된다.

기술공유 사례에 대한 인지도는 60%로 나왔고 대체적으로 이에 대한 활용가치 또한 크다고 답변하였다. 기술공유 제도를 활용한 결과, 기술혁신이 활성화되고, 풍부한 연구자료 확보를 통한 후속연구를 활성화시키고, 기술개발에 드는 시간비용의 절감 등의 효과가 있었다고 조사되었다. 특히, 기술공유 도입의 장점 및 도입 후 얻을 수 있는 효과로 ‘기술공유화를 통한 기술혁신’을 기대하고 있으므로 다양한 산업 분야 중에서도 관련 산업 또는 경쟁 업체와의 기술 개방 및 공유를 통해 기술혁신을 통한 이익을 얻을 수 있는 분야에서 기술공유제도를 활용할 가능성이 클 것으로 판단된다.

특허제도 보완을 위한 기술공유에 대한 지지도는 높게 나타났으며 기술공유가 도움이 되는 분야로는 환경 및 보건이라는 응답이 많았다. 제조업, IT, 에너지 분야에 비하여 환경, 제약, 생명공학 분야에서 더 높은 비율의 응답이 나온 것으로 보아, 지구온난

화와 기후변화라는 전지구적 환경문제로 인식되어 꾸준히 활발한 논의가 되고 있는 환경 분야, HIV/AIDS, 결핵, 말라리아와 같은 전염병과 최근 들어 크게 문제가 되고 있는 신종인플루엔자 등 인간의 생명과 건강을 담보로 하고 있는 의약품과 같은 보건분야, 유전자 공학과 같은 생명공학 분야 등의 공익 부문에 대한 기술공유제도 도입의 기대가 큰 것으로 생각된다.

II. 기술공유 관련 법제도 및 정책수립 방향

기술공유 관련 정책에 관해서는 민간 차원의 노력뿐만 아니라 국제기구 및 정부차원에서 공공 분야의 지식재산 관련 정책의 일환으로 논의되는 경우도 있는데, 설문 결과를 보면 우리나라에서 보건·환경 등의 공공의 이익과 관련된 문제를 해결하기 위하여 정부 주도의 기술 공유정책을 추진함에 있어 대다수가 적극적으로 동참한다고 하였다. 그러나 동참을 주저하는 응답자들은 그 이유에 대해 정부 주도의 기술공유 정책보다는 민간 차원의 자발적인 기술공유 운동으로 충분하고, 현행 제도 보완만으로 충분하다는 의견과 정책으로 인한 기존 법체계 적용의 부작용을 우려한다는 의견이 있었다. 또한 기술공유에 대한 사회적 인식 확산 및 공감대 형성은 아직 미흡하다는 이유로 공익관련 정부주도의 기술공유정책의 동참을 주저한다고 답변하였다. 따라서 특허제도에 대한 보완책으로서 기술공유제도 도입이 우리나라 현행 법제도 및 산업 환경에 적합한지에 대한 충분한 검토를 거친 후에 관련 제도의 도입이 필요하다고 판단된다.

특허법상 공익관련 특허 실시제도의 인지도 조사 결과, 제도의 취지 및 목적은 알고 있으나, 실시현황 및 세부 내용에 대해서는 잘 모르겠다는 응답이 대다수를 차지하였다. 대체적으로 본 제도에 대한 취지 및 목적은 정확히 판단하고 있는 반면, 응답자 중 절반이 넘게 실시 현황에 대한 인식이 부족한 것으로 나타났다. 이번 설문조사가 선별된 전문가들을 대상으로 이루어진 점을 감안하면, 이에 대한 비전문가나 일반인들의 인지 정도는 더 낮을 것으로 예측된다.

또한 응답자 전체가 공익관련 특허실시제도가 효율적으로 시행되고 있지 않다고 하였고, 그 이유로 보상금이나 실시료의 산정방법의 부재 및 실시를 위한 요건과 절차가 까다롭다는 응답이 가장 많은 것으로 나타났다. 공익관련 특허 실시제도의 효율적인 시행을 위하여 보상금 또는 실시료 산정방법을 마련하도록 해야 할 것이며, 특허 실시에 관한 요건을 정비하고 절차적 용이성을 확보할 수 있는 개선방안이 마련되어야 한다고 판단된다.

특허법상의 공익관련 특허실시제도의 확대에 관한 설문결과, 대부분이 긍정적으로

인식하고 있었으며 정책적 측면에서의 특허제도 보완의 방향성에 대해 인류번영을 위해 공익 및 혁신의 기술 공유 관련 정책을 적극적으로 추진하여야 하며, 우리나라의 입장을 고려하는 동시에 국제적 추세를 살펴 정책을 마련하여야 한다고 응답하였다. 특허제도 보완 시 적절한 수단으로써 공익 및 혁신을 위하여 특허권을 장려하고 민간 주도의 기술공유 운동을 장려하여야 한다는 의견이 다수를 차지하였다. 이를 통하여 현행 특허권 활성화 방안을 모색하고, 특허권과 관련한 특허권 남용 문제를 방지하기 위한 대책 마련도 필요할 것으로 판단된다. 또한 Eco-Commons 운동, Green Xchange 운동, Science Commons 등과 같은 민간 차원의 기술공유 사례를 검토하여 우리나라에 사정에 반영할 수 있는 요소들이 무엇인지 연구할 필요가 있다. 또한 지구환경·공중 보건과 직결되는 특허의 공유화를 위한 기금을 조성하고, 특허기부제를 활용하여 공익 도모 및 기술 혁신을 꾀할 수 있는 기술을 보급하기 위한 노력도 또 다른 특허보완책이 될 수 있을 것으로 판단된다.

제5장 기술공유제도의 모델 분석 및 제도설계방향

제1절 서설

현재, 특허 인정 범위의 확대 및 특허권의 지나친 사유화로 인한 피해를 극복하기 위하여 국내·외에서 다양한 시도가 이루어지고 있다. 국제기구 및 정부 차원에서의 기술공유 운동도 진행되고 있다. 주로 기후변화협약, 탄소배출권 등과 관련된 환경 분야에서의 기술 공유 논의가 많으며, 신약개발 및 보급과 관련한 보건 분야에서의 기술공유 논의¹⁴¹⁾도 활발히 진행되고 있다.

대표적인 예로는 환경과 생태계를 직·간접으로 개선 또는 보호하는 특허를 공유하여 환경보전에 이바지 하고자하는 ‘EPC(Eco-Patent Commons)’, 환경을 보호하고 그린 경영을 실천하는데 도움을 줄 수 있는 특허를 서로 공유하고자 하는 ‘Green Xchange’, 소프트웨어에 대한 사용·복제·배포의 자유와 소스코드를 학습·수정·개선할 수 있는 자유를 부여하는 ‘Open Source S/W’, 열대 질병 치료를 위하여 신약 개발 시 연구 결과를 공개토록 하는 ‘Open Source Drug Discovery Project’ 등이 있다. 우리나라의 경우 주로 대기업 주도로 특허 협력 강화를 위한 특허 기술 공유가 개별 기업 차원에서 이루어지고 있는 것으로 보인다.¹⁴²⁾

이하에서는 이러한 특허제도 보완을 위한 종래 논의되는 기술공유관련제도와 최근

141) 세계무역기구의 ‘무역관련 지적재산권(TRIPs)협정’과 현행 우리나라 특허법에서는 국가비상사태나 긴급한 상황, 공공의 비영리적 목적을 위한 경우 등의 경우에 특허권자의 허락 없이 강제로 특허를 사용할 수 있는 강제실시권을 규정하고 있다. 그러나 이러한 규정에도 불구하고, 특허 독점으로 인해 백혈병 치료제 글리백(2001년), 조류독감 유행에서 타미플루(2005년), 에이즈치료제 푸제온(2008년)의 공급 부족 사태가 문제가 되었으며, 최근에는 신종플루 유행 등 국민의 건강과 생명이 위협을 당하는 많은 문제를 야기하면서 공익 목적을 위한 특허권 제한 및 강제실시권 제도 강화 논의가 대두되었다.

142) 하이닉스반도체는 반도체 장비,재료 관련 중소 협력사와의 특허 기술 공유 및 지원을 위해 ‘하이닉스 특허지원 프로그램’을 운영하고 있으며(연합뉴스, 2010.4.26.자 뉴스 참조), 삼성전자의 경우 불필요한 특허경쟁을 줄이고 비즈니스에 집중하기 위하여 쉐컴, 마이크로소프트(MS), 소니, 코닥 등과 특허기술 공유 계약을 체결한 바 있다(파이낸셜뉴스, 2010.1.20.자 뉴스 참조). 또한 국내 지문인식업체인 니트젠과 유니온은 상호 특허 공유를 통해 기술혁신 및 마케팅 협력을 시도한 바 있으며(etnews, 2008.9.18자 뉴스 참조), LG전자와 제너럴 일렉트릭(GE)은 생활가전 관련 특허공유 계약을 체결하여 전략적 협력 관계를 구축한 바 있다(NEWSPIM, 2008.2.27.자 뉴스 참조).

새롭게 민간분야에서 진행되고 있는 기술 공유모델을 비롯하여, 일본에서 제안되고 WIPO에서 대응하고 있는 기술 공유모델들을 검토함으로써, 특허제도를 보완하기 위한 기술 공유모델의 구축방안을 도출하고자 한다.

제2절 종래 기술 공유관련 제도적 모델

I. 특허기부(기술기부채납) 제도

1. 도입 배경

특허기부제도는 일반적으로 대학이나 국공립 연구기관 등에서 국가연구개발사업을 수행하여 확보한 기술을 중소기업에 무상으로 이전하는 기술무상양허제도¹⁴³⁾와는 다른 개념의 제도로서 기업이 자사가 보유한 일부 특허권을 대학 등 비영리기관에 기부하고 법인세법에 의거하여 일정금액의 세금을 감면받는 제도이다. 특허기부제도는 특허권 취득 후 활용되지 않고 있는 휴면특허의 활용을 활성화시키기 위한 방안의 하나로서 2001년부터 계속적으로 논의가 있어 오다가¹⁴⁴⁾ 2010년 4월에서야 ‘기술의 이전 사업화 촉진에 관한 법률’ 제21조의 2¹⁴⁵⁾에 관련 내용을 법문화함으로써 도입되었다.

143) 한국과학기술정책관리연구소, “중소기업에 대한 기술무상양허사업 성공사례”, STEPI 조사자료 96-20, 1996, 153-154면.

144) 이와 관련하여 국회 산업자원위원회는 2001년도 특허청에 대한 국정감사에서 휴면특허의 활성화 대책을 촉구한 바 있으며, 2002년 3월 국내 11개 기업이 ‘특허권 활용활성화를 위한 제도개선 건의’ 형식의 청원을 한 바 있다. 2003년에는 국회 산업자원위원회가 제239회 임시국회에서 특허기부제도 도입문제를 특허청장에게 질의한바 있으며 특허청장은 현행 법인세법상 특허권기부제도 도입에는 문제가 없으나 기부된 특허권에 대한 가치평가 등 실무적 문제가 있는 것으로 답변한 바 있다. 한편, 국내 대기업 중심의 민간경제단체인 전국경제인연합회(FKI)는 2004년 11월 24일에 “대기업 특허기부제도 도입”에 관한 대정부 정책건의를 하였으며,¹⁾ 2005년 5월 3일에는 중소기업협동조합중앙회와 대기업의 휴면특허 활용을 통한 중소기업 경쟁력 강화 방안을 논의하였다(김해도, “산학협력 촉진을 위한 특허기부제도 활성화 방안에 관한 연구”, 「지식재산21」(통권 제91호), 2005, 55-57면).

145) 제21조의2(기술 등의 기부채납)

① 다음 각 호에 해당하는 자는 기술 등을 국가에 기부채납(寄附採納)할 수 있다.

1. 공공연구기관

2. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단

3. 민간기업

② 지식경제부장관은 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 제1항에 따라 기부 채납된 기술

2. 특허기부제도의 개념

특허기부(Patent Donation)는 위에서 언급한 기부행위의 한 유형이라 할 수 있는데, 금전이 아닌 무체재산의 일종인 특허권을 기부하는 것으로 다소 생소한 개념일 수 있지만, 기부의 본질은 크게 다르지 않다고 할 수 있다. 다시 말해 특허기부제도는 기업이 자사의 일부 특허권을 대학 등 비영리기관에 기부하고 법인세법에 의거하여 일정금액의 세금을 감면받는 제도이며, 대학이나 국공립연구기관 등에서 국가연구개발사업을 수행하여 확보한 기술을 중소기업에 무상으로 이전하는 기술무상양허제도와는 다른 개념이라 할 수 있다.¹⁴⁶⁾

특허 기부는 산업계와 대학 간에 아무런 연고 없이 이루어질 수 있지만, 그렇다고 해서 기부로서 산학간의 관계가 끝나 버리는 것은 아니다. 대학이 기부를 통해서 지식재산권을 소유하게 되면, 이는 대학의 배타적 권리가 된다. 만약 대학이 결국 이러한 기부 특허를 판매하거나 로열티를 얻기로 결정하는 것은 대학이 원한다면 할 수 있는 것이다. 그리고 기업은 이러한 대학의 움직임에 동참할 수 있다. 대부분의 경우, 기부를 한 기업은 그러한 특허의 진행 상황을 주시하고 있다. 만약 대학이 기부 기업이 관심을 가질 만한 상태로 기술을 개발하게 되면, 기업은 대학에 판매 혹은 라이선싱을 제의할 수도 있다. 기업이 특허를 기부하는 것은 양질의 기술이 외부로 나가서 계속 개발되는 것을 보장하기 위함이지, 쓰레기 특허를 내다 버리는 것이 아닌 것이다. 대부분의 기업들이 이러한 기부 철학을 가지고 있기는 하지만, 모든 기업들이 이와 같이 선의의 철학으로 기부를 행하고 있는 것은 아니다. 따라서 대학은 가치가 없는 기술에 대한 기부를 거절하는 경우도 있다.¹⁴⁷⁾

특허기부제도는 그 취지를 잘 살리면 기부기업과 수탁기관 모두에 이익을 주면서 동시에 휴면 특허권의 활용을 촉진하는 효과를 거둘 수 있는 제도이다. 다만, 이 제도의

등을 관리·처분[현물출자(現物出資)는 제외한다]한다.

③ 제1항에 따라 기부채납된 기술 등의 이전 및 사업화로 기술료 등 수익이 발생하는 경우 기부채납을 한 자 또는 그 기술 등의 개발자에게 보상할 수 있다.

④ 제2항에 따른 기술 등의 관리·처분 등에 필요한 사항 및 제3항에 따른 보상의 기준·방법 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2010.4.12]

146) 전국경제인연합회는 특허기부제도의 개념을 ‘기업이 보유하고 있는 미활용 특허가 대학 등의 비영리기관에 기부될 때 기업은 기부된 특허의 화폐가치에 상응하는 일정금액의 세금을 감면받는 제도’로 정의하고 있다(전국경제인연합회의, “정책건의-대기업 특허기부제도 도입에 관한 의견”, 2004, 10면).

147) 임근영 외 3인, “특허권 기부제도 및 증권화 연구”, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2002, 7면.

성공적인 정착을 위해서는 특허권의 기부가액 산정방법, 수탁기관의 선정문제 등이 관건이라고 할 수 있다. 즉, 특허권의 기부금 가액을 산정함에 있어 특허권 획득에 드는 비용으로 할 것인지 아니면 미래의 가치를 반영한 평가액으로 할 것인지에 대한 결정이 있어야 할 것이다.¹⁴⁸⁾

3. 특허기부의 법적 성격¹⁴⁹⁾

일반적인 국어사전에서는 기부란 “자선사업이나 공공사업을 도울 목적으로 재물을 내어 놓는 행위”를 의미하는 것으로 기술되어 있으나, 법률적인 측면에서 기부란 “반대급부 없이 금전이나 물품을 제공하는 행위”라고 해석할 수 있다. 이처럼 기부란 반대급부를 바라지 않고 제공하는 자선행위이나 세계 각국은 자국의 기부문화 활성화를 위해 일정한 조건의 기부행위에 대해 세금감면 등 소정의 인센티브를 부여하고 있다.

우리나라의 경우도 공익적인 성격의 기부금에 대해서 법인의 경우에는 법인세법에 의거하여 손금¹⁵⁰⁾으로 인정하여 일정비율의 법인세를 감면¹⁵¹⁾해주고 있으며, 개인의 경우에는 소득세법을 통해 종합소득 계산 시 소득공제¹⁵²⁾를 해줌으로써 일정비율의 소득

148) 전기역, “특허의 기부제도와 증권화 방안에 관하여”, 「지식재산21」(통권 제79호), 2003, 59-60면.

149) 김해도, 앞의 논문, 58-59면.

150) 법인세법 제19조(손금의 범위)

- ① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것을 제외하고 당해 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비의 금액으로 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 손비는 이 법 및 다른 법률에 달리 정하고 있는 것을 제외하고는 그 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 용인되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다.
- ③ 「조세특례제한법」 제100조의18제1항에 따라 배분받은 결손금은 제1항의 손금으로 본다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 손비의 범위 및 구분 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

151) 법인세법 제14조(각 사업연도의 소득)

- ① 내국법인의 각 사업연도의 소득은 그 사업연도에 속하는 익금의 총액에서 그 사업연도에 속하는 손금의 총액을 공제한 금액으로 한다.
- ② 내국법인의 각 사업연도의 결손금은 그 사업연도에 속하는 손금의 총액이 그 사업연도에 속하는 익금의 총액을 초과하는 경우에 그 초과하는 금액으로 한다.

152) 소득세법 제52조(특별공제)

- ⑥ 거주자가 해당 과세기간에 지급한 기부금[제50조제1항 제2호 및 제3호 나목에 해당하는 사람(다른 거주자의 기본공제를 적용받은 사람은 제외한다)이 지급한 기부금을 포함한 다]으로서 다음 각 호의 기부금을 합한 금액에서 사업소득금액을 계산할 때 필요경비에

세를 감면해 주고 있다. 그리고 개인사업자의 경우도 소득세법에 따라 소득금액 계산 시 필요경비로 인정해주고 있다.

또한 우리나라의 법인세법시행령은 금전 이외에 자산도 기부로 인정하고 있으므로 특허권과 같은 지식재산권도 기부의 대상이 될 수도 있다. 이처럼 특허권 등과 같이 금전 이외에 자산을 기부한 경우에는 당해 자산의 가액은 이를 제공한 때의 시가로 하고 법인세법 24조 2항에 명기된 법정기부금은 장부가액으로 하고 있다.¹⁵³⁾

4. 특허기부제도를 통한 미활용 기술의 활용

1990년도 초에 접어들면서, 지식재산의 중요성이 크게 인식되면서 기업자산의 새로

산입한 기부금을 뺀 금액은 해당 과세기간에 합산하여 과세되는 종합소득금액(사업소득 금액을 계산할 때에 기부금을 필요경비에 산입한 경우에는 기부금을 필요경비에 산입한 후의 소득금액을 기준으로 하며, 제62조에 따라 원천징수세율을 적용받는 이자소득 및 배당소득은 제외한다)에서 공제한다. 이 경우 제1호의 기부금과 제2호의 기부금이 함께 있으면 제1호의 기부금을 먼저 공제한다.

1. 법정기부금

2. 지정기부금. 이 경우 지정기부금의 한도액은 다음 각 목의 구분에 따른다.

가. 종교단체에 기부한 금액이 있는 경우

한도액 = [종합소득금액(사업소득의 경우 기부금을 필요경비에 산입하기 전의 소득금액을 기준으로 하며, 제62조에 따른 원천징수세율을 적용받는 이자소득 및 배당소득은 제외한다)에서 제1호에 따른 기부금을 뺀 금액을 말하며, 이하 이 항에서 “소득금액”이라 한다] × 100분의 10 + [소득금액의 100분의 10과 종교단체 외에 지급한 금액 중 적은 금액]

나. 가목 외의 경우

한도액 = 소득금액의 100분의 20

- ⑧ 제1항부터 제7항까지의 규정에 따른 공제는 해당 거주자가 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청한 경우에 적용하며, 공제액이 그 거주자의 해당 과세기간의 합산과세되는 종합소득금액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다. 다만, 그 초과한 금액에 기부금이 포함된 경우에는 해당 기부금을 해당 과세기간의 다음 과세기간의 개시일부터 다음 각 호에 따른 기간 이내에 끝나는 각 과세기간에 이월하여 종합소득금액에서 공제하거나 제34조제3항에 따라 필요경비에 산입할 수 있다.

1. 법정기부금의 경우 : 1년

2. 지정기부금의 경우 : 5년

153) 제37조(기부금의 가액 등)

- ① 법인이 법 제24조의 규정에 의한 기부금을 금전외의 자산으로 제공한 경우 당해 자산의 가액은 이를 제공한 때의 시가(시가가 장부가액보다 낮은 경우에는 장부가액)에 의한다. 다만, 법 제24조제2항 각 호의 규정 및 「조세특례제한법」 제73조제1항 각 호의 규정에 따른 기부금에 대하여는 장부가액으로 한다.<개정 2006.2.9>

은 평가방법으로서 지식재산관리(IP Asset Management)가 태동되었다. 그 무렵 미국의 주요 회계 법인들은 고객기업들이 소유한 특허권 등 지식재산권의 관리에 관한 컨설팅을 시작하였다. 그 당시 기업들이 자사 보유 특허에 대한 재조사를 시작하게 된 동기는 막대한 특허유지비용을 절감해 보고자하는 것이었다. 실례로 IBM과 같이 수 만 건의 특허를 보유하고 있는 기업들은 매년 특허유지비만 수백만 달러를 투입하고 있었기 때문에 이에 대한 대책마련이 절실하게 되었다. 특허유지비는 특허권의 권리설정 이후에 특허권자가 부담하는 것으로서, 미국특허청에서 특허가 허여된 후 특허권을 유지되기 위해서는 먼저 특허등록료(Patent Enrollment Fees)를 납부하여 특허권을 등록한 후 특허보호기간의 경과에 따른 특허유지료 (Patent Maintenance Fees)를 납부해야 한다. 미국의 경우 특허유지료는 특허권 설정등록 후 4년차, 8년차, 12년차 이후의 특허권 유지를 위해 총 3회에 걸쳐 납부해야 하는데, 각 회차별 유지료는 1회차 900달러, 2회차 2,300달러, 3회차 3,800달러로 기간이 경과될수록 그 금액이 증가하고 있음을 알 수 있다. 즉, 특허권 유지기간이 길수록 그에 따른 비용이 급격히 증가하고 있음을 알 수 있다.

앞에서 언급한 바와 같이, 특허가 허여된 후 특허권이 유지되기 위해서는 특허유지료 등 제반 법률비용이 소요된다. 또, 일반적으로 특허권을 상업화시키는 방안을 찾게 되면 높은 거래비용과 자문료가 들어가게 되지만 성공할 가능성은 매우 낮다. 실제로 특허기술에 대한 판매는 비록 언론에서 많은 조명을 받고는 있으나 거래가 성사되기는 매우 어렵다. 따라서 특허권에 대한 판매가 특허권으로부터 이득을 얻는 방법으로서는 일반적으로 가장 비용이 많이 들고 어려운 방법인 것으로 간주되고 있기도 하다.

이에 반하여 특허기부는 특허가치 평가와 특허권 권리설정 이전 등에 소규모 비용이 투입되지만 몇 개월 이내에 소득세 감면이라는 실질적인 혜택을 가져다주게 된다. 이와 더불어, 특허기부 기업들은 기부를 통해 기업 이미지를 제고하게 되고 자사가 개발한 특허기술이 사장되지 않고 대학 등 수탁기관에서 후속 연구를 진행할 수 있게 함으로써 자사 연구원들에게 보이지 않는 자긍심을 심어주고 있다.¹⁵⁴⁾

II. 특허풀 제도

1. 축적형 기술에 대한 대응

특허 풀(Patent pool)이란 특허에 대한 공동의 이익(라이선싱)을 목적으로 결성한 단체

154) 김해도, 앞의 논문, 76-77면.

로 회사의 성격을 갖는다. 특히 표준화 대상 기술에 포함된 특허를 대상으로 관련 회사가 모여 풀을 만들고 풀에 포함된 회사는 권리를 상호 공유하지만 포함되지 않은 회사는 실시료(라이선싱 비용)를 지불하고 사용하여야 한다. 대표적인 특허 풀로 MPEG-LA가 있다.

대부분의 특허권에 관한 발명은 축적형의 기술에 관한 것이다. 전기, 기계, 사무기기, 자동차 분야 등에 속하는 기술로서 기본기술에 대한 주변기술로서 대량의 개량발명 특허가 존재한다. 어떤 분야의 중심기술에 속하는 기본발명의 특허권도 중요하지만, 그 주위에 존재하는 대량의 개량발명의 특허권도 무시할 수 없다. 기본발명에 관한 특허권을 갖는 자는 그 신기술 상품을 시장에 제공한 후에 타사가 개량발명 특허를 가지고 있는 것을 발견한 경우를 상정해 보자. 기본발명의 특허권자가 개량발명의 사용을 피할 수 없다면 발명의 중요성은 별론으로 하더라도, 그 배타적 권리로서의 특허권의 존재는 매우 크다.

결국 축적형 기술의 경우 각각의 기술 분야에 속한 기업은 보유한 특허권의 상호 사용을 허락하게 된다. 반대로 보유한 특허의 수와 가치에 차이가 있는 경우 그 차이만큼을 로열티로 지급하는 구조로 되어 있다. 보유한 특허권을 배타권으로서 이용한 경우 현실의 비즈니스는 정지될 우려가 크기 때문이다.

2. 크로스라이센스의 보급

축적형 기술 분야에서는 패키지형의 크로스라이센스(Cross-license) 계약이 보편화되어 있다. 일본의 조사에 따르면, 전기, 사무기기 등의 기술 분야의 라이선스 중 90% 이상이 크로스라이센스가 형성되어 있다고 한다. 게다가 이러한 축적형 기술·표준화 기술의 경우에는 특허풀(Patent pool)의 비즈니스모델이 이용된다. 휴대전화와 DVD 등의 기술표준을 검토해보면, 관련된 특허권을 전부 조사해서 그 표준을 사용한 경우에 필요로 하는 특허권을 사전에 분명히 해둔다. 아울러, 그러한 특허권을 갖는 특허권자에게는 그 특허권 실시허락의 내부허락을 받는다. 그러한 표준관련의 다수 특허권을 풀(pool)에다 놓고 특허권의 사용을 희망하는 자에게는 특허풀의 운영책임자를 통해서 그 실시허락을 받는다.

이러한 패키지형 크로스라이센스 혹은 표준기술에 있어서 특허풀은 특허권자 각각이 보유한 특허권에 대해서 배타적 권리를 주장하는 것이 아니고, 그 특허권의 사용에 따라 일정한 실시료의 지급만을 요구하고 있다. 보상청구형 권리로서의 활용 모델이 확장되고 있는 것을 보여준다고 생각할 수 있다.

3. 우리나라에서의 특허폴 동향

우리의 경우 미국과 같이 여러 종류의 특허폴이 형성되고 있지는 않다. 국내에서의 특허폴은 이론적인 논의에 비하여 매우 제한적이다. 반면, 실제에 있어 특허폴은 현실적으로 정부 주도로 이루어지고 있다. 특허청은 2005년 12월 14일 RFID 기술은 특허폴의 출현이 유력한 기술 분야라고 하면서, 대응이 필요하다고 하였으며, 특허청이 주도하여 DVD관련 특허 1500건을 분석하여 중소기업체의 특허관련대응책을 제공하기 위한 노력을 기울이고 있다. DMB 등의 분야에 대하여 특허폴을 고려하기 위한 방안들에 대한 강구가 지속적으로 이루어지고 있다. 하지만 특허폴은 국내에서는 활성화되고 있지 않다.

그 이유로는 우선 국제 특허폴과 같이 특허폴이 형성될 경우 국내 및 해외 시장에서의 기술표준을 확립하거나, 산업의 구도를 재편할 수 있는 기술 분야가 드물다는 점들을 들 수 있다. 지상파 DMB의 경우 특허폴을 결성하는 경우 우리나라의 상용화 사례와 이를 위한 특허폴의 형성이 분명 긍정적인 면에서의 특허폴 결성 유인이 될 수 있지만 원천특허가 존재하지 않는 경우에는 특허폴의 결성에도 불구하고 여전히 개별적인 협상의 여지가 남게 되므로 개별 특허권자가 유인을 가지기 어려울 수 있다. 하지만 개별적인 기술분야에 따라 상황이 다르므로 일률적으로 설명할 수는 없다. 그러나 개량 특허 위주로 우리나라의 특허가 구성되어 있는 기술분야의 경우에는 특허폴을 통하여 원천특허 보유자와의 협상에서 유리한 지위에 있을 수 있으므로 방어적인 목적으로 특허폴을 형성하는 것이 필요할 수 있으므로 이러한 점을 감안하면 반드시 특허폴 구성의 필요성이 없다고 할 없다.¹⁵⁵⁾

두 번째로 특허권을 특허폴 회사에 양도한 후 그 양도이후의 수익을 배분하기 위해서는 특허권의 가치평가가 제대로 이루어질 수 있어야 하는데 이러한 가치평가기준을 제대로 하기 위한 기법이 우리나라의 경우 제대로 이루어지지 않아서 일 수 있다. 그러나 미국의 MPEG 특허폴의 경우나 VISX/Summit 특허폴의 경우에서 보는 것과 같이 결국 전체적으로 특허폴 결성의 필요성이 분명하게 인정된다면 특허평가는 하나의 점으로 정확한 가치평가가 이루어질 수 없는 분야이므로 협상력에 의하여 결정된다. 그러므로 특허가치평가방법의 부족만이 특허폴이 구성되지 않는 유일한 이유라고 할 수 없다.

세 번째는 위의 각 요인이 어느 정도 영향을 주는 것이라고 하더라도 규범적인 면에서 특허폴은 항상 독점금지법 위반의 소지를 안고 있다. 결국 특허폴의 문제는 사전적으로 경쟁제한성에 대한 정리(clearance)를 하여 주지 않으면 기업들의 경우에는 많은

155) 최승재, 앞의 논문, 24면.

비용을 부담하여 특허권을 형성하고는 오히려 특허권의 경쟁제한성이 인정되어 공정거래위원회와 같은 경쟁당국에 의하여 위법한 특허권으로 과징금의 부과, 손해배상, 형사처벌 가능성 등의 위험을 감수할 것을 요구하는 것은 특허권의 형성에 중대한 장애가 될 수 있다. 우리나라의 경우에도 미국 법무부의 비즈니스 리뷰 레터나 미국 연방거래위원회의 권고적 의견 제도와 같이 공정거래위원회에 대한 사전심사청구제도가 있지만 10여건 정도만 활용이 되고 있어 특허권의 형성에 장애가 될 수 있다고 생각된다.¹⁵⁶⁾

4. 특허권의 전망

우리나라의 기업들의 경우, 국제 특허권의 결성에는 이미 기업들의 표준선점의 목적과 로열티 수입의 증대, 기술경쟁에서의 특허침해소송 등 공격에 대한 방어목적 등 여러 가지 이유로 하여 특허권의 구성원이 되고 있다. 그리고 이러한 국제 특허권에서 주도적인 역할을 하기 위한 노력을 가속화할 것으로 예상된다. 다만, 1990년대 말에서 2000년 이후 지속적으로 특허분쟁을 야기하고 있는 퀄컴의 경우와 같이, 굳이 특허권의 일원이 되지 않아도 충분한 수익을 발생시킬 수 있는 회사들을 특허권의 구성원으로 포함시킬 수 있는 인센티브에 대하여는 특허권의 활성화와 부작용을 줄이기 위해서 학문적으로 또 실무적으로 고민할 사항이다.

생명공학분야의 경우에는 IT 분야보다 특허권의 결성이 더욱더 필요한 분야이다. 생명공학특허의 상업화의 성공 가능성이 미미하고, 많은 연구개발비용이 소모되고 있고, 대부분의 AIDS나 암치료제들이 자본력이 있는 제약회사들에 의해서만 가능한데, 이러한 다국적 제약회사들에 의하여 수혜를 받는 사람들은 반드시 선진국 국민에만 그치는 것이 아니므로 특허권이 이러한 다국적 제약회사들에 대한 강제실시가 가지는 연구개발 인센티브의 저하를 갈음하는 유용한 수단으로 기능할 수 있다고 본다. 향후 이러한 점에 대한 생명공학산업의 특성을 고려한 연구가 추가적으로 이루어져야 한다.¹⁵⁷⁾

IV. 정리

특허 기부는 아직 정착된 제도가 아니며, 비즈니스 측면에서 살펴보면, 현실적으로 필요한 특허나 기술이 기부되기보다 사회적으로 효용가치가 없는 특허(기술)들이 기부될 가능성이 높다. 또한 이 제도는 미활용 특허를 활용하자는 측면에서 도입된 제도

156) 최승재, 앞의 논문, 23-24면.

157) 최승재, 위의 논문, 27-28면.

이므로 공중보건, 기후변화 등 사회적·국가적으로 필요한 특허가 기부되기란 사실상 곤란하다. 이러한 측면에서 살펴보면, 현재 당면하고 있는 특허제도의 문제점을 극복하는 데 적합한 모델이라고는 할 수 없다.

한편, 특허풀은 기업이 전략적 차원에서 특허를 활용할 목적으로 결성되는 것이 많고, 순수한 공익적 측면에서 이루어지는 것이라는 볼 수 없다. 기업은 이윤을 추구가 최종 목표이며, 특허풀은 이를 위한 하나의 수단에 지나지 않는다. 다만, 국가적 차원에서의 특허풀을 형성시켜 현행 특허제도를 보완하는 형태로 특허풀을 활용할 가치는 있다고 생각된다. 그러나 현실적으로 국제적합의가 이루어지기는 쉽지 않을 것이다.

따라서 특허기부(기술채납제도)나 특허풀 제도가 기술공유모델로서 활용될 여지가 있는가, 현실적으로 큰 메리트가 있다고는 볼 수 없다.

제3절 최근 민간 주도의 기술공유 모델

I. 특허 공용제(Patent Commons)

1. Eco-Patent Commons¹⁵⁸⁾

가. 성립배경 및 이유

환경을 보호하는 지식과 기술의 공유는 지구의 광범위한 도전과제와 위협을 다루기 위한 한 가지 방법이 된다. 또한 특허 받은 기술을 여러 사람들이 이용할 수 있도록 하는 것은 그러한 지식과 기술을 공유하는 하나의 방법이다. 그러나 현재까지 폐기물이나 오염물, 지구온난화 및 에너지수요를 감소시키기 위해서 로열티를 지불하지 않고 특허를 이용할 수 있도록 하는 국제사회 차원에서의 조직적인 노력이 이뤄지지 않은 실정이었다.

이러한 가운데 세계경제인회의(World Business Council for Sustainable Development : 이하 'WBSCD')와 IBM, Nokia, Pitney Bowes 및 Sony 등이 주도하여 2008. 1월에 설립한 Eco-Patent Commons는 시장에 환경적 편익을 가져오는 것을 원하는 누구라도 환경을 보호하기 위하여 이러한 특허를 사용할 수 있고 새로운 혁신을 촉진하는 기업간 협력을 가능하게 하는 약속에 기초하여 설립되었다.

Eco-Patent Commons는 환경적 편익을 제공하는 일부 특허가 기업의 핵심자산 (the

158) <http://www.wbcsd.org/web/epc> 참조.

jewel in the crown)일 수 있음을 인정한다. 따라서 기업이나 대학에게 그러한 핵심자산을 포기하도록 요청하는 것은 Eco-Commons의 목표가 아님을 명시하고 있다. 그러나 선도적인 기업과 대학들은 환경적 편익을 제공하지만 기업수익의 핵심자원이 아닌 일부 특허를 소유할 수도 있다. 이러한 특허는 기업들에게 명목적 라이선스나 배타성을 제공할 수 있으나, 공공의 영역에 들어왔을 때 더 큰 가치를 제공해 줄 수 있다.

오픈소스 소프트웨어에서 입증된 바와 같이, 지식의 무료공유는 새로운 협력과 혁신을 위한 비옥한 토양을 제공할 수 있다. 환경특허(environmental patents)의 공유를 통해 기업들은 좀 더 환경 효율적이고 지속가능한 방식으로 운영할 수 있을 것이고, 기술혁신이 사회혁신에 부응하는 것이 가능할 것이다.

그래서 Eco-Patent Commons는 세계적 기업에게 지속가능한 발전을 하도록 지원하고 혁신을 공유함으로써 다른 기업과의 차이를 만들 수 있는 유일한 리더십의 기회를 제공하는 것을 목표로 삼고 있다.

나. 운영방침

Eco-Patent Commons는 환경보호를 위한 이행을 가속화하고 촉진하기 위한 혁신과 해결책이 쉽게 공유될 수 있는 수단을 제공하고, 추가적인 공동혁신 및 환경에 도움이 되는 솔루션의 발전과 개발을 촉진하기 위해 특허를 제공한 기업과 이를 이용할 가능성이 있는 사용자간 협력과 협동을 촉진하고 장려하는 것을 목표로 하고 있다.

Eco-Patent Commons는 전세계 다양한 산업 부문, 대학, 연구센터 등에 개방되어 있고, Eco-Patent Commons의 회원사가 된 기업들이 제공한 특허를 보유하고 있다. 이 특허는 WBCSD에서 운영하는 웹사이트에 공개되며, Eco-Patent Commons를 통해서 모든 사람들이 환경을 보호하기 위해 특허를 자유롭게 사용할 수 있다. 다만, 이것은 방어적 종료조건(defensive termination)을 전제로 한다.

<표 V-1> Eco-Patent Commons의 운영방침에 대한 내용

제공될 수 있는 특허	- 제공 가능한 특허의 제한은 없으나, 다만 특허는 반드시 “환경적 편익”을 제공하는, 혁신을 위한 특허이어야 함 - 이 “환경적 편익”은 지하수 수질개선을 가속화하기 위한 기술처럼 특허의 직접적인 목적이거나, 폐기물 생산이나 에너지 소비의 감소를 가져오는 제조 또는 사업 공정과 같이 간접적인 목적도 가능 - Eco-Patent Commons에 참여하기 위하여 기업들은 그 수에 관계없이 특허를 제공할 수 있으나, 적어도 하나의 특허는 제공하여야함 - 하나의 특허만을 소유하고 있거나 적은 수의 특허를 소유하는 기업들의 참여 및 이러한 세계적인 이니셔티브를 지지하는 것도 환영
--------------------	--

환경적 혜택의 예	- 에너지 보존 또는 효율성, 오염방지(자원사용감소, 쓰레기감소), 환경 친화적인 재료나 물질의 사용, 재료 감소, 재활용성 증가
웹기반의 자원	- Eco-Patent Commons를 지원하는 주된 메커니즘은 WBCSD가 운영하는 www.wbcd.org/web/epc. 웹사이트임(Commons에 대한 정보를 제공함과 동시에 특허 제공과 활용을 촉진) - 웹사이트에서는 Eco-Patent에 대한 기본적인 정보, 회원, 조직구조 및 권리부여를 개설했던 법적 “프레임워크(framework)에 관한 정보, Commons의 회원인 기업 또는 기타 특허권자들의 목록, 회원이 특허를 제공하는 것을 허용하는 양식 및 그 특허에 관한 유용한 정보, Commons의 특허목록을 통해 특허를 찾는 방법, Commons의 특정 특허에 빠르게 접근하는 검색 기능, 관련된 언론기사 목록, 특허를 제공하고 Commons에 가입하는 방법에 관한 정보 (회원의 권리와 의무, 제공된 다른 특허에 대해 특허를 주장하지 않을 것을 포함), 문의사항과 도움을 요청하기 위한 연락처 정보 등을 제공
회원 기업들 또는 특허를 양도한 그 밖의 특허권자들을 위한 혜택	- Eco-Patent Commons는 지속가능한 발전의 가속화에 기여하는 기업들을 세계적으로 인정해 줌 - 기업이 그들의 혁신을 공유할 수 있는 효율적인 경로이다. 추가적인 혁신을 위한 기폭제를 제공하며 기업간 협력을 위한 새로운 기회를 촉진함 - 산업계와 기업들에게 특허를 제공한 기업이나 특허권자의 기술과 미래의 비전을 소개하는 데 도움을 줌 - 방어적 종료조건 (defensive termination)에 대하여, Commons에 특허를 제공한 자는 Commons 내에서의 권리를 잃지 않고 Commons의 영역 밖의 특허에 대해 다른 특허제공자에게 특허 주장이 가능
특허 이용자와 지구를 위한 혜택	- Eco-Patent Commons는 다른 사람들이 환경적 측면을 개선하기 위해 수단으로 사용될 수 있는 특허에 대한 자유로운 접근제공 - 그러한 정보가 쉽게 접근가능한 곳에서 이용이 가능

다. 참여기업

2008.1월 창립된 이후, 세계적으로 다양한 산업계를 대표하는 11개 기업에 의해 100개 이상의 환경 친화적 특허가 제공되어 오고 있다. 11개의 기업에는 Bosch, Dow, Dupont, Fuji-Xerox, IBM, Paitney Bowes, Ricoh, Sony, Taisei와 Xerox 등이 있다.

라. 운영실적

2009. 3. 23. 오피스 솔루션에 있어서 글로벌 리더인 Ricoh사와 선도적인 건설기업인

Taisei사가 Eco-Patent Commons에 가입하였다. Ricoh사와 Taisei사가 제공한 환경친화적 특허는 Ricoh사가 제공한 탈착식 카트리지의 재활용에 중점을 두어 개발한 기술과 Taisei사가 제공한 수질개선을 위해 개발한 건축기술이다. Eco-Patent Commons의 신규회원들이 제공한 특허 외에도, 이 이니셔티브에 가입하고 지난 가을 네 개의 특허를 제공한 Dupont사는 환경을 보전하기 위하여 오존과과를 줄일 수 있는 냉매물질에 대한 일곱 개의 특허를 더 제공하였다.

2009. 10. 2. Dow 화학회사와 Fuji-Xerox사, Xerox Corporation과 FUJIFILM Holdings Corporation의 합작회사가 Eco-Commons에 가입하였다. 새롭게 제공된 특허는 공정과정에서 에너지와 재료 소비를 감축시킴으로써 올레핀의 더 효율적인 생산을 가능하게 하기 위해 개발된 기술이다 (Dow사 제공). 올레핀은 포장, 전자제품, 접착제 및 내구성 상품에 사용되는 기본적인 건축용 자재이다. 이 특허는 올레핀 생산을 더 효율적이게 하는 현재의 기술에 대해 여러 가지 장점을 제공한다.

Fuji Xerox사는 그들이 개발한 폐수처리방법에 관한 특허를 제공하였다. Fuji Xerox사가 공개한 친환경 특허는 공장에서 배출된 폐수의 효율적인 처리에 관한 것으로, 폐수 속의 계면활성제 성분을 효과적으로 분리하는 기술과 폐수 처리시 필요한 응집제와 발생하는 진흙의 양을 줄여주는 환경 친화적 기술이다.

Xerox사는 2008년에 Eco-Patent Commons 회원이 되었고 그 당시에 토양 및 수질에서 발생하는 독성물질을 제거하기 위해 걸리는 시간을 단축시키는 공정에 적용되는 11개의 특허를 제공하였다. Xerox사는 2009년에 추가적으로 자기냉동 (magnetic refrigeration)이 환경을 덜 오염시키는 것을 가능하게 하는 기술에 적용되는 특허를 제공하였다. 2010. 7. 1. HP사가 Eco-Patent Commons에 가입하고 특허를 제공하였다.

2. Science Commons¹⁵⁹⁾

가. 성립배경 및 이유

Science Commons는 과학적 성과의 제고를 위해서 예술 및 문화 분야에서의 크리에이티브 커먼즈 라이선스의 성공이 과학 분야에서도 가능하도록 만드는 개방과 공유를 위한 목적으로 2005년에 개시되었다.

Science Commons는 크리에이티브 커먼즈에 의해 또는 크리에이티브 커먼즈를 통해 운영되는 네 개의 준자율적(semi-autonomous) 프로그램 중 하나이다. MIT 컴퓨터과학

159) <http://sciencecommons.org/projects/greenxchange> 참조.

과 교수인 Hal Abeson, 지식재산전문가인 James Boyle, Michael Carroll, Lawrence Lessig 교수, 변호사이자 다큐멘터리 영화제작자인 Eric Saltzman을 포함하여 크리에이티브 커먼즈 위원회 회원들에 의해 감독되고, 생물정보학 기업가이자 메타 데이터 전문가인 John Wilbanks는 크리에이티브 커먼즈 과학부 부사장으로써 사이언스 커먼즈의 프로젝트를 지시한다. 2002년 노벨상 수상자인 Sir John Sulston, 저명한 유전체학 및 생물정보학 과학자인 Michael Eisen, 저명한 경제학자인 Paul David, 저명한 특허법 및 생물공학자인 Arti Rai를 포함하여 과학자문위원회의 지도를 받아 작업한다. 마지막으로 1958년 노벨상 수상자인 Joshua Lederberg는 2006년부터 2008년 초까지 자문 위원회에서 활동하였다.

Science Commons는 연구주기-지속적인 생산과 과학적 방법의 중심에 있는 지식의 재사용-를 가속화하기 위해 세 가지 연결된 이니셔티브를 갖고 있다. 또한 디자인에 의해서 과학적 발견을 더 쉽게 하기 위한 새로운 협력적 인프라의 구성요소를 형성하고 있으며, 빠르고 효율적으로 웹에서 과학연구가 가능하게 하기 위한 전략과 수단을 고안하고 있다.

연간 예산은 약 75만 달러로 민간재단, 기업 및 계약을 포함하여 여러 가지 다양한 곳으로부터 운영지원을 받는다. 현재 자금제공자는 Ewing Marion Kauffman Foundation, the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the Omidyar Network and the HighQ Foundation이다. Science Commons는 크리에이티브 커먼즈에게 매 분기마다 운영지원비로 약 4만 달러를 지불하고 있다.

나. 운영방침

연구자와 기관들이 그들의 연구결과와 데이터를 개방하고 확인하는 것을 돕기 위한 정책과 수단을 개발한다. 전세계적인 과학 공동체를 가능하게 하기 위하여 '오픈 데이터' 프로토콜을 공개함으로써 서로 다른 법제도 하에서 생산된 데이터를 공유하고 사용하도록 한다. 또한 표준화된 계약을 통해 연구자들이 쉽게 연구 내용을 공유하고, 검증할 수 있도록 협조한다. 나아가 공통의 정보를 확인하고 통합함으로써 연구자들이 서로 다른 원천으로부터 데이터를 발견, 분석, 사용하도록 한다.

다. 참여기업

Addgene, BioMedCentral, CAMBIA, Hindawi, iBridge, MIT Open Courseware(OCW), Public Library of Science, PLoS ONE, Rice Connexions이 참여하고 있다.

라. 운영실적

Science Commons는 연구에 대한 법적, 기술적 장벽을 제거하기 위해 여러 분야에서 광범위하게 작업하고 있다.

<표 V-3> Science Commons의 주요 활동

- ▶ Scholars Copyright Program : 합법적 재사용을 위해 연구결과 및 데이터의 공개와 확인
- ▶ Biological Materials Transfer Project : 연구를 검증하고 확대하기 위해 물리적 물질의 이전 촉진¹⁶⁰⁾
- ▶ Neurocommons : 자유로운 접근허가를 위해 서로 다른 원천으로부터의 연구결과, 데이터, 자료 및 서비스의 통합/연결
- ▶ HealthCommons : 자유로운 접근허가를 위해 서로 다른 원천으로부터의 연구결과, 데이터, 자료 및 서비스의 통합/연결
- ▶ Patent Licenses : 특허와 노하우의 라이선싱

II. 특허협력제(Green Xchange)

1. 성립배경 및 이유

2010.1.27일 전 세계 10여 개 기업과 업계협회는 웹기반의 지식재산거래소인 그린익스체인지(GreenXchange: GX)를 출범한다고 발표했다. GX는 기업들이 지속 가능한 신사업 모델과 혁신을 지원하는 지식재산을 공유하고 상호 협력을 도모하는 공간이다.

GreenXchange를 창설해야겠다는 생각은 지식재산의 공유와 개방을 촉진하는 업무를 하고 있는 Creative Commons의 과학부 부사장인 John Wilbanks와 그 동료인 Joi Ito가 나이키의 지속가능한 사업 부장인 Kelly Lauber과 함께 지속가능성 관련 특허를 공유하고자 하는 나이키의 바람에 대해 대화를 나누던 때로 거슬러 올라간다. Wilbanks는 특허거래가 비영리로 운영되거나 기업이 운영하기보다는 웹기반의 공유사이트로 운영되어야 한다고 생각하였다.

160) 이를 통해서 Science Commons는 DNA, 세포주, 모델 동물, 항체, 플라스미드와 같이 물리적 생물학적 물질의 복사비용을 줄이기 위한 표준, 모듈 계약을 개발하고 보급하고 있다.

2009년에 그들의 비전이 펼쳐나가자, MEC(현재까지 유일한 캐나다 기업)를 포함하여 8개의 기업이 공동창립파트너로서 서명하였다. GreenXchange는 40만 달러 이상의 초기 투입 자본과 60만 달러 이상의 현물서비스를 가지고 있다. 파트너인 Salesforce.com사가 온라인 거래를 구축하였고, 소프트웨어 개발업체인 nGenera사는 특허권자와 특허를 찾고자 하는 사람들이 기밀 라이선스에 대한 세부사항을 논의할 수 있는 온라인 “공간”을 제공했다. GreenXchange는 직원이 없으나 창립파트너의 직원들은 회원협정의 일환으로써 이메일을 통해 대부분의 업무를 수행하면서 목적을 달성하는 데 헌신하고 있다.

GreenXchange의 창립파트너인 MEC사의 CEO인 David Labistour는 노력의 중복과 자원소비의 비효율성으로 인해 지속가능한 기술과 관행이 어려움을 겪고 있다고 지적하였다. GreenXchange는 특허를 많이 공개함으로써 기업들이 지속가능하게 사용할 수 있지만 현재는 잠재성만 있는 기술을 용도에 맞게 수정하도록 도움으로써 혁신을 자극하고자 한다. 기업들은 또한 협력연구에 더 쉽게 투자한다.

GreenXchange는 특허권자와 특허를 찾는 사람들이 자유롭게 이용할 수 있는 여러 가지 법적 틀을 가지고 있다. 여기에는 연구자들이 특허침해 면제를 허용하는 non-assertion-for-research licence, 특허권자들이 소득제한을 부과하는 것을 허용하는 model-patent licence와 field-of-use 제한이 있다. 예를 들면, Nike는 환경친화적고무제조법에 대한 사용분야를 제한하여 이것이 MEC의 자전거 타이어 내부에 있는 튜브에서 사용될 수 있으나 경쟁하는 신발제조업체에서는 사용될 수 없다. 또는 특허권자들이 자신의 지식재산이 지속가능한 에너지 분야에서 자유롭게 사용되도록 허용할 수 있다.

GreenXchange에는 약450개의 특허가 있고, GreenXchange는 현재 10개의 회원사를 2010년에는 20개로 확대하고자 하는 목표를 가지고 있다. Labistour에게 있어, 거래는 MEC 상표를 부착한 상품의 생태발자국을 줄이고 지속가능성 부문에서 리더십을 제공하기 위한 수단이다. 그는 향후에 MEC의 제품이 GreenXchange에 근거한 녹색특허를 사용할 수 있다고 한다. “이것이 화학물 공급자, 섬유 제조업자 등 원자재를 가지고 우리 상표를 부착한 제품을 만드는 사람들에게 의해 사용될 수 있기를 바란다.”고 말했다.

Wikinomics의 저자이자 GreenXchange 파트너인 nGenera의 회장인 Don Tapscott은 “더 효과적인 혁신, 경쟁 및 참여를 위해 기업들이 지식재산에 대해 달리 생각할 필요가 있다는 것이 비즈니스 마인드이다. 지식재산을 공유하는 것은 사회주의나 급진적인 환경보호운동가, 자선가의 입장이 아니다. 지식재산공유는 경쟁에서 살아남고 혁신을 자극하여 더 성공적인 기업과 고객을 위한 더 나은 가치를 구축하는 일이다”라고 말한다.

2. 참여기업

베스트바이, 크리에이티브커먼스, IDEO, 마운틴 이큅먼트 코업, 나이키, 엔제네라, 아웃도어업계연합, 세일스포스닷컴, 투디그리즈, 야후

III. 기타 모델(Open Source 운동)

1. 오픈소스 SW의 발생 배경 및 의의

가. 오픈소스 SW의 발생 배경

1950년대부터 1970년대까지의 컴퓨터 사용자들은 대부분의 소프트웨어를 서로 공유하여 자유롭게 이용할 수 있었고, 하드웨어 제조사들은 하드웨어를 편리하게 사용할 수 있게 하는 소프트웨어들이 제작되는 것을 기꺼워했다. 1970년대와 1980년대 초반부터 소프트웨어는 단지 하드웨어의 부속물이 아닌 그 자체의 가치 및 중요성이 부각되었고, 이전과 달리 사용자들이 소프트웨어를 연구하거나 수정하지 못하도록 바이너리 형태로만 배포하는 등의 기술적 방법을 사용하기 시작하였다. 소프트웨어의 독점배타권이 부각되고, 소프트웨어 산업이 복제권을 법적으로 적용하기 시작함에 따라, 이러한 소프트웨어 산업의 변화에 저항하여 1984년 리처드 스톨만은 GNU 프로젝트를 시작하게 되었다. 1984년에는 GNU 운영 체제의 개발이 시작되었으며, 자유 소프트웨어 재단(FSF)은 1985년 10월에 설립되었다. 그는 카피레프트를 주창하며 자유 소프트웨어의 정의를 모두가 자유롭게 사용할 수 있도록 디자인된 소프트웨어로 소개하였다. 1991년에는 핀란드에서 리누스 토발즈가 리눅스를 발표하였고 이것이 GNU 프로젝트에 통합되면서, 자유 소프트웨어 커뮤니티는 활성화되기 시작했다.

나. 오픈소스 SW와 GPL의 의미

오픈소스 소프트웨어(Open Source Software)는 리처드 스톨만과 FSF(Free Software Foundation)에 의해 만들어진 개념으로서, 소프트웨어의 이용자에게 해당 소프트웨어를 실행, 복제, 배포할 수 있는 자유, 그리고 원본코드¹⁶¹⁾에 대한 접근을 통해서 이를 학습, 수정,

161) 컴퓨터 프로그램의 원본코드는 컴퓨터 프로그램을 생성하기 위해 사람이 작성한 설계도로, 보통은 소스코드라고 불린다. 소스코드는 COBOL이나 FORTRAN 등의 고급언어로 쓰여지고, 이것은 다시 컴파일러(Compiler)라고 부르는 일종의 번역기를 거쳐 0과 1의 나열에 의한 오브젝트코드화 되어 사람이 아닌 컴퓨터가 읽고 이해할 수 있도록 변환된다. 이러한 과정

개선시킬 수 있는 자유를 부여하는 소프트웨어이다. 그리고 이와 같은 내용의 자유를 실질적으로 보장하기 위해 리처드 스톨만은 자신의 소프트웨어에 대한 저작권을 확보한 뒤, 이러한 권리를 전제로 해당 저작물을 일정한 조건에 의해 사용하도록 허락하는 GPL을 만들었다. 1989년 제1판이 발표된 이래 FSF는 대부분의 소프트웨어를 GPL에 의해 배포하였으며, 다른 많은 오픈소스 소프트웨어 개발자들도 본인들의 의사에 기하여 자신이 만든 소프트웨어를 GPL 조건으로 배포하였다. 그 결과 현재 GPL조건의 소프트웨어가 오픈소스 소프트웨어의 가장 많은 부분을 차지하고 있다.¹⁶²⁾ 오픈소스 소프트웨어¹⁶³⁾의 연혁을 간단히 정리하면 아래 표와 같다.

<표 V-2> 오픈소스 SW 운동의 연혁

역사	활동
1984년	- 리처드 스톨만(Richard Matthew Stallman, RMS)이 소스 코드의 사용이 자유로운 운영 시스템을 개발하기 위해 GNU project를 시작
1985년	- RMS이 자유 소프트웨어 재단(Free Software Foundation, FSF)을 창립(Free Software 운동 개시)
1989년	- GNU GPL 1.0 발표(1월)
1991년	- GNU GPL 2.0 발표(6월) - GNU LGPL(Library General Public License) 2.0 발표 - Linus Torvalds가 Linux 커널을 GPL로 공개
1998년	- 에릭 레이몬드(Eric Steven Raymond, ESR)가 오픈소스 이니셔티브(Open Source Initiative, OSI) 결성 - Netscape Communicator가 OSI 라이선스인 MPL 1.1로 발표
1999년	- GNU LGPL(Lesser General Public License) 2.1 발표 : Library에서 Lesser로 명칭 변경
2001년	- 우리나라 : 오픈소스 SW 연구 필요성 제기
2004년	- 우리나라 : 오픈소스 SW 육성 정부 시범 사업
2007년	- GNU GPL 3.0, GNU LGPL 3.0 발표 (6월) - 지식경제부에서 오픈소스 SW 라이선스 가이드 발표(11월)
2008년	- 지식경제부에서 오픈소스 SW 유지보수 가이드 라인 발표(1월) - 우리나라 : 2008년 이후 오픈소스 SW 생산 기반 요소인 커뮤니티 활성화 추진

을 통해 원본코드로부터 실제 사용가능한 컴퓨터 프로그램을 생성할 수 있다.

162) 이철남, “GPL의 주요내용과 개정동향에 관한 연구”, 「산업재산권」(통권 제22호), 한국 산업재산권법학회, 2007, 233-234면.

163) 통상 오픈소스 소프트웨어는 자유소프트웨어(Free Software)를 포함한 넓은 의미로 사용되며, 국내에서도 자유소프트웨어를 ‘공개소프트웨어’로 번역하여 사용하기도 하나, 본 고에서는 오픈소스 소프트웨어라는 용어로 통일하여 사용하기로 한다(김찬동, “소프트웨어 특허 인정에 따른 대응방안에 관한 연구”, 「지적재산권」(제25호), 한국지적재산권법제 연구원. 2008, 53면).

다. GPL의 이념과 원칙¹⁶⁴⁾

오픈소스 소프트웨어가 추구하는 자유는 구체적으로 i) 어떠한 목적으로든 프로그램을 실행할 수 있는 자유, ii) 프로그램이 어떻게 작동하는지를 연구하고 이용자의 필요에 맞게 수정할 수 있는 자유, iii) 주변의 이웃들을 돕기 위해서 프로그램을 복제 및 배포할 수 있는 자유, iv) 커뮤니티 전체의 이익을 위해 프로그램을 개선한 후 이를 공중에 공개할 수 있는 자유를 의미한다. GPL의 궁극적인 목표도 이와 같은 자유를 실질적으로 보장하기 위한 것으로 볼 수 있으며, 구체적으로 다음과 같은 원칙적인 내용과 조건을 담고 있다.

첫째, GPL 조건의 프로그램은 아무런 제한 없이 ‘사용’ 또는 ‘실행’ 할 수 있다. 다시 말해 복제, 배포행위 이외에 프로그램을 단순히 이용하거나 실행하는 행위는 아무런 조건 없이 누구나 자유롭게 할 수 있다.

둘째, GPL 조건의 프로그램을 수정하지 않고 소스코드형태로 배포하고자 하는 경우에는 저작권표시, 워런티가 없다는 표시, 해당 프로그램이 GPL에 의해 배포되고 있다는 표시를 하고, 동 프로그램과 함께 GPL 원문을 제공하기만 하면 GPL 프로그램을 자유롭게 ‘복제’, ‘배포’할 수 있다. 이때 이용자의 선택에 따라 복제물 제공에 대한 비용을 청구할 수 있으며, 유로로 워런티를 제공할 수 있다(GPL 제1조 후단).

셋째, GPL 조건의 프로그램을 수정한 2차적 프로그램을 작성한 후 이를 배포하고자 하는 경우, 저작권표시 등 제1조의 의무와 함께, 수정했다는 사실 및 수정일자를 명시하고, 2차적 프로그램 전체를 GPL에 의해 다시 제공할 것을 요구하고 있다(GPL 제2조).

넷째, GPL 조건의 프로그램을 오브젝트(Object) 코드나 실행파일 형태로 배포하고자 하는 경우에는 소스코드를 함께 제공하거나, 또는 최소 3년 동안 배포에 필요한 최소한의 비용만을 받고 소스코드를 제공하겠다는 문서와 함께 제공하여야 한다(GPL 제3조).¹⁶⁵⁾

이상과 같은 조건들을 준수하지 못할 경우 GPL에 의해 부여된 라이선스는 자동적으로 종료되며(GPL 제4조), 그럼에도 불구하고 계속해서 GPL 조건의 프로그램을 복제, 수정, 배포하는 경우에는 계약위반 또는 프로그램저작권침해의 책임을 지게 된다(GPL 제5조).

164) 이철남, 앞의 논문, 235-236면.

165) 다만, 소스코드를 제공받지 않은 상황에서, 다시 해당 소프트웨어를 비상업적으로 배포하는 경우에는 오브젝트코드 또는 실행파일과 함께 소스코드를 제공 받을 수 있는 정보를 담은 문서를 함께 제공하면 된다(GPL 제3조 c).

2. 오픈소스 SW 운동의 시사

오픈소스 소프트웨어는 독점 소프트웨어(proprietary software)와 동일하게 저작권 등에 의한 법적 보호를 받고 있으며, 이와 같은 권리에 기반을 두어 이용자에게 라이선스를 부여한다. 그러나 오픈소스 소프트웨어는 공개되어 있는 소스코드를 자유롭게 획득하고 접근할 수 있으며, 오픈소스 소프트웨어 라이선스를 준수하여 내용을 수정하거나 배포할 수 있는 특징을 가지고 있다.¹⁶⁶⁾ 아래 표는 일반 상용 소프트웨어와 오픈소스 소프트웨어의 비교표이다.

<표 V -3> 일반 상용 SW와 오픈소스 SW의 비교

구분	일반 상용 SW	오픈소스 SW
SW 배포형태	- 라이선스 계약에 의한 바이너리 파일 - 일반적으로 소스코드는 기업비밀로 유지	- 라이선스 계약에 의한 바이너리 파일의 소스코드를 공개 - 라이선스 조건하에 일반적으로 자유롭게 사용·복제·배포·수정 가능
사용자	- 주로 최종 사용자	- 주로 개발자
사용상 제약	- 라이선스 계약 내용에 따른 제약(사용료 지불)	- 사용상에 제약 없음(무료)
SW의 예	- MS Windows, Office, AutoCAD 등	- 아파치 웹 서버, MySQL, Perl 등
개발방법	- 조직 내 개발팀에서 제한된 인력(보안 유지) - 체계적인 로드맵에 의한 개발	- 커뮤니티 내 관심이 있는 모든 사람 - 관심 있는 개발자의 참여도 및 의지에 따라 좌우
단점	- 저작권사의 라이선스 정책에 의해 비용 부담 - 관심자들의 자발적 개발 참여 불가	- 문서화 미흡 - 리눅스 기반 애플리케이션 부족 - 제품보증 및 유지보수 어려움

* 출처: 공개SW역량프라자 정기 기술 세미나 자료(2010.8)

이러한 오픈소스 소프트웨어 운동은 카피레프트(Copyleft) 운동의 일종으로 소프트웨어가 독점 기업 등 다른 누군가에 의해 원래보다 자유가 더 제한된 조건으로 배포되는 것을 금지하고, 원본코드를 수정할 경우 그 수정사항을 다시 공개하도록 강제하는 제

166) 김찬동, 앞의 논문, 53면.

작물 사용허가 조건을 두도록 하고 있다. 이는 공동체가 자유롭게 사용가능하고 사회적으로 검증 가능한 소프트웨어를 생산하고, 사용을 독려함으로써 현재까지 상당한 성과를 거두었다. 과거 IBM과 마이크로소프트와 같은 몇몇 주요 소프트웨어 기업이 소프트웨어 개발을 주도하던 때와는 달리, 최근에는 다양한 분야에서 오픈소스 소프트웨어를 공동 개발하고 있으며 소프트웨어 산업 전반에 걸쳐 매우 큰 변화를 가져왔다고 할 수 있다.¹⁶⁷⁾ 이렇게 독점권과 명시적 이윤이 주어지지 않더라도 자유 소프트웨어의 공유지가 풍부해질 수 있었던 데에는 소프트웨어가 지적생산물이자 그 자체로 다른 생산을 위한 도구라는 특성을 간과할 수 없지만, 전통적인 공유지의 비극 논리나 재화의 독점을 정당화하고 강조하는 사람들에게 시사하는 바가 매우 크다고 할 수 있다.¹⁶⁸⁾

오픈소스 소프트웨어 운동은 기술공유와 협업을 가능케 하여 산업발전에 이바지할 뿐만 아니라 경제적·사회적 약자들에게도 평등하고 자유롭게 정보 시스템에 접근할 권리를 보장함으로써 공공의 이익도 도모하는 좋은 실례가 되므로 이를 벤치마킹하여 타 기술 및 산업 분야에도 활용할 수 없는지 연구해 볼 필요가 있다. 물론 오픈소스 소프트웨어도 2차적 프로그램에 대한 지식재산권 처리, 소스코드 제공 범위, 특허권의 취급, 다른 라이선서와의 양립성 등 다양한 문제가 있으며, 소프트웨어가 그 자체로 다른 생산을 위한 기능적 도구로서의 성격이 강한 특성으로 인해 오픈소스 운동이 큰 성과를 거두었을 수도 있다. 따라서 기술 및 산업에 따라 고유한 특성이 존재하므로 기술분야별 특성을 고려하여 공유화제도 도입의 가능성 및 효과를 예측하고 분석할 필요가 있다.

IV. 정리

이상으로 최근 민간 주도로 활발히 전개되고 있는 기술공유모델에 대하여 살펴보았다. 이러한 민간주도 기술공유모델이 현재 문제되고 있는 특허제도를 보완하기 위한 적합한 모델이 될 수 있는 지에 대해서는 면밀한 검토가 필요하다. 따라서 이하에서는 민간주도의 기술공유모델의 적용가능성과 그 한계에 대해 살펴보려고 한다.

Eco-Patent Commons는 환경보존을 위하여 기존 기술의 활용을 용이하게 하고, 새로운 이노베이션을 촉진하기 위해 지속가능한 개발을 위한 세계경제인회의(World Business

167) 전세계 인터넷에서 사용되는 웹서버와 웹브라우저 부문에서 자유 소프트웨어가 차지한 점유율이 각각 62.91%와 24.07%에 달하며, 주요한 소프트웨어 공동개발 사이트인 소스포지(<http://sourceforge.net>)에 등록된 소프트웨어 개발 프로젝트 개수만 해도 37만개를 넘어서고 있다고 한다(유성, “공유지의 비극은 없다”, 「인권 오름」 (<http://www.hr-oreum.net/article.php?id=1286> - 2010년 12월 방문).

168) 유성, 앞의 글(<http://www.hr-oreum.net/article.php?id=1286> - 2010년 12월 방문).

Council for Sustainable Development : 이하 'WBSCD')와 IBM, 노키아, 소니 등 기업에 의해 2008년 1월 설립된 환경관련기술의 공개, 활용에 관한 이니셔티브이다. Eco-Patent Common에 개방된 특허는 지구환경에 기여할 목적으로 참가 기업인 권리자로 부터의 권리불행사 규칙이 적용되고, 누구라도 무상으로 활용가능하다. 이렇게 함으로써, 이용자는 환경 부담을 회피하면서도 새로운 이노베이션을 창출하는 것이 가능하게 된다. 개방된 특허는 WBSCD의 웹사이트상의 데이터베이스에서 특허번호나 특허 요약 등의 기본정보로 열람가능하며, 상세한 특허정보에 대해서는 링크된 해당 출원국의 특허청 데이터베이스에서 열람 가능하도록 되어 있다. 2009년 10월을 기준으로 상기 기업을 포함하여 10개사가 가입되어 있으며, 100건에 가까운 특허가 등록되어 있다. 스스로 유지비도 지불하고 있는 특허를 환경목적으로 개방함으로써 이니셔티브에 참여하는 점은 높게 평가될 만하다.

한편, Science Commons는 Creative Commons의 성공에 자극받아 과학분야에서도 개방과 공유를 목적으로 설립된 조직이다. 각 연구자들과 기관들이 자신의 연구결과와 데이터를 개방하여 보다 나은 정책과 수단을 개발하도록 한다. 또한 전세계의 과학공동체 형성을 목표로 '오픈 데이터' 프로토콜을 공개하여 서로 다른 환경에서 창출한 데이터를 공유하고 사용한다. 여기에 표준화된 계약을 이용하여 연구자들이 쉽게 연구내용을 공유하고 활용할 수 있도록 하고 있다

또한, 특허협력제(Collaborations)의 모델의 하나로 볼 수 있는 GreenXChange는 전세계 10여개 기업 등이 참여하는 지속가능한 사업모델과 혁신의 지원을 위해 지식재산을 공유하고 상호협력을 도모하기 위해 창설된 조직이다. GreenXChange도 특허권자와 이용자 사이에 라이선스 협력을 할 수 있는 온라인 공간을 두어, 이를 활용하게 함으로써 기업들의 협력연구와 투자를 용이하게 해 주고 있다. GreenXChange는 기술혁신의 측면에서 특허제도를 보완하기 위한 민간주도의 기술공유모델이라 할 수 있다.

한편, Open Source 운동은 카피레프트(Copyleft) 운동의 일종으로 소프트웨어가 독점 기업 등 다른 누군가에 의해 원래보다 자유가 더 제한된 조건으로 배포되는 것을 금지하고, 원본코드를 수정할 경우 그 수정사항을 다시 공개하도록 강제하는 저작물 사용허가 조건을 둔다. 이렇게 함으로써, 공동체가 자유롭게 사용가능하고 사회적으로 검증 가능한 소프트웨어를 생산하고, 사용을 독려함으로써 현재까지 상당한 성과를 거두고 있다. 과거 IBM과 마이크로소프트와 같은 몇몇 주요 소프트웨어 기업이 소프트웨어 개발을 주도하던 때와는 달리, 최근에는 다양한 분야에서 오픈소프 소프트웨어를 공동 개발하고 있으며 소프트웨어 산업 전반에 걸쳐 매우 큰 변화를 가져왔다고 할 수 있다.

이와 같이, 민간주도로 전개되고 있는 각종 기술공유형 조직들은 각 분야에서 상당

한 성과를 내고 있으며, 긍정적으로 평가할만하다.

그러나, 이러한 민간주도 기술 공유조직들은 설립 이래 큰 폭의 참여기업, 특허가 증가하고 있다고는 할 수 없는 실정이다. Eco-Patent Commons 등에 개방된 것으로 지속 가능한 개발을 위해 주도적 역할을 발휘하는 기업으로서의 인지도를 확보하는 CSR 측면에서의 메리트나, 개방함으로써 비즈니스에 결부될 가능성 등 그 밖의 동기를 얻을 수 없거나, 또는 개방에 적당한 특허를 가지고 있는 기업이 없으면 참여하기 어려운 점이 난점이라고 할 수 있을 것이다.

특히, 특허기술공유를 선·진국 기술격차나 기후변화 해소(환경기술의 공유)의 측면에서 접근할 경우에는, 예컨대 Eco-Patent Commons의 경우에는 제공되고 있는 것이 특허번호만이므로 기술도입의 측면에 있어서 특허기술만을 도입할 목적으로 하는 환경기술을 실시할 수 있을 것인가라는 점을 들 수 있을 것이다. 다양한 기술로 구성된 환경기술에서 특허기술은 물건이나 방법이 어느 일부분을 구성하는 것에 지나지 않는 경우도 있다. 또한 특허공보에 기재된 기술정보나 특허권을 얻기 위한 내용에 한정되어 있는 경우도 많다. 이러한 점으로 볼 때, 아주 단순한 것이 아닌 한, 제품을 생산하거나 기술을 실현하기 위해서는 그러한 관련 노하우 등을 기술과 주변기술에 대한 이해가 불가피하다. 그리고 이것이 부족할 경우 특허공보기재정보만으로는 실제로 기술이전이나 기술도입이 어렵다. 선진국기업들 끼리도 특허정보만으로는 실시 곤란한 경우도 많이 있으므로, 개도국으로서는 특허 라이선스 및 특허정보를 얻는 것만으로는 의도하는 기술의 실현을 할 수 없는 경우가 많다고 생각된다.

제4절 일본의 GTPP 제안과 WIPO의 대응

I. 서설

특허제도의 제도론적 문제점으로 제기되고 있는 공익, 기술혁신 및 특허남용방지의 측면에서 이를 보완하기 위한 기술공유는 범국가적 차원에서 설계되어야 한다고 생각된다. 이러한 측면에서 일본 지재협회는 물론 환경기술의 기술이전에 한정된 측면의 연구이기는 하지만, 환경기술 패키지 테스트 포스를 설치하여 그린기술 패키지 프로그램(Green Technology Package Program: 'GTPP')를 제안하였다. 일본 지재협회의 제안내용의 일부를 WIPO에서 받아들여, 일본지재협회와 WIPO는 공동으로 기술공유에 대한 작업을 진행하고 있는 상황이다. 이하에서는 일본의 GTPP 제안과 WIPO의 대응을 중심

으로 살펴보고, 이러한 제안이 환경기술이전의 측면만이 아니라, 공익, 기술혁신 등 다른 영역에서 어떻게 활용되고 응용될 수 있는 지를 검토하고자 한다.

II. 일본의 GTPP 제안

1. 개도국으로의 기술이전의 과제

개도국이라고 하더라도, 개도국이라고 하기 어려운 정도의 발전을 거듭하는 국가도 있는 등 기술도입국의 상황이 매우 다양하다. 그러나 선진국으로부터 개도국으로의 라이선스할 경우에 대한 문제로서 기술제공 측과 도입 측의 매칭, 도입 측에서 기술 실시의 곤란성 및 라이선스 교섭력, 사용료 등 자금과 관련된 과제를 들 수 있다. 일본 지재학회는 이러한 과제를 해결하고, 개도국에 대한 특허·기술 라이선스를 포함한 환경기술의 기술이전을 촉진하기 위한 새로운 대처 가능성에 대하여 검토하였다.¹⁶⁹⁾ 그 결과 새로운 체제를 제안으로 하는 “Green Technology Package Program(GTPP)”를 제안하였다.

2. 그린기술 패키지 프로그램(GTPP)¹⁷⁰⁾

가. GTPP의 특징

GTPP의 특징과 요구되는 역할 및 조직에 대하여 설명하면 다음과 같다.

① 제공자 측으로부터 도입자 측으로 제공되는 기술·서비스의 내용

도입 측의 능력에 대응하여, 필요한 특허, 노하우, 인적 역무 및/또는 부품·소재 등을 기술제공자 측의 가능한 범위에서 패키지로 제공하는 한 것으로 한다.

② 운영주체의 역할

169) 日本知的財産協会(2009年環境技術パッケージタスクフォース), "Green Technology Package Programの提案", 「知財管理」(Vol. 60), 2010, 1012頁.

170) 日本知的財産協会(2009年環境技術パッケージタスクフォース), 위의 논문, 1012-1016頁 참조.

- 기술도입 측이 그 도입의 장점을 이해하기 쉽도록 GTPP에 기해 제공 가능한 환경기술에 대하여 각 기술의 특징, 이용되는 특허의 정보, 그 밖의 기술과의 비교정보, 제공조건, 모델 계약 등을 종합하여 웹사이트 상 등의 데이터베이스에서 제공한다(다만, 게시된 정보의 범위는 제공측이 개별적으로 결정한다)

- 기술제공 측과 도입 측과의 코디네이터 역할, 또는 경우에 따라서는 어드바이스로서 제공 측 및 도입 측 쌍방으로부터 독립 또는 공평한 입장에서 교섭의 중개 또는 어드바이스 등을 하고, 상대거래를 촉진하는 역할을 담당한다.

- GTPP에 기해 기술이전에 대하여 기술제공 측과 도입 측에 대하여 CDM의 이용, 정부에 의한 배출권 매수·우대세제의 이용, 환경관련 각종 기금과 ODA의 활용절차 등을 지원한다.

- GTPP에 기해 기술이전에 있어서는 현존하는 각국의 라이선스 규제의 적용제외로 하는 동향 등을 파악해 가는 등, 장애를 배제·경감하고, 기술이전을 촉진하기 위한 정책을 추진한다.

- GTPP에 의한 기술이전을 안심하고 행하거나, 또는 이를 촉진하기 위한 틀(지재침해보험 등)의 구축을 추진하거나, 적용의 바람직한 조건에 대하여 당해 틀을 소개하여 이용을 촉진한다.

③ 운영주체의 조직형태

UNFCCC나 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization: 이하 'WIPO')의 하부조직으로 한 공평성과 구체성을 확보할 수 있는 조직

나. 사용료 등 자금 측면에 대한 해결방안

개도국이 선진국으로부터 환경기술이전을 받을 경우 로열티가 부담되어, 기술이전을 진행할 수 없다는 개도국의 주장이 있다. 이는 지불능력이 충분히 있는 일부 국가나 기술 도입처를 제외하고는 소지격차나 통화가치의 차이를 고려하면 현실적인 과제에 해당된다. 한편 개발비나, 특허비용을 부담한 기술제공 측, 즉 선진국으로서는 자기가 보유하는 지식재산을 제3자에게 사용시키는 이상 대가를 얻는 것은 당연한 행위이며, 또 소유자로서 널리 인정된 권리라고 할 수 있다. 주식회사라면, 발생비용의 회수를 할 필요도 없고, 주주 등 스테이크스 홀더에의 합리적인 설명과 세무적인 리스크를 배려할 필요도 있다.

즉 기술이전을 위한 상시적인 조직을 창설하기 위해서는 도입 측이 개도국 법인이며

나, 도입기술이 환경기술인 점으로 인해 대가를 염가로 하는 것은 바람직하지 않을 것이다. 그래서 적절한 대가를 수령하고, 어디까지나 비즈니스 측면에서 생각하지 않으면 선진국 기업이 제공 가능한 GTPP의 대상기술로 하는 동기가 되지 않는다. 대가 지불의 곤란함 때문에, 개도국에 의해 라이선스에 의한 기술도입이 늦어지고 있다면, 이를 해결할 수 있는 방안을 제시하지 않는 한 일정한 한계가 있다. 그러한 현실적인 과제를 앞서 개도국의 요청 및 선진국의 기술이전·지원으로의 협력의무의 균형을 어떻게 맞추어 갈 것인지에 대한 검토가 급선무이다. 이러한 관점에서 일본 지재학회는 다음과 같이 제안하고 있다.

- (1) GTPP에 의해 실현되는 프로젝트는 가능 또는 프로젝트 참가자의 요청인 경우 CDM 사업의 대상으로서 등록. 당해 인증된 프로젝트의 주체적 참가자인 자금제공자나 기술제공자는 그 사업에 의해 발행된 CER(Certificate Emission Reduction: 이하 'CER') 즉 배출권의 전부 또는 일부 또는 그 환가금액을 자금제공의 상환이나 기술이전 대가로서 수령하는 방법
- (2) GTPP에 의한 기술이전 대가를 기술이전을 지원하기 위한 기금 등으로부터 차출하는 방법

(1)의 방법(CER 또는 환가금액의 수령)에 대하여 구체적으로 설명하면, GTPP의 대상이 환경기술을 전제로 하는 것이므로, 환경기술에 관한 특별한 조치인 CDM(Clean Development Mechanism: 이하 'CDM')을 포스트 도코의정서의 구조 하에서 계속 진행하고, 이를 개량 이용하여 기술제공 측이 CER 또는 대가를 수령하는 방법이다. CDM은 국가연합CDM이사회에서 인정된 온난화 가스 삭감 프로젝트에서 실현된 온실가스의 삭감분을 CER 즉 온난화 가스 배출의 제한범위로 하여 프로젝트 참가자(자금이나 기술제공자 등)가 획득할 수 있다.

현재 수준에서는 CDM의 프로젝트 참가자가 되기에는 당해 프로젝트에 자주적으로 참가하고 있는 자일 것이 필요하며, 단순한 라이선서는 프로젝트 참가자가 될 수 없다.

예를 들면, 풍력발전기술을 보유하고 있는 일본의 X사가 CDM 사업을 수행하는 Y사(전력회사)에 직접 기술을 제공할 경우 X사는 프로젝트 참가자로서 CER을 획득할 수 있다. 그러나 X사가 실시국 Z사에 기술공여를 하고, Z사가 Y사의 풍력발전설비를 건설할 경우는(X사는 건설에 직접 관여하지 않고) X사는 프로젝트 참가자로서 인정되지 않을 가능성이 있다. 이러한 다양한 경우에도 X사를 프로젝트 참가자로 인정하여 CER의 분배를 받을 수 있는 것을 규칙으로 한다.

또한 현행 CDM 규칙에서는 그러한 대상사업은 프로젝트 마다 심사를 받아 등록될

필요가 있다. 그러한 심사는 복잡하며, 상당한 비용과 시간을 요한다. 여기서 GTPP에 기재 동일한 라이선스 기술을 이용한 프로젝트에 대해서는 간단한 심사로 등록을 가능하게 하거나 심사 수수료나 등록료 등의 우대조치를 받을 수 있도록 한 CDM의 규칙을 개선한다. 일본 정부로서는 배출권을 외국으로부터 구입할 예정에 있으므로, GTPP 하에서 CDM을 이용한 경우에 있어서 기술 제공 측이 현금으로서 기술대상의 수령을 희망할 경우에는 CER을 지정관리기관에 예치하고, 해당 관리기관으로부터 제공측은 환가액을 수령하고, 그 후 해당 크레딧을 국가가 매수하는 방법을 둘 수 있다고도 생각된다. 혹은 국가로서는 도입 측에 현금을 지급하는 방법 이외에도 세제혜택을 당해 제공 측에 주는 것도 검토 할 수 있다.

CDM을 이용할 때의 유의점으로서 프로젝트가 등록할 수 없는 등의 이유로 CER을 획득할 수 없게 되는 취소의 리스크나 실제 배출삭감량이 전적량보다 적게 됨으로써 CER 발행량이 감소하는 수행리스크를 들 수 있다. 이용할 때에 다양한 리스크에 유의한 대처를 하는 것이 불가결하다.

또한 CDM 자체에도 지정인증기관의 편재나 CDM 사업실시국의 편재, 심사의 질과 소요시간 등의 과제도 있다. 전술한 바와 같이, 라이선스 대상사업으로의 이용촉진을 위한 규칙을 개선하는 한편, 보다 공평하고 수용성이 높은 규칙을 제정하는 것도 요구된다.

(2)의 방법(기술이전지원기금의 이용)에 대하여 구체적으로 설명하면, UNFCCC 교섭에 있어서는 개도국으로부터 기술지원·이전에 기여하는 펀드를 조성하는 것이 요구되고, 또한 선진국도 각각 자금 원조를 할 예정이다. 이를 설립하거나 현존하는 조직을 이용할 수 있다면 이를 이용하여 개도국에 의한 완화 행동에 기여하는 기술이전의 대가는 그 기금으로부터 충당할 수 있는 것으로 한다.

구체적으로는 UNFCCC 하에서 환경기술의 이전을 위해 요구되는 자금을 충당하는 기술이전추진기금을 창설 또는 설정한다. 개도국으로의 기술이전을 할 경우 그 대가의 전부 또는 일부로서 제공 측에 일정한 규칙에 따라 라이선스 크레딧(예를 들면, 제공기술의 대가로서 일정액에 해당하는 라이선스 크레딧)을 얻는 형태로 사전에 해당기금 또는 그 인증기구에 신청하고 인증을 받는다. 기술제공 측은 획득한 라이선스 크레딧을 기금에 환가하여 대가를 수령할 수 있는 것이다. 이러한 이용을 촉진함으로써 기술이전 대가가 확실히 수령가능하게 된다. 인증이나 기금 착출에 있어서는 공평성 및 투명성이 높은 규칙과 운용이 필요하다. 정부개발원조(Official Development Assistance:

이하 'ODA')나, 지구환경시설(Global Environment) 그 밖의 환경자금을 이 기금으로서 또는 이들 펀드를 그 밖의 이용 가능한 방법으로 활용하여 기술이전을 위해 이용하는 것도 검토할 수 있다.

3. 라이선스 규칙의 완화·철폐에 대한 국제 규범 검토

GTPP에 의한 기술이전을 강력히 지원하는 것이라면, 현재 선진국에는 없고, 개도국에만 존재하는 기술이전의 장해가 되고 있는 각국에 있어서의 라이선스 규제를 GTPP의 특허·기술 라이선스에 대해서는 적용제외로 하는 새로운 규범을 UNFCCC나 기타 국제조약의 틀에서 인정하는 것도 충분한 기술이전촉진에 공헌하는 것이 될 수 있다. 규제의 예로서는 특허·기술 라이선스료의 상한한도, 노하우 라이선스의 가능한 기간의 제한, 그랜트 백에 관계한 제한, 보증의무, 소스코드의 개시의무, 계약등록의무 및 외국으로의 송금허가 및 인가제도 등 기술이전 측으로 에서 보면 그러한 규제가 있으므로 기술이전을 하는 것에 주저하는 것도 사실이다.¹⁷¹⁾

기술도입 측 및 해당국에 환경기술도입에 따라 얻을 수 있는 장점은 명백하며, 개도국에서도 기술이전 촉진을 위한 타협이 있어야만 한다. 개도국에도 선진국과 동등 이상의 자금 및 경쟁력이 있는 기업도 급증하고 있다. 그러므로 선진국에 대해 지금까지 온난화 가스를 경제활동으로 배출해 왔다는 역사적 책임을 물어 자금이나 기술을 요구하는 것만으로는 선진국도 불공평함을 느끼는 점도 부정할 수 없다. 개도국의 경제에도 기여하는 기술이전을 요구하는 것이라면, 개도국은 자국의 규제가 그 장해가 되고 있음을 인식하고, 규제 폐지 등에 대해서도 검토해야한다. 또한 그러한 규제의 일시적 완화나 철폐 등의 노력을 선진국 정부와 협력하여 요구하는 것도 GTPP 운영주체에 의한 선진국 및 개도국 쌍방의 서비스로서 고려해야한다고 제안하였다.¹⁷²⁾

4. 기타 추가 서비스의 검토

특허 라이선스에 있어서 그 특허의 침해보증을 하는 것이 강제되는 국가도 있다. 그러한 경우에 있어서 실제 제3자의 권리를 침해하게 될 경우 침해액을 담보하는 지재침해보증을 창설하는 것도 특허라이선스를 할 때 일조할 수 있는 도구로서 검토할 수 있다. 또한 환경 분야에서 벤처 캐피탈을 관여시키는 것도 제공 측은 특허·기술 라이선스의 대가를 투자액으로부터 충당시킬 수 있는 것으로 부터도 환경기술의 개도국으로

171) 日本知的財産協会(2009年環境技術パッケージタスクフォース), 앞의 논문, 1016-1017頁.

172) 日本知的財産協会(2009年環境技術パッケージタスクフォース), 위의 논문, 1017頁.

의 보급을 촉진하는 것이라고 생각된다. 이러한 경우에는 환경 벤처캐피탈은 도입 측에 있어서는 특허·기술 라이선스를 얻음과 동시에 벤처캐피탈로부터 유용한 정보를 얻거나, 보다 많은 자금을 확보할 수 있는 선택지로서 기술제공 측 또는 도입 측이 이용할 수 있는 기능도 있다.

이들은 GTPP 범위 외에도 성립할 수 있는 것이며, 또한 추가적인 톨의 일부가 되는 것이지만, GTPP 운영주체는 GTPP에 기해 기술이전·지원을 당사자가 보다 원만히 안심하고 할 수 있도록 이들 조직을 창설에 관여하고 설립된 경우에는 안전에 따라 이용이 바람직한 경우에 있어서 제공 측 또는 도입 측으로의 소개를 하는 형태가 될 것이다.¹⁷³⁾

III. WIPO의 대응

WIPO는 일본 지재협회에서 제안한 GTPP 프로그램의 내용 중에서 '환경기술에 관한 DB' 구축하자는 건의를 받아 들였다. 그래서 2011. 1. 17일 일본지식재산협회(JIPA)는 세계지식재산권기구(WIPO)와 공동개발한 '환경기술DB'의 시험판을 오는 6월에 공개할 예정이다. 이 '환경기술DB'를 통해 환경기술의 도입을 희망하는 개발도상국의 정부와 기업의 요구 사항, 기업 등이 제공할 수 있는 지식재산 및 지원 서비스 정보 등을 '환경기술DB'에 등록함으로써, 쌍방의 원활한 환경기술이전을 촉진할 수 있도록 하고 있으며, 향후 성립된 계약 정보 등의 등록도 검토하고 있다.

이러한 '환경기술DB'를 이용하면 기술을 제공하는 측과 도입하는 측이 상대를 찾아낼 수 있으며, 구체적인 교섭에서는 공적개발원조(Official Development Assistant, ODA)나 개발도상국이 가진 배출권을 활용할 수 있는지, 환경기술을 보유한 기업의 지식재산부서가 얼마나 문제의식을 가지고 이 새로운 과제에 도전할 것인지가 큰 과제될 수 있다.¹⁷⁴⁾

제5절 소결

이상 살펴본 바와 같이, 특허기부제도와 특허풀, 그리고 Eco-Patent Commons 등 종래 기술공유모델과 최근 민간주도의 기술공유모델은 일정한 한계가 있다. 기술공유는 국가적 내지는 국제적 관점에서 논의되어야 하고, 이러한 측면에서 볼 때, 일본이 제안한 그린기술 패키지 프로그램과 WIPO의 노력은 현행특허제도를 보완하기 위한 기술공유모델에 있어서 주목할 만한 시사점을 주고 있다.

173) 日本知的財産協会(2009年環境技術パッケージタスクフォース), 위의 논문, 1017頁.

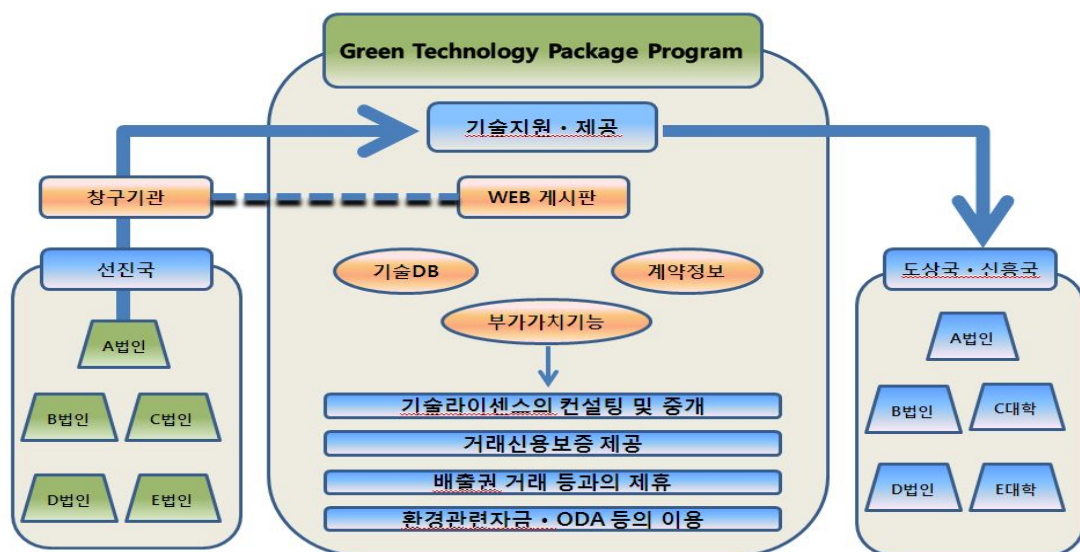
174) <http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/110117/cpd1101170503009-n2.htm> 참조.

이를 간단히 요약하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

지구온난화의 문제에 있어서는 환경기술의 보급이 가장 중요한 문제지만, 도상국 측에서는 환경기술 보급을 저해하는 가장 큰 요인으로 특허권을 들고 있으며, 선진국이 소유한 환경 기술에 관한 특허를 강제허락 하도록 요구하고 있다. 그러나 현실적으로 도상국에는 노하우나 기술이 없어 특허를 강제허락한다고 해도 환경기술이 보급되지 않을 가능성이 높다. 그래서 강제허락에 반대하는 것만으로는 기술의 보급은 이루어 지지 않는다. 따라서 환경기술의 보급을 위하여 비즈니스를 기반으로 한 거래를 원칙으로 하는 새로운 구조가 필요하다. 도상국과의 거래를 염두해 둘 경우 ODA의 활용도 적극적으로 검토하는 것이 효과적이다.

환경기술이전을 촉진하기 위해서는 특허만이 아니라 기술정보, 생산설비, 투자계획, 구성원 계획 등 세부사항을 포함한 형태의 환경기술 패키지를 상품으로 한 진정한 의미에서의 기술공유(Technology Commons)를 하여야 한다. 특히 제공기업 스스로 상품의 가격을 결정하고, 상품의 구성은 특허 라이선스만이 아니라 다른 구성요소의 개별 판매도 가능하도록 한다. 그래서 Commons에 참가할 것인지, 참가할 경우 어떠한 상품을 투입할 것인지에 대한 사항 모두를 개별기업이 판단한다. 첨단 기술 뿐만 아니라, 오래된 기술이나 특허 등도 가능하다. 상품의 구매자는 환경기술의 이전을 희망하는 국가지만, 반드시 도상만을 의미하는 것은 아니고, 전 세계국가 대상이 될 수 있는 개념의 기술공유 프로그램이다.

<그림 V-1> 녹색기술 패키지 프로그램 하에서의 기술이전의 예1)



제6장 결론

이 장에서는 지금까지의 논의를 요약·정리하고, 공익과 혁신의 측면에서 특허제도를 보완하기 위한 기술공유를 위한 방향성을 제시하고자 한다.

우선, 19세기 유럽에서 일어났던 특허제도의 비판론에서 국제특허제도가 탄생하기까지의 역사적 전개과정을 살펴보면, 당시의 상황 즉 대공황에 의한 보호무역으로의 전환, 미국의 국제특허정책, 유럽 각국의 산업혁명의 진전, 강제실시제도의 수용 등 이 시기는 특허제도에 대한 새로운 패러다임이 요구되었던 시기라고 할 수 있다. 이러한 새로운 패러다임 하에, 특허제도는 시대적 요청에 부응하면서 새로운 제도가 수용되거나, 폐기되면서 진보를 거듭하여 왔다. 이러한 19세기의 상황은 오픈이노베이션, 공익과 기술혁신, 특허남용의 문제 등이 제기되는 현시점과 유사하다. 최근 이러한 특허제도에 대한 새로운 패러다임을 요구하는 주장들이 유럽, 미국, 일본을 중심으로 활발히 전개되고 있다. 그러한 관점에서 기술 공유는 새로운 패러다임의 대안 중에 하나로서 논의할 가치가 크다는 결론을 도출하였다.

또한 오늘날 발생하고 있는 특허제도의 제문제는 공익(기후변화, 환경, 공중보건)과 기술혁신(리서치 툴), 그리고 특허남용(patent troll 및 특허풀)에 대한 문제점이 제기되고 있는 실정이다. 이는 특허제도의 지나친 독점성에 대한 문제로부터 출발한다. 산업 발전을 위해 탄생한 특허제도는 지금까지 충분한 역할을 해 왔고, 특허제도가 산업의 발전, 넓게는 인류의 발전을 저해하는지 여부에 대해서는 명확한 근거가 있다고는 할 수 없다. 다만, 오픈 이노베이션, 공중보건, 환경 등이 중요해진 현 시점에서는 현행 특허제도의 한계를 보완할 새로운 장치가 필요해졌다. 특히 환경문제나 인류의 건강과 관련된 영역에 대해서는 기술공유의 필요성이 더욱 높아지고 있고 있으며, 이에 대한 해결방안으로서 기술 공유에 대한 적극적인 논의와 검토가 필요하다고 결론지었다.

이와 더불어, 각계 기술공유 전문가를 대상으로 한 설문조사 결과를 종합하면, 기술공유는 특허제도를 보완하기 위한 하나의 수단으로서 큰 메리트가 있으며, 민간차원뿐만 아니라 국제기구 및 정부차원의 노력을 기울일 필요가 있다는 것이다. 또한 특히 환경이나 공공의 이익과 관련된 특허제도의 문제점에 대해서는 다른 분야보다 전향적인 검토가 필요하다고 하였다.

마지막으로 특허제도를 보완하기 위한 기술공유모델의 분석결과를 살펴보면, 특허기부제도와 특허풀, 그리고 Eco-Patent Commons 등 종래 기술공유모델과 최근 민간주도의 기술 공유모델은 특허제도를 보완하기 위한 모델로서는 일정한 한계가 존재한다고

결론을 내렸다. 기술 공유제도는 국가적 차원 내지는 국제적 차원에서 논의되어야 하며, 이러한 관점에서 일본의 제안(환경기술의 이전 내지는 환경기술의 공유에 한정)과 국제기구인 WIPO의 노력이 오히려 실현가능성이 있고, 시사성이 있다고 판단하였다.

따라서 특허제도를 보완하기 위한 기술 공유를 전개함에 있어서는 다음과 같은 방향성이 필요할 것이다. 일본의 제안(그린패키지프로그램)과 같이, 기술 공유가 필요한 분야를 선정하고, 당해 분야의 기술공유와 관계된 노하우, 인적요소 등을 패키지화하며, 기술 공유를 전개할 운영주체(조직)를 창설하는 것을 전제로, 기술공유에 필요한 자금 확보방안, 각종 규제 등도 종합적으로 검토하여야 할 것이다.

참고문헌

[국내문헌]

- 강경남, 「지식재산권이 연구개발 활동에 미치는 영향에 대한 연구」, 특허청, 2008
- 김영배, “사용자 혁신(User Innovation)과 기술공유: 혁신의 새로운 추세”, 「IP Policy」 (통권 제3호), 한국지식재산연구원, 2010
- 김찬동, “소프트웨어 특허 인정에 따른 대응방안에 관한 연구”, 「지적재산권」 (제25호), 한국지적재산권법제연구원, 2008
- 김해도, “산학협력 촉진을 위한 특허기부제도 활성화 방안에 관한 연구”, 「지식재산21」 (통권 제91호), 2005
- 구대환, “특허폴의 결성과 운영”, 「저스티스」 (통권 제109호), 2009
- 오승한, “EU경쟁법에 의한 특허권자의 특허폴 및 특허플랫폼에 대한 규제”, 「경쟁법연구」, 한국경쟁법학회, 2008
- 육소영, “리서치 톨 특허와 그 보호의 정당성”, 「산업재산권」 (통권 제28호), 한국산업재산권법학회, 2009
- 신지연, 기술공유화에 대한 정책적 논의(Policy Focus 전문가 좌담회 토론문), 「IP Policy」, 한국지식재산연구원, 2010
- 이대회, “특허폴 및 그 유효성에 관한 연구”, 「산업재산권」, 한국산업재산권법학회, 2004
- 이수웅, 「특허법」, 한국교육문화원, 2006
- 이종일, 「특허법」, 한빛지적소유권센터, 1996
- 이주현, “Patent Troll의 특허권 남용에 대한 법적대응방안검토”, 「Law & Technology」 (제5권 제1호), 서울대학교 기술과 법센터, 2009
- 임근영 외 3인, “특허권 기부제도 및 증권화 연구”, 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2002
- 전국경제인연합회의, “정책건의-대기업 특허기부제도 도입에 관한 의견”, 2004
- 전기억, “특허의 기부제도와 증권화 방안에 관하여”, 「지식재산21」 (통권 제79호), 2003

- 전기억·박진우·최성진, “국내 특허폴의 결성전략에 관한 소고”, 「지식재산 21」 (통권 제100호), 특허청, 2007
- 정연덕, “특허폴에 관한 법적 연구-활성화 방안을 중심으로-”, 서울대학교 법학박사 논문, 2005
- 정연덕, “공공기술의 사유화와 기술공유”, 「IP Policy」 (통권 제3호), 한국지식재산 연구원, 2010
- 조명선, “Research tool 특허에 관한 생명과학분야의 최근 이슈”, 「지식재산21」 (통권 제101호), 특허청, 2007
- 최승재, “IT 기술 혁신을 위한 특허폴의 유용성과 전망-미국 사례를 중심으로-”, 「IT와 법 연구」 (제3집), 경북대학교 IT와 법 연구소, 2009
- 한국과학기술정책관리연구소, “중소기업에 대한 기술무상양허사업 성공사례”, STEPI 조사자료 96-20, 1996
- 황종환, 「특허법」, 한빛지적소유권센터, 2001
- 오승한, “방어적 특허폴 구성과 부속약적에 대한 경쟁제한성 평가”, 「성균법학」, 2008
- 이철남, “GPL의 주요내용과 개정동향에 관한 연구”, 「산업재산권」 (통권 제22호), 한국산업재산권법학회, 2007

[일본문헌]

- マーキュア・E. R., 「1873年ウィーン國際特許會議」, 知的財産法の系譜 小野昌延古稀記念論 文集, 青林書院, 2002
- 大本富夫, 「近代ドイツの特許と企業家活動 - 鐵鋼・電機・ビール經營史研究」, 泉文堂, 2002
- 大河内曉男, 「發明行爲と 技術構想 - 技術と 特許の 經營史的 位相 -」, 東京大學出版會, 1992
- 山根裕子, “知的財産權のグローバル化-醫藥品アクセスと TRIPS 協定”, 2008
- 上野貴弘・杉山大志, “溫暖化防止技術の國際技術移轉-中國への技術移轉の事例分析を通じて-”, 『電力中央研究所報告 Y08023』, 電力中央研究所, 2009
- 石井 正, “特許廢止論から國際特許制度への轉換の時代”, 「パテント」, 日本弁理士會,

Vol. 61, 2008

玉井克哉, 「特權付与から行政行為への史的発展-ドイツ特許制度成立過程の一断面」, 行政法の發展と変革 塩野宏先生古稀記念, 有斐閣

日本知的財産協會(2009年環境技術パッケージタスGCクフォース), "Green Technology Package Programの提案", 「知財管理」(Vol. 60), 2010

財團法人國際投資研究所公正貿易センター『「TRIPS 研究會」報告書・平成20年度』, 2009

中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2010

土井輝生 譯, 「特許制度の經濟學」, 日本經濟新聞社, 1975

河内曉男, 「發明行為と 技術構想 - 技術と 特許の 經營史的 位相 -」, 東京大學出版會, 1992

J. ジャクソン, 「ドーハ閣僚會議の印象」『經濟經濟ジャーナル』 Vol. 35, No.2, 2002

[歐美文헌]

Batzel, V. M., "Legal Monopoly in Liberal England : The Patent Controversy in the Mid-Nineteenth Century", 「Business History」 Vol. 22, No.2, 1980

Breda Sandburg, Inventor's Lawyer Makes a Pile from Patents, The Recorder, July 30, 2001

Doorman, G., "Patent Law in the Netherlands-Suspended in 1869 and Reestablished in 1910-"Journal of the Patent Office Society Vol.30, No.3, 1948

E Mansfield, M Schwartz and S Wagner, 'Imitation Costs and Patents: An Empirical Study', The Economic Journal, 91, 1981

Ladas, S.P., "Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection", 1975

Landes, D. S., "The Unbound Prometheus-Technological change and industrial development in Western Europe from 1750 to the present", 1969

Lerner. J., "Patent Policy Innovations : A Clinical Examination" Vanderbilt Law Review, Vol. 53 No.6, 2000

- Machlup, F, "An Economic Review of the Patent System" ,1958
- Machlup, F. & Penrose, E., "The Patent Controversy in the Nineteenth Century",
「The Journal of Economic History」 Vol. 10, No.1, 1950
- Macleod, C., "Concepts of Invention and the Patent Controversy in Victorian Britain" Technological Change Methods and themes in the History of Technology(Edited by Fox, R.) 「Harwood Academic Publishers」 , 1996
- Mandich, G."Venetian Patents", Journal of the Patent Office Society Vol. 30, No. 3, p. 1450-1550
- Marlan D. Walker, "The Patent Research Tool Problem After Merck v. Integra", 14 Tex. Intell. Prop. L. J, 2005
- Janis, M.D., "Patent Abolitionism", 「Berkley Technology Law Journal」 Vol.17, 2002
- Jeremiah Chan & Matthew Fawcett, Footsteps of the Patent Troll, 10 No.1 Intell. Prop.L.Bull.1, 1-2, 2005
- Jonathan Kahn, "What's the Use? Law and Authority in Patenting Human Genetic Material", 14 Stan. L. & Pol'y Rev., 2003
- Kronstein, H. & Till, I., "Reevaluation of the International Patent Convention", Law and Contemporary Problems, Vol. 12, 1974
- Penrose, E. T., The Economics of the International Patent System, The Johns Hopkins Press, 1951
- Ritter, D. S., "Switzerland's Patent Law History" Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal Vol. 14, No. 2, 2004
- Schiff, E., "Industrialization without National Patents : the Netherlands 1869-1912 : Switzerland 1850-1907", 「Princeton University Press」 , 1971
- USPTO, Revised Interim Guidelines Training Materials.

[기타자료]

<http://likms.assembly.go.kr/bill/jsp/main.jsp> (국회의안정보시스템)

<http://www.wbcds.org/web/epc>

<http://sciencecommons.org/projects/greenxchange>
<http://www.hr-oreum.net/article.php?id=1286>
<http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/110117/cpd1101170503009-n2.htm>
http://www.rim.com/news/press/2006/pr-03_03_2006-01.shtml
<http://www.chicagotribune.com/technology/chi-0602190193feb19,1,2188886.story?coll=chi-techtopheds-hed>
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A51969-2005Jan5.html>
<http://www.ipvalue.com/company/index.html>
<http://www.mosaid.com/corporate/about/profile.php>
<http://www.us.designreuse.com/news/news10022.html>
<http://www.cioinsight.com/article2/0,1540,1902291,00.asp>

부 록 1 : 설문조사 내용

기술공유화 제도에 대한 의견 수렴을 위한 설문조사

귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

저희 한국지식재산연구원에서는 「특허제도를 보완하기 위한 기술공유화에 대한 연구」라는 과제를 수행하고 있습니다. 국내 학계·산업계·연구계의 전문가들을 대상으로 특허제도의 문제점과 이를 보완하기 위한 관련 제도 및 정책에 대한 의견을 수렴하고자 합니다. 본 조사의 목적은 의약품 및 리서치 툴 관련 특허의 독점, 환경(기후변화)관련 특허의 독점으로 인한 문제, 패턴트롤(특허권 비실시자의 특허권 행사) 등 기존 특허제도의 문제들을 해결하는 방안으로서 특허제도를 보완하기 위하여 각계의 전문가 분들의 의견을 수렴·분석을 통하여 특허제도를 보완하기 위한 제도적·정책적 방안을 마련하는 데 있습니다.

설문에 참여하시는 분들의 성의 있는 고견은 특허제도의 폐해를 보완하는데 중요한 기초자료로 활용될 것입니다. 본 조사의 결과는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 설문에 응한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 비밀과 무기명으로 처리되고 통계분석이외의 목적에는 사용되지 않음을 말씀드립니다.

아무쪼록 바쁘시겠지만 소중한 의견을 부탁드립니다.

2010년 12월

- 주관기관 : 특허청 · 한국지식재산연구원
- 조사기관 : 000
- 설문 내용 관련 문의처
- 회신 및 응답 관련 문의처 : 000

응답요령

■ 기본수칙

1. 특별지시표시 ➡가 없는 한, 순번에 따라 차례대로(예; 1→2→3 ...) 응답합니다.
2. 특별지시표시 ➡가 있는 경우
 - 설문항목 중에 ➡표시가 부기(附記)된 경우 「지시한 설문항목으로 이동(移動)하라」는 의미이므로
 - ➡ 표시가 부기(附記)된 해당 항목을 체크한 후
 - 지시된 설문 항목으로 바로 이동하여 응답합니다.
 - 이동한 이후에는 다시 순번에 따라 차례로 응답합니다.
3. ‘복수응답 가능’이라는 지시문구가 없는 한, 응답은 반드시 1개로 합니다.
4. 원칙적으로 모든 설문항목에 응답해야 합니다.

■ 응답자 인적사항

응답자	성명			
	소속/직급			
	연락처		이메일	

1 기술 공유에 대한 인식 조사

지식재산은 지식기반 경제사회에 있어서 성장을 위한 주요 자원으로 인식되고 있습니다. 1980년대 이후부터 미국을 비롯한 주요 선진국은 지식재산의 독점적 활용을 강조하고 지식재산 보호를 위한 정책을 강화하여 왔습니다. 최근에 지식재산이 소송, 창업, 투자자산 등의 시장에서 경쟁 수단을 목적으로 활용되는 경우가 증가하고, 공공영역에 까지 지식재산의 사유화가 진전됨으로 인하여 지식재산 활용에 대한 변화를 요구하는 움직임이 나타나기 시작하였습니다. 혁신 패러다임이 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로 변화함에 따라 지식재산을 ‘독점’에서 ‘공개’로 하여 지식재산을 공동 활용하고, 공공의 이익과 관련된 분야에 대한 사적이익(독점권)과 공공의 가치에의 균형을 도모하기 위하여 지식재산 정책을 재고해야 한다는 의견도 제기되고 있습니다. 다시 말해, 기술혁신 및 공익 도모를 위하여 기존의 지식재산권 특히, 특허권 제도의 개선 및 보완이 필요하다고 할 수 있습니다. 이러한 움직임은 공중보건 분야, 기후변화와 관련한 환경보전 및 대체 에너지 개발 분야, 컴퓨터프로그램 분야 등에서 두드러지게 나타나고 있습니다.

대표적인 예로는 환경과 생태계를 직·간접으로 개선 또는 보호하는 특허를 공유하여 환경보전에 이바지 하고자하는 ‘EPC(Eco-Patent Commons)’, 환경을 보호하고 그린 경영을 실천하는데 도움을 줄 수 있는 특허를 서로 공유하고자 하는 ‘Green Xchange’, 소프트웨어에 대한 사용·복제·배포의 자유와 소스코드를 학습·수정·개선할 수 있는 자유를 부여하는 ‘Open Source S/W’, 열대 질병 치료를 위하여 신약 개발 시 연구 결과를 공개토록 하는 ‘Open Source Drug Discovery Project’ 등이 있습니다.

* 본 설문에서 넓은 의미로 기술 공유라는 용어를 사용하였으나, 엄밀한 의미로 특허 공유라는 측면으로 이해하시길 바랍니다.

1. 귀하는 현행 특허제도의 문제점을 무엇이라고 생각하십니까?(복수응답가능)

- ① 지나친 기술 독점으로 인한 기술 혁신의 지장을 초래
- ② 지구환경(기후변화 등), 국민보건(의약품) 등에 관한 기술 독점으로 공공의 이익을 저해
- ③ Patent Troll과 같은 특허권 비실시자의 특허제도 악용으로 인해 피해 증대
- ④ 현행 특허제도에 대한 특별한 문제없음
- ⑤ 기타()

2. 특허제도를 보완하기 위해 특정분야의 기술 공유가 필요하다고 생각하십니까?

- ① 그렇다 ② 아니다(☞문4로 이동)

3. 기술 공유(특허 공유)가 어떤 면에서 도움이 된다고 생각하십니까?

- ① 기술 공유를 통한 기술혁신
- ② 기술 개발에 따른 비용 절감
- ③ 불필요한 특허권 침해 소송 예방
- ④ 인간의 삶과 밀접한 분야의 공공의 이익 달성
- ⑤ 기타()

4. 기술 공유(또는 특허 공유)가 도움이 되지 않는다고 생각하시는 이유는 무엇입니까?

- ① 기술 공유보다는 독점권 보장을 통해 기술 혁신이 가능하므로
- ② 기술 공유가 자칫 기술의 하향평준화를 초래할 수 있으므로
- ③ 권리자에게 부여되는 독점 배타권은 특허권 등의 지식재산권 본질이므로 권
리자에게 공익 추구를 강요하는 것 자체가 모순이므로
- ④ 기술 공유가 관련 산업발전에 미치는 실효성이 부족하므로
- ⑤ 기타()

5. 실제 기술 공유에 대한 사례를 알고 계시거나, 기술 공유를 활용하신 경험이 있으십니까?

- ① 예 ② 아니오(☞문8로 이동)

6. 기술 공유의 활용가치는 어느 정도라고 생각하십니까?

- ① 매우 크다 ② 크다
③ 보통이다 ④ 적다
⑤ 거의 없다

7. 기술 공유(혹은 저작권 공유)제도의 활용하여 결과적으로 어떠한 측면에서 효과를 보셨습니까?

- ① 기술 개발에 드는 시간·비용의 절감
- ② 풍부한 연구자료 확보를 통한 후속연구 활성화
- ③ 기술혁신 활성화
- ④ 기타()

8. 귀하는 앞으로 특허제도를 보완하기 위하여 기술 공유를 적극적으로 지지할 계획이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오(☞문10으로 이동)

9. 기술 공유 개념을 적용하기에 가장 적합한 산업 분야는 무엇이라고 생각하십니까?(복수응답 가능)

- ① 제조업 분야 ② 제약 분야
③ 생명공학 분야 ④ 에너지 분야
⑤ 환경 분야 ⑥ IT 분야
⑦ 기타()

10. 기술 공유에 관한 정책을 적극적으로 지지하지 않는 이유는 무엇입니까?

- ① 기술공유에 관한 정책이 특허제도를 형해화 시킬 가능성이 있으므로
- ② 또 다른 법적 분쟁을 야기할 소지가 크므로
- ③ 국가 경쟁력 차원에서 현행 특허제도를 유지하는 것이 바람직하므로
- ④ 정부 주도의 기술공유 정책보다는 민간 차원의 자발적인 기술공유 운동으로 충분하므로
- ⑤ 현행 특허제도의 보완(강제실시권 확대 등)으로 충분하므로
- ⑥ 기타()

11. 기술 공유는 위에서 언급한 민간 차원의 노력뿐만 아니라, 국제기구 및 정부 차원에서 공공 분야의 지식재산 관련 정책의 일환으로 논의되는 경우도 있습니다. 가령, 보건·환경·식품 등의 공공정책과 지식재산권의 조화를 위한 WIPO의 국제회의 개최, UN 기후변화 협약에서의 기술 공유화 논의, OECD의 ‘유전자관련발명의 라이선스 공여에 관한 가이드라인’ 제정, 일본의 ‘라이프사이언스 분야에 있어서 리서치툴 특허의 사용 원만화에 관한 지침’ 제정 등이 있습니다. 만약, 우리나라에서 보건·환경 등의 공공의 이익과 관련된 문제를 해결하기 위하여 정부 주도의 기술 공유정책을 추진한다면 귀하는 적극적으로 동참할 생각이 있습니까?

- ① 예 (☞ 문 13로 이동) ② 아니오 ③ 잘 모르겠다

12. 공익과 기술 혁신을 위한 정부 주도의 기술 공유 정책의 추진임에도 불구하고 귀하께서 적극적 동참을 주저하시는 이유는 무엇입니까?(복수응답가능)

- ① 기술공유에 관한 정책이 특허제도를 형해화 시킬 가능성이 있으므로
- ② 또 다른 법적 분쟁을 야기할 소지가 크므로
- ③ 국가 경쟁력 차원에서 현행 특허제도를 유지하는 것이 바람직 하므로
- ④ 정부 주도의 기술공유 정책보다는 민간 차원의 자발적인 기술공유 운동으로 충분하므로
- ⑤ 기타()

2 특허제도를 보완하기 위한 법제도 및 정책적 방향성 조사

우리나라 특허법에는 (1) 특허권의 수용(제106조), (2) 제106조의 2(정부 등에 의한 특허발명의 실시), (3) 통상실시권 설정의 재정(제107조)제도와 같이, 공익을 목적으로 특허발명을 실시할 수 있는 제도를 두고 있습니다. 그러나 이 제도의 활용은 전혀 되고 있지 않은 상황입니다. (예: 특허권으로 인해 2001년 백혈병 치료제 글리벡의 비싼 약값, 2005년 조류독감 유행에서 타미플루의 부족, 그리고 2008년 에이즈치료제 푸제온 미공급, 최근의 신종플루유행 등 국민의 건강과 생명이 위협을 당하는 많은 문제를 야기)

13. 귀하는 위와 같은 특허법상의 공익관련 특허실시제도에 대하여 알고 계십니까?

- ① 제도의 취지 및 목적, 실시 현황 등에 대하여 자세히 알고 있다
- ② 제도의 취지 및 목적은 알고 있으나, 실시 현황에 대해서는 잘 모르겠다
- ③ 제도에 대해 들어본 적은 있으나 그 내용이 무엇인지 알지는 못한다
- ④ 전혀 모르겠다

14. 현재 위와 같은 공익관련 특허 실시제도가 효율적으로 시행되고 있다고 생각하십니까?

- ① 그렇다(☞문16로 이동)
- ② 그렇지 않다

15. 공익관련 특허 실시제도가 효율적으로 시행되고 있지 않다면 그 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 독점배타권의 보장을 기본으로 하는 특허제도의 취지에 맞지 않아서
- ② 기술 선진국에서 이러한 제도를 시행한 사례가 없어 기술무역 환경에서 부담요소로 작용하므로

- ③ 우리나라의 입장에서 이러한 공익관련 특허실시제도를 장려하는 것은 득보다 실이 많으므로
- ④ 보상금이나 실시료의 산정방법이 없고, 실시를 위한 요건과 절차가 까다로우므로
- ⑤ 기타()

16. 기후변화 및 지구온난화 등의 환경문제와 공중위생 문제(의약품 등) 등의 공공 분야에 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 범위를 확대하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 긍정한다(☞문18로 이동)
- ② 대체로 긍정한다(☞문18로 이동)
- ③ 보통이다
- ④ 대체로 반대한다
- ⑤ 매우 반대한다

17. 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 범위 확대에 반대하는 이유는 무엇입니까?

- ① 이러한 제도의 남용이 우려되므로
- ② 독점 배타권이라는 특허제도의 형해화가 우려되므로
- ③ 국익의 입장에서 이러한 제도를 장려하는 것은 득보다 실이 많으므로
- ④ 기타()

18. 정책적 측면에서 특허제도의 보완의 방향성은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 정부의 개입은 최소한도로 하고, 민간 주도의 기술 공유 운동을 장려하여야 한다
- ② 인류의 번영을 위해 공익 및 혁신관련 기술 공유 관련 정책을 적극적으로 추진하여야 한다
- ③ 우리나라의 입장을 고려하여 국제적 추세를 살펴 정책을 마련하여야 한다.
- ④ 기타()

19. 정책적 측면에서의 특허제도를 보완한다면, 다음 중 가장 적절한 수단은 무엇이라고 생각하십니까?(복수응답가능)

- ① 특허 기부제 활용을 활용하여 공익 및 혁신에 대한 기술 보급
- ② 민간 주도 기술 공유 운동(eco-patent commons, Science commons) 장려
- ③ 범국가적 차원에서 지구환경, 공중보건과 직결되는 특허의 공유화를 위한 기금조성

- ④ 공익 및 혁신과 관련된 기술의 특허풀 장려
- ⑤ 기타()

20. 본 설문에서 논의된 것 외에 공익과 혁신의 관점에서 특허제도를 보완하기 위한 방안에 대해 자유롭게 기술해 주세요.

21. 특허제도의 목적에 비추어 볼 때, 공익과 혁신을 통한 산업발전을 위해 특허제도가 나아가야 할 방향은 무엇이라고 생각하십니까?

- 조사에 응답하여 주셔서 대단히 감사합니다 -
- 응답하신 설문은 산업재산권 정책 자료로서 소중히 사용하겠습니다. -

부 록 2 : 설문조사 결과





조사 기획

자료 수집 방법	• 무작위된 설문지를 활용한 개별 면접조사(필요 시, 이메일, fax 조사 병행)
모집단	• 산업계/연구계/학계/기타
조사 대상	• 기술공유와 전문가 집단
조사 기간	• 2010년 12. 1 - 12. 17
조사 샘플 수	• N=20

II. 실태조사 관련

1. 기술 공유에 대한 인식 조사
2. 특허제도를 보완하기 위한 법제도 및 정책적 방향성 조사



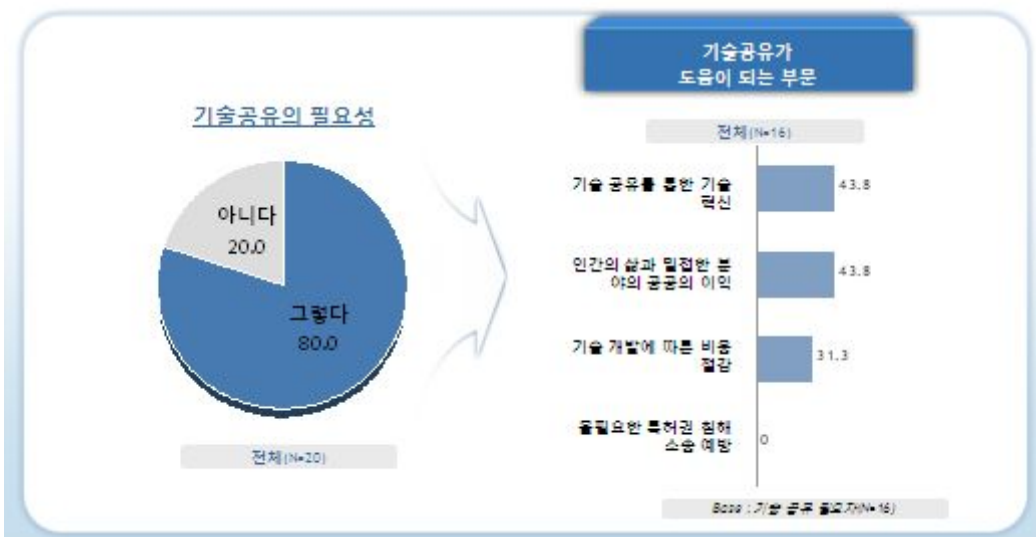
1. 특허제도의 문제점

- 특허제도의 문제점으로는 Patent Troll과 같은 특허권 비실시자의 특허제도 악용으로 인해 피해 증대가 50%로 가장 높게 나타남.



2. 특정분야의 기술 공유의 필요성(1)

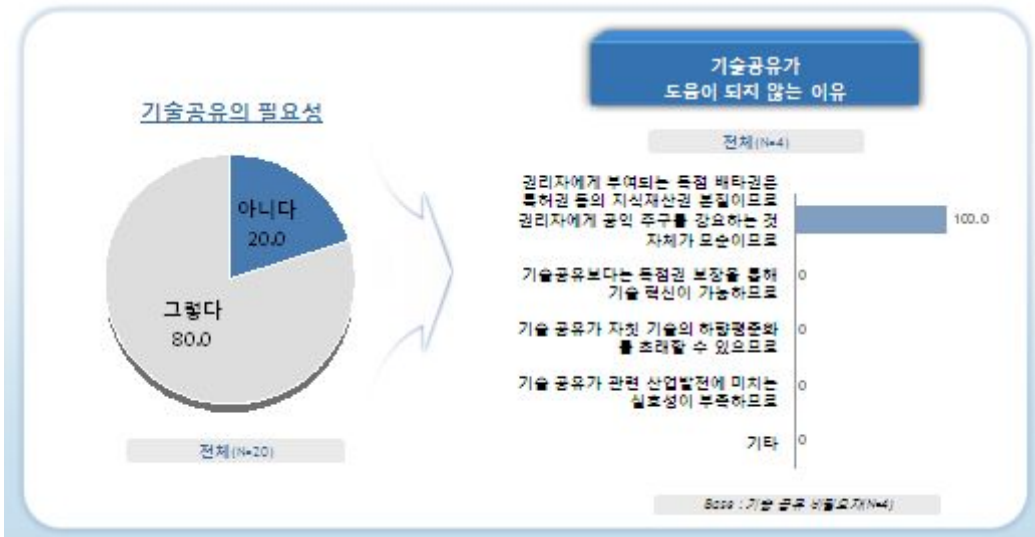
- 기술 공유의 필요성은 대부분 느끼고 있는 것으로 나타내며, 기술공유가 도움이 되는 부문은 기술 공유를 통한 기술혁신(43.8%), 인간의 삶과 밀접한 분야의 공공의 이익(43.8%) 순임





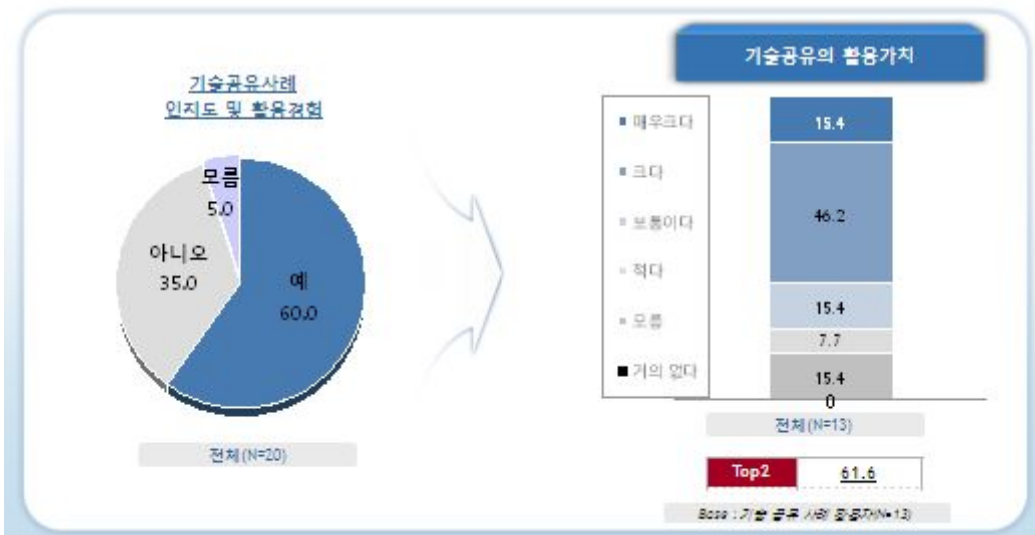
2. 특정분야의 기술 공유의 필요성(2)

- 기술공유의 필요성이 없다는 경우는 "권리자에게 부여되는 독점 배타권은 특허권 등의 지식재산권 본질이므로 권리자에게 공익 추구를 강요하는 것 자체가 모순이다"로 인식하기 때문에 필요성이 없다고 인식함



3. 기술공유에 대한 사례 인지도 및 활용 경험

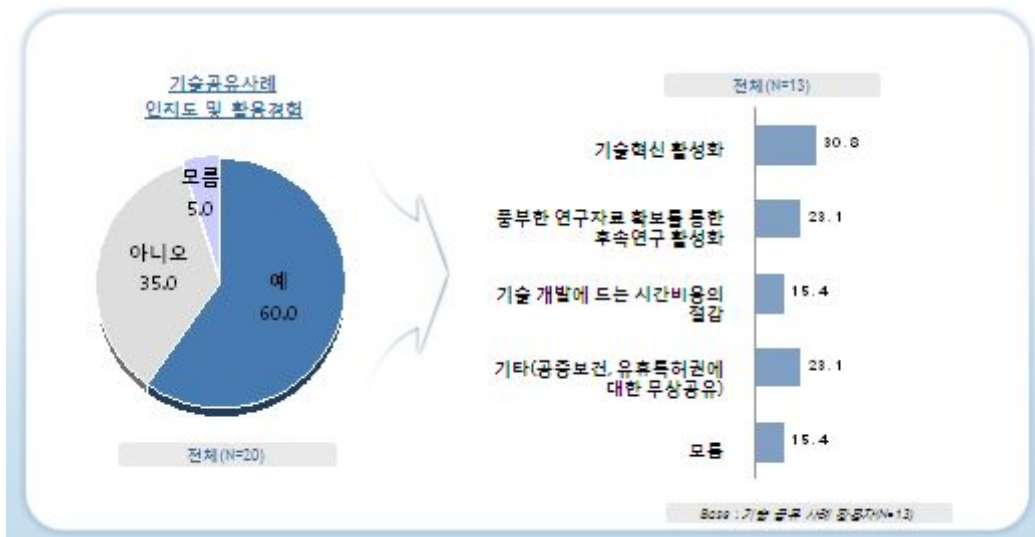
- 기술공유 사례를 알고 있는 경우는 95%로 대부분 인지하고 있는 것으로 나타나며, 활용한 경험은 약 60%로 나타나 대부분 인지하며 활용하는 것으로 나타남
- 기술공유의 활용가치는 크다는 의견이 61.5%로 높게 나타남





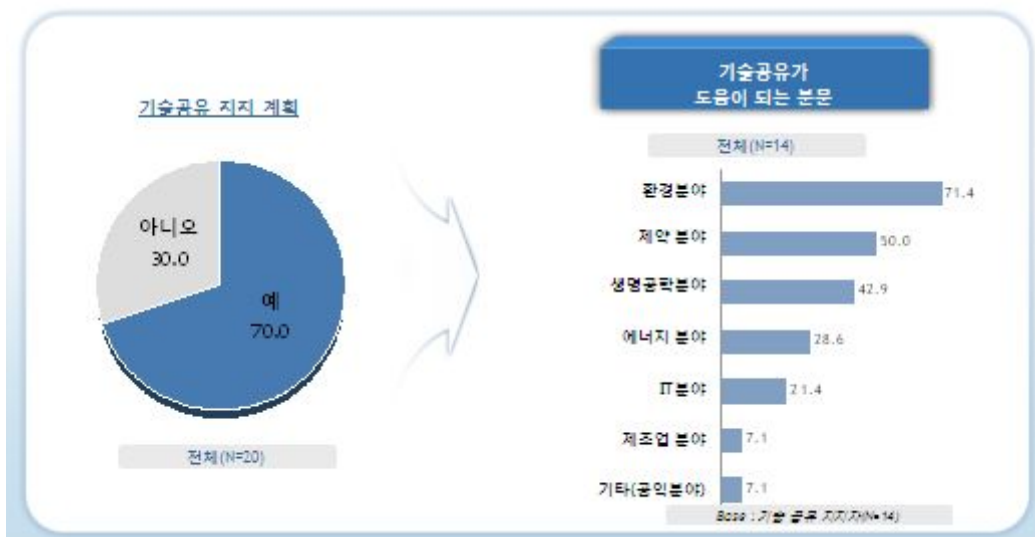
4. 기술공유제도의 활용 효과

* 기술공유제도의 활용되는 부분은 기술혁신 활성화(30.8%), 풍부한 연구자료를 통한 후속연구 활성화(23.1%) 순임



5. 기술공유 제도의 지지 및 활용분야

* 기술공유 제도의 지지는 약 70%이며 기술 공유가 도움이 되는 부문은 환경분야(71.4%), 제약분야(50.0%) 순으로 나타났다.





6. 기술공유 정책을 지지하지 않는 이유

- 기술공유 지지를 하지 않는 경우는 현행 특허제도의 보완(50.0%), 기술공유에 관한 정책이 특허제도를 형해화시킬 가능성이 있으므로(33.3%) 순일



7. 공공이익과 관련 정부 주도의 기술 공유정책

- 공익관련 기술공유 정책의 동참의향은 약 65%정도 형성되었으며, 비 동참자는 5%임
- 동참하지 않는 이유로는 정부 주도의 기술공유 정책보다는 민간 차원의 자발적인 기술공유 운동으로 충분 하므로가 가장 높게 나타남





8. 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 인지도

- 특허법상 공익관련 특허 실시제도의 인지도는 제도의 취지 및 목적은 알고 있으나, 실시 현황에 대해서는 잘 모르겠다는 의견이 가장 높게 나타남.



9. 공익관련 특허 실시제도가 효율적인지의 의견

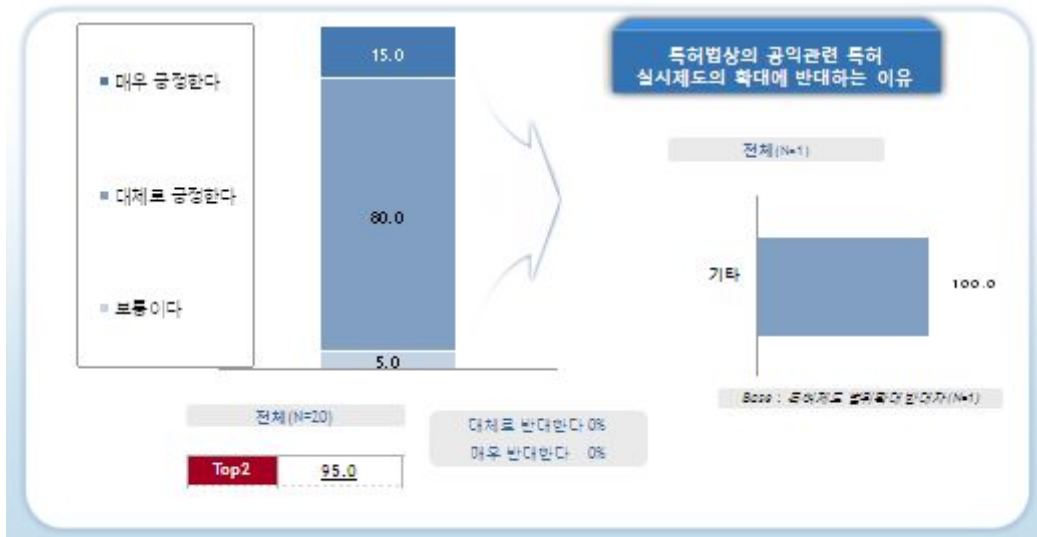
- 공익관련 특허 실시 제도의 효율성은 대부분 그렇지 않다 의견이 지배적이며
- 효율적으로 시행되고 있지 않은 이유는 보상금이나 실시료의 산정방법이 없고, 실시를 위한 요건과 절차가 까다로우므로 50% 순으로 나타남





10. 특허법상의 공익관련 특허실시제도의 확대 의견

• 특허법상 공익관련 특허 실시제도의 확대 의견으로는 긍정적으로 인식함



11. 정책적 측면에서의 제도보완의 방향성

• 정책적 측면에서의 제도보완의 방향성은 인류의 번영을 위해 공익 및 혁신관련 기술공유 관련 정책을 적극적으로 추진해야 한다는 의견이 45%이며, 우리나라의 입장을 고려하여 국제적 추세를 살펴 정책을 마련하여야 한다는 의견이 40%로 나타남.





12. 제도 보완 시 적절한 수단

* 제도 보완시 적절한 수단으로는 공익 및 혁신과 관련된 기술의 특허를 장려가 60%로 가장 높게 나타나며, 민간 주도 기술 공유 운동 50% 순으로 나타남.

